



CONTRATOS PARTE GENERAL

INTRODUCCIÓN

Este apunte está consagrado al estudio de los Contratos, en su parte general. La importancia de los tópicos que abordamos en este apunte está relacionada con la importancia del estudio de los contratos. En concordancia con las materias que ya hemos estudiado hasta aquí, podríamos decir que los contratos son las principales herramientas por medio de las cuales se materializa la autonomía privada, es decir, la facultad de cada particular para regular sus propias relaciones jurídicas.

En particular, la parte general de los contratos aborda las instituciones y reglas aplicables al género de los contratos en tanto especie de los actos jurídicos. De esta manera, además de su evidente vinculación con la parte especial de los contratos, el contenido de este apunte se encuentra en directa relación con lo ya estudiado a propósito de la teoría general del acto jurídico y del derecho de las obligaciones.

En términos más concretos y particulares, nos dedicaremos a la revisión del concepto de contrato, las principales clasificaciones de los contratos, tanto legales como doctrinarias, y sus respectivas consecuencias, los principios generales de la contratación y lo relativo a la interpretación de los contratos.

En esta materia, al igual que en el derecho de las obligaciones, nos encontraremos con importantes desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales que implican una evolución importante en el tratamiento clásico de varias de las instituciones que analizaremos. Al respecto, hemos optado por mantener la estructura clásica de las explicaciones doctrinales más tradicionales, y por consignar los aspectos discutibles o cuestionables de la materia en el cuerpo del apunte, o en un anexo si es que la importancia de las discusiones respectivas así lo amerita.

ÍNDICE

1. El concepto tradicional del contrato	4
2. La clasificación de los contratos en el Código Civil	7
2.1 Contratos unilaterales y bilaterales	7
2.1.1 Efectos propios de los contratos bilaterales	9
2.1.2 La cesión de los contratos bilaterales	15
2.2 Contratos gratuitos y onerosos	17
2.3 Contratos onerosos conmutativos y aleatorios	19
2.4 Contratos principales y accesorios	22
2.5 Contratos consensuales, solemnes y reales	24
3. Otras clasificaciones de los contratos	26
3.1 Contratos nominados e innominados	26
3.2 Contratos de ejecución instantánea, de ejecución diferida y de tracto sucesivo	28
3.3 Contratos individuales y contratos colectivos	29
3.4 Contratos libremente discutidos y contratos de adhesión	30
3.5 Contratos preparatorios y contratos definitivos	36
3.6 Según el rol que cumplen en la vida de una empresa	36
3.7 Contratos intuitu persona y contratos impersonales	38
3.8 Contratos de familia y contratos patrimoniales	39
4. Categorías contractuales	40
4.1 El contrato dirigido	40
4.2 El contrato forzoso	40
4.3 El contrato tipo	43
4.4 El contrato ley	45
4.5 El subcontrato	46
4.6 El autocontrato	48
4.7 El contrato por persona a nombrar y el contrato por cuenta de quien corresponda	50
5. Los principios de la contratación	54
5.1 La doctrina de la autonomía de la voluntad	54
5.1.1 Fundamento y críticas a la autonomía de la voluntad	54
5.2 El principio del consensualismo contractual	56
5.2.1 Subclasificación de los contratos consensuales	56
5.2.2 Excepciones y atenuantes al consensualismo	57
5.2.3 Ventajas del formalismo	59
5.3 El principio de la libertad contractual y su deterioro	59
5.4 El principio de la fuerza obligatoria de los contratos	60
5.4.1 Distintas fundamentaciones del principio	61
5.4.2 La fuerza obligatoria frente al legislador	62
5.4.3 La fuerza obligatoria frente al juez	65
5.4.3.1 La revisión judicial de los contratos en curso y la resolución por excesiva onerosidad sobreviniente	67
5.4.3.2 Adaptación convencional del contrato	68
5.4.4 La terminación del contrato	69
5.5 El principio del efecto relativo de los contratos	69

5.5.1 Sujetos concernidos por el efecto relativo	70
5.5.2 Excepciones al efecto relativo de los contratos	73
5.5.3 El efecto absoluto o expansivo de los contratos	76
5.5.4 La inoponibilidad de los contratos	78
5.5.5 La simulación y el efecto relativo de los contratos	83
5.6 El principio de la buena fe contractual	84
5.6.1 Funciones de la buena fe en materia de contratos	86
5.6.2 Manifestaciones de la buena fe objetiva	87
5.6.3 Conclusión	90
6. Interpretación de los contratos	91
6.1 ¿Cuándo deben interpretarse los contratos?	91
6.2 Interpretación subjetiva de los contratos	92
6.3 Las reglas de interpretación de los contratos	93
6.3.1 Naturaleza jurídica de las reglas de interpretación	93
6.3.2 Casos de interpretación legal	94
6.3.3 Reglas relativas a los elementos intrínsecos	94
6.3.4 Reglas relativas a los elementos extrínsecos	96
6.3.5 Reglas subsidiarias de interpretación contractual	98
6.4 Críticas del profesor López Santa María al sistema subjetivo de interpretación contractual	99
6.5 Interpretación objetiva de los contratos	99
6.6 Interpretación de los contratos y casación en el fondo	101
6.6.1 El recurso de casación en el fondo por una errónea calificación del contrato	103
6.6.2 Discusión acerca de la procedencia del recurso de casación en el fondo por una errónea interpretación del contrato	104
Anexo I – Covid-19, caso fortuito y teoría de la imprevisión	105
Anexo II – Proyecto de ley acerca de la teoría de la imprevisión	108

LOS CONTRATOS. PARTE GENERAL

CAPÍTULO 1. EL CONCEPTO TRADICIONAL DEL CONTRATO.

1. Generalidades

Contrato: acto jurídico bilateral que crea obligaciones.

Rol de la autonomía privada: La voluntad de las partes es fuente y medida de las obligaciones contractuales. La intención domina el nacimiento del contrato y sus efectos.

La formación del contrato está dominada por dos subprincipios de la autonomía de la voluntad:

- Consensualismo
- Libertad contractual

En cuanto relación jurídica ya creada, imperan las ideas fundamentales de:

- Fuerza obligatoria del contrato
- Efecto relativo de los contratos

En la interpretación, debe buscarse la intención de las partes.

2. El concepto del contrato en el Código Civil

Art. 1438 CC. "*Contrato o convención* es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas."

Críticas:

- 1) Identifica los términos contrato y convención, en circunstancias que la convención es el género y el contrato, la especie.
- 2) No hace mención a que en los contratos las partes también se pueden obligar recíprocamente, no solo una en beneficio de la otra.
- 3) El objeto del contrato son las obligaciones que crea; el objeto de las obligaciones es la prestación: una cosa que se trata de dar, hacer o no hacer. La definición se salta una etapa, pues alude a la prestación como objeto del contrato.

3. Elementos de los contratos

Art. 1444 CC. "Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la *esencia* de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la *naturaleza* de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son *accidentales* a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales."

Elementos de los contratos:

- 1) Requisitos comunes a todos los contratos: requisitos del acto jurídico (Art. 1445 CC).
- 2) Requisitos propios de cada contrato: elementos esenciales, de la naturaleza o accidentales.

4. Funciones económica y social de los contratos

Función económica: es el principal vehículo de las relaciones económicas. La circulación de la riqueza y el intercambio de bienes y servicios se realizan primordialmente a través del contrato.

Función social: no sólo sirve para la satisfacción de necesidades individuales, sino que es además medio de cooperación o colaboración entre los hombres. Se relaciona con el principio de la buena fe.

En el contexto de su función económico-social, es necesario mencionar que para cierto sector de la doctrina más contemporánea, el contrato constituye un mecanismo para la distribución de riesgos entre los contratantes. Si bien el término "riesgo" no ha sido objeto de definición legal de ningún tipo, podemos definirlo doctrinariamente como la posibilidad de un daño de cualquier tipo. En el marco de los contratos, el riesgo debe entenderse como el peligro de insatisfacción del interés de los contratantes.

En efecto, la gran mayoría de las relaciones económicas se dan en un marco de incertidumbre acerca de la posibilidad de que las actividades que las partes realizan tengan éxito o que resulten frustradas, sobre todo cuando dichas actividades económicas implican relaciones duraderas en el tiempo. Las razones por las cuales un negocio podrían fracasar son variadas: desastres naturales, enfermedades, acciones u omisiones por parte de terceros, entre otros.

El punto que nos interesa recalcar es que, cualquier prestación a que una parte se obligue a cumplir en virtud de un contrato, implica el riesgo del acaecimiento de cualquier circunstancia que pudiera frustrar el cumplimiento. Por medio del contrato, las partes distribuyen entre sí el riesgo de que ocurra algún hecho que frustré la posibilidad del cumplimiento del mismo. Así, algunos riesgos se considerarán dentro del ámbito de control del deudor, mientras otros quedarán excluidos de dicha esfera.

Naturalmente, rara vez los contratantes pactarán de manera expresa y detallada todos los riesgos que caben dentro y fuera del ámbito de control de cada contratante. La mayoría de las veces, la determinación concreta de la distribución de los riesgos entre los contratantes será objeto de interpretación e integración del contrato, según las reglas generales que estudiaremos en el capítulo 6 de este apunte. Por otro lado, también puede ocurrir que sea el propio legislador el que se haya encargado de distribuir los riesgos entre los contratantes.

La consideración del contrato como mecanismo de distribución de riesgos cobra una especial relevancia en el análisis de las causales eximentes de responsabilidad contractual. Por ejemplo, en torno al caso fortuito, recordemos que éste debe tratarse de un hecho imprevisible, irresistible y ajeno o exterior. Tradicionalmente, se ha entendido que la exterioridad en el caso fortuito es sinónimo de inimputabilidad. Es decir, el hecho es exterior si es que no es culpable. Para quienes sostienen la doctrina del contrato como mecanismo de distribución de riesgos, sería posible reformular el requisito de la exterioridad en términos objetivos, es decir, prescindiendo del elemento subjetivo de la culpa. Así, el requisito de exterioridad sólo se entenderá cumplido si es que el hecho que se invoca para fundamentar el incumplimiento no corresponde al ámbito de riesgos que el deudor había asumido sobre sí mismo. En otras palabras, un hecho solo será exterior si es que no es la materialización del riesgo que el contratante asumió sobre sí, por medio del contrato.

5. Subfunciones de los contratos

- 1) Cambio: circulación de los bienes, mediante contratos traslaticios de dominio. Para el perfeccionamiento de esta función es menester la tradición.
- 2) Crédito: generalmente onerosa, a través de contratos de mutuo, y en general, contratos bancarios; excepcionalmente gratuita, como en el comodato.
- 3) Garantía: contratos accesorios. Ej. Prenda, hipoteca y fianza.
- 4) Custodia: contratos destinados a la guarda y conservación de bienes ajenos. Ej. Depósito.
- 5) Laboral: contrato de trabajo, arrendamiento de servicios y mandato.
- 6) Previsión: contratos destinados a precaver riesgos. Ej. Seguro.
- 7) Recreación: Ej. contrato de transporte con fines turísticos, hotelería, juego, etc.
- 8) Cooperación: esencial en los actos intuitu personae.

CAPÍTULO 2. CLASIFICACIONES DE LOS CONTRATOS FORMULADAS POR EL CÓDIGO CIVIL CHILENO.

2.1 CONTRATOS UNILATERALES Y BILATERALES

Art. 1439 CC. "El contrato es *unilateral* cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna; y *bilateral*, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente."

No hay que confundirla con la clasificación de los actos jurídicos en unilaterales y bilaterales. Todo contrato es un acto jurídico bilateral.

1. Contrato unilateral: una sola de las partes resulta obligada, la que asume el rol de deudora, y la otra, de acreedora.

2. Contrato bilateral o sinalagmático: ambas partes resultan obligadas; cada parte es deudora y acreedora de la otra.

Importancia de la clasificación:

En los contratos bilaterales existe una interdependencia de las obligaciones: los sucesos que afectan a la obligación de una parte repercuten sobre lo que ocurre con la obligación de la contraparte.

El principal fundamento de los efectos propios de los contratos sinalagmáticos se encuentra en la idea de causa final: la causa es el fin perseguido por las partes, y no un motivo psicológico individual, sino que es siempre el mismo en los contratos de una determinada categoría. En los contratos bilaterales, el contratante se obliga a fin de obtener la prestación que en cambio le hay sido prometida. Si por algún motivo no es posible la ejecución de esta prestación, su obligación deja de tener causa.

La doctrina distingue, además:

CONTRATO PROPIAMENTE BILATERAL O SINALAGMÁTICO PERFECTO:

Todas las obligaciones surgen en el mismo instante, que es el del perfeccionamiento del contrato por la formación del consentimiento. Dichas obligaciones son interdependientes.

La interdependencia de las obligaciones no se agota en la génesis del contrato, sino que opera durante la fase de cumplimiento.

CONTRATO SINALAGMÁTICOS IMPERFECTO:

Son aquellos que nacen como contratos unilaterales, pero a propósito de los cuales ulteriormente emerge obligación para la parte que originalmente estaba dispensada. Ej. Depósito y comodato.

La terminología "sinalagmático o bilateral imperfecto" da la idea de que estamos frente a un contrato bilateral, lo que es inexacto. Es en el momento de su nacimiento o formación cuando un contrato pasa a revestir el carácter de unilateral o bilateral.

El contrato unilateral no pierde tal calificativo por quedar después obligada la parte que no lo estaba. Esa obligación deriva de la ley, no del contrato.

Al contrato sinalagmático imperfecto no se le aplican, en principio, los efectos particulares de los contratos bilaterales.

Se ha pretendido que sí sería aplicable la excepción de contrato no cumplido, pero no es convincente si se tiene en cuenta que para garantizar el cumplimiento de las nuevas obligaciones, el acreedor tiene el derecho legal de retención.

Sí sería factible aplicar la teoría de los riesgos o la cesión del contrato.

CONTRATOS PLURILATERALES O ASOCIATIVOS.

Son aquellos que provienen de la manifestación de voluntad de dos o más partes, todas las cuales resultan obligadas en vistas de un objetivo común.

La multiplicidad subjetiva, es respecto al contrato de que se trate, un elemento accidental, ya que el contrato se concibe sin problemas, vinculando exclusivamente a dos partes, como contrato bilateral. Ej. Sociedad. El contrato plurilateral sería una especie de contrato bilateral.

Diferencias doctrinarias entre contratos bilaterales y plurilaterales:

1) Derechos y obligaciones: En los bilaterales, surgen obligaciones correlativas; en los plurilaterales, cada parte adquiere derechos y obligaciones respecto a todos los demás.

2) Vicios del consentimiento: En los bilaterales, los vicios del consentimiento acarrearán la nulidad; en los plurilaterales, el vicio en uno de los contratantes se traduce en la ineficacia de su concurso al contrato, que es válido para las otras partes.

3) Ingreso de nuevas partes: Los bilaterales están limitados a las partes originarias; los plurilaterales admiten el ingreso de nuevas partes o el retiro de las iniciales.

4) Extinción inmediata del contrato/situación jurídica estable: Los bilaterales pueden extinguirse tan pronto como nacen, por el cumplimiento de las prestaciones, o ser de ejecución diferida; los plurilaterales generan una situación económica y jurídica estable, destinada a perdurar por mucho tiempo.

Para Messineo, esta figura no es un contrato, sino un acto colectivo.

2.1.1 EFECTOS PROPIOS DE LOS CONTRATOS BILATERALES

1. Resolución por incumplimiento
2. Excepción de contrato no cumplido.
3. Teoría de los riesgos
4. Teoría de la imprevisión.

1) Resolución por incumplimiento de las obligaciones del contrato (Art. 1489 CC).

Si uno de los contratantes voluntariamente se ha abstenido de ejecutar las prestaciones a que se encuentra obligado, si estuviera en mora, el otro puede demandar el cumplimiento forzado de lo que se le adeuda o, si lo prefiere, puede optar por desligarse del contrato, solicitando la resolución judicial.

La resolución por inejecución se encuentra esencialmente relacionada con la condición resolutoria, en particular con la condición resolutoria tácita (Art. 1489 CC).

La resolución basada en el Art. 1489 CC es la que interesa como efecto particular de los contratos bilaterales.

Es una resolución judicial, que supone un proceso declarativo. No opera de pleno derecho. Es un beneficio que la ley otorga al acreedor cuyo crédito no ha sido satisfecho.

Requisitos de la resolución por inejecución, según la doctrina clásica.

- 1) Debe haber incumplimiento del contrato. Basta que sea parcial.
- 2) El incumplimiento del deudor debe ser imputable a su culpa o dolo.
- 3) El actor debe haber cumplido sus obligaciones o estar llano a cumplir.
- 4) Se requiere, además, sentencia judicial.

Es necesario recordar que la doctrina y la jurisprudencia se han alejado de la formulación clásica de los requisitos de la resolución por incumplimiento.¹ La jurisprudencia más reciente ha estimado que basta el incumplimiento del deudor, sin requerirse la mora. Luego, de manera consecencial, tampoco se requiere que el actor haya cumplido con sus obligaciones o esté llano a cumplir, pues dicho requisito se exigía en relación a lo establecido en el art. 1552 CC, lo cual pierde relevancia al no requerirse la mora.

Efectos de la resolución por inejecución.

- Desaparece retroactivamente el contrato, conforme a las reglas de la resolución (Art. 1487 y siguientes).
- Si una parte ya había pagado, procede la devolución.

¹ Al respecto, recomendamos consultar el apartado 3.11.1.2.2 del apunte de obligaciones, donde se desarrolla esta evolución doctrinaria y jurisprudencial.

- Si se trata de un contrato de tracto sucesivo, la terminación opera sólo para el futuro.
- Además de la resolución, el demandante puede solicitar indemnización de perjuicios.
- La resolución sólo da acción contra terceros poseedores de mala fe (Arts. 1490 y 1491 CC).

2) Excepción de contrato no cumplido (Art. 1552 CC).

La doctrina tradicional ha comprendido que en esta norma se encuentra consagrada la excepción de contrato no cumplido. Por medio de dicha excepción, el deudor demandado se niega, en el proceso judicial respectivo, a cumplir su obligación mientras la otra parte no cumpla o no se allane a cumplir lo que le corresponda. Dicha excepción, además, se enuncia con la sintética formula de 'la mora purga la mora'.

En Chile, dicha institución se basa en el Art. 1552 CC.

Art. 1552 CC. "En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos."

No obstante lo anterior, la doctrina más moderna ha considerado que la posición anterior es errónea, toda vez que estaría confundiendo dos instituciones distintas: la excepción de contrato no cumplido, por un lado, y la compensación de moras, por el otro.

Esta distinción, que ha encontrado acogida en la jurisprudencia más reciente, es explicada por la profesora Claudia Mejías Alonzo en los siguientes términos: "No obstante fundarse en el mismo principio y compartir el supuesto de procedencia –si uno de los contratantes no cumple lo pactado o no se encuentra llano a hacerlo– difieren en sus efectos y forma de operar. La excepción de contrato no cumplido suspende temporalmente la pretensión de cumplimiento y su forma pura de operar es mediante una excepción en el juicio respectivo. La compensación en mora, por su parte, impide que uno de los contratantes pueda ser considerado en mora mientras no cumpla o se allane a hacerlo y opera de pleno derecho; constitución que se nos presenta vinculada a un mecanismo concreto de tutela del acreedor lesionado: la indemnización de perjuicios."²

Ahora bien, quienes consideran pertinente esta distinción, no niegan la

² Claudia Mejías Alonzo: "La excepción de contrato no cumplido y su consagración en el código civil chileno" (2013) . Disponible online en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372013000200002

existencia de la excepción de contrato no cumplido en el derecho chileno. El objetivo principal de esta distinción es clarificar el alcance y los efectos de los remedios del acreedor frente al incumplimiento y, como veremos más adelante, resulta especialmente relevante para efectos de la procedencia de la resolución por incumplimiento.

Por regla general, la excepción de incumplimiento contractual no pretende el término del contrato, sino impulsar al otro contratante a la ejecución de su obligación, lo cual tendrá como resultado justificar el cumplimiento íntegro de las obligaciones contractuales. En este sentido, la excepción de contrato no cumplido puede funcionar eficazmente como mecanismo extrajudicial de autotutela del acreedor frente al deudor incumplidor, quien podrá invocar el incumplimiento de su contraparte para negarse a cumplir con su propia prestación. No obstante, también es posible que la abstención en el cumplimiento genere de facto el término del contrato ante la desidia del otro contratante. En este caso opera una resciliación tácita por la aquiescencia de ambas partes.

Es posible que el asunto no se limite al ámbito extrajudicial y que una de las partes proceda a requerir la intervención de los tribunales de justicia. En este caso corresponderá al juez calificar el fundamento de la excepción de incumplimiento pudiendo acogerla desestimando el cumplimiento forzado.

Puede observarse, entonces, que la excepción de incumplimiento contractual interviene en diversas fases del íter contractual, y tanto de manera judicial como extrajudicial. Su función varía según la época y la forma en que se haga valer y, además, la calificación de sus condiciones y efectos sólo tendrá lugar en la hipótesis en que interviene un tribunal judicial o arbitral.

Las funciones de la excepción por incumplimiento contractual:

Las funciones que puede asignarse a la excepción por incumplimiento contractual no son uniformes, debiendo distinguirse según la oportunidad en que se haga valer. Entre ellas podemos señalar:

- La excepción por incumplimiento contractual puede significar un impulso a la ejecución de las obligaciones contractuales.
- La excepción por incumplimiento contractual opera en un ámbito considerable como una forma de justicia privada ajena a la intervención de los tribunales de justicia. En efecto, la excepción puede constituir un medio anticipado de término del contrato. Frente a la exigencia a ejecutar sus obligaciones el contratante requerido puede señalar como fundamento para su abstención el incumplimiento de la parte requirente.

- Respecto a la relación entre la resolución por incumplimiento y la excepción de contrato no cumplido, el problema se presenta con los casos de incumplimiento recíproco. En primer lugar, debemos recordar que, si bien la doctrina y la jurisprudencia tradicionales han exigido la mora del deudor como un requisito para la resolución por incumplimiento, la jurisprudencia más moderna ha tendido a omitir este requisito, considerando que el puro incumplimiento es suficiente para la resolución por inejecución.

De esta manera, la posición tradicional de la jurisprudencia fue no permitir la resolución ante casos de incumplimiento recíproco, esto es, si es que el acreedor tampoco había cumplido ni estaba llano a cumplir. Actualmente, la jurisprudencia sí ha tendido a conceder la resolución por casos de incumplimiento recíproco, aunque sin indemnización de perjuicios. Además de la prescindencia de la mora como requisito para la resolución, se sostiene un argumento de carácter económico: sería francamente contraproducente dejar a las partes vinculadas por un contrato que ninguna quiere cumplir.

Requisitos para que se acoja la excepción de contrato no cumplido:

- 1) Que se trate de un contrato bilateral.
- 2) La parte demandante no debe haber cumplido la prestación que le corresponde ni allanarse a cumplirla.
- 3) Que la obligación del demandante, que se afirma incumplida, sea actualmente exigible.

La CS ha sostenido que el Art. 1552 CC sólo se refiere a las obligaciones propias de la esencia y de la naturaleza del contrato, no las accidentales. Esto puede relacionarse con la buena fe y el incumplimiento de poca monta.

Efectos de la excepción de contrato no cumplido.

En este aspecto, nuevamente debemos distinguir entre la excepción de contrato no cumplido y la compensación de moras. Respecto a la excepción de contrato no cumplido, su efecto principal es la suspensión de la ejecución de las obligaciones. El deudor requerido para el cumplimiento de sus obligaciones se abstiene alegando el incumplimiento del demandante. Este efecto suspensivo es la primera manifestación extrajudicial de la excepción por cuenta y riesgo del deudor requerido. Este efecto de carácter temporal queda supeditado a la ejecución de las obligaciones de la contraparte. Pero, la actitud del acreedor requirente definirá en gran parte la suerte de las consecuencias de la excepción, pudiendo consolidarse el efecto suspensivo o a través de la intervención judicial determinar la extinción definitiva del contrato o su ejecución forzada. En síntesis, la excepción de contrato no cumplido suspende la

ejecución de las obligaciones, ya sea de manera extrajudicial, o de manera judicial en relación a la acción de ejecución forzosa.

Respecto a la compensación de moras, su efecto es impedir que cualquiera de los contratantes pueda ser considerado en mora, mientras la contraparte también lo esté, según el conocido adagio de que 'la mora purga la mora'. Así, el efecto de la compensación de moras es enervar la acción de indemnización de perjuicios.

3) Teoría de los riesgos (Arts. 1550 y 1820 CC).

Planteamiento de problema de los riesgos en materia contractual.

La pérdida fortuita de una cosa que es objeto de obligación, sólo podría ser para su dueño.

La teoría de los riesgos dice relación con los contratos en curso, más concretamente, los riesgos que hacen imposible el cumplimiento de una de las prestaciones emanadas de un contrato bilateral por una imposibilidad no imputable al deudor.

Al extinguirse la obligación de un contratante por imposibilidad de ejecución, ¿se extingue también la obligación correlativa del otro?

- Si la respuesta es afirmativa, el riesgo es del deudor;
- Si es negativa, el riesgo es del acreedor.

Condiciones para que se presente la teoría de los riesgos.

1) Que exista un contrato bilateral en curso, cuyo cumplimiento esté pendiente, al menos en parte.

2) Que se extinga la obligación de uno de los contratantes por imposibilidad de ejecución, o sea, a consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor.

Teoría de los riesgos en caso de extinción de una obligación de dar.

Lo más equitativo y técnicamente correcto es admitir, cuando se extingue la obligación de una de las partes por imposibilidad de ejecución, que deba también extinguirse la obligación correlativa: el riesgo sería del deudor.

Sin embargo, esta no es la solución del CC:

Art. 1550 CC. "El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba, es siempre a cargo del acreedor; salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarla, o que se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas; en cualquiera de estos casos, será a cargo del deudor el riesgo de la cosa, hasta su entrega."

Esto se confirma con la regla del Art. 1820 CC: el riesgo es para el comprador.

Excepciones al Art. 1550 CC:

- 1) Deudor que se encuentra en mora de efectuar la entrega.
- 2) Deudor se ha comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas.
- 3) Deudor que ha tomado sobre sí la responsabilidad del caso fortuito por un pacto expreso.
- 4) Riesgo de pérdida de la cosa debida bajo condición (Art. 1486 inc. 1º CC).
- 5) Obligaciones de género (teoría de los riesgos no opera en obligaciones de género ilimitado).
- 6) Destrucción de la cosa arrendada pone fin al arrendamiento (Art. 1950 Nº 1 CC).

En derecho comparado, la solución moderna es la inversa que la chilena: los riesgos son para el deudor.

Teoría de los riesgos en caso de extinción de una obligación de hacer o no hacer.

El Art. 1550 CC no soluciona el problema que plantea la imposibilidad de ejecución de una obligación de hacer o de no hacer, con el destino de la obligación correlativa. La doctrina establece dos posibilidades:

a) Un sector de la doctrina plantea la aplicación por analogía de los artículos 1550 y 1820 CC. Este sector de la doctrina distingue entre obligaciones de hacer personalísimas y no personalísimas, siendo las primeras aquellas que solo pueden ser cumplidas por el deudor. La solución analógica aplicaría solo para las obligaciones de hacer personalísimas, en las cuales el riesgo sería de cargo del acreedor. En las obligaciones de hacer no personalísimas, en virtud de los artículos 1553 nº2 y 1572 CC, el riesgo sería del deudor, el cual tendría que cumplir de todas formas.

b) A falta de disposición expresa debería optarse por establecer que el riesgo es del deudor. Según un sector de la doctrina, aquí habría propiamente una laguna, que correspondería integrar por medio del espíritu general de la legislación y con criterios de equidad. Los fundamentos de los efectos particulares de los contratos bilaterales permitirían postular que, hoy en Chile, el riesgo lo soportaría el deudor. Sirven de argumento: la interdependencia de las obligaciones, la doctrina de la causa y la equidad o buena fe.

4) Teoría de la imprevisión. Revisión y resolución por excesiva onerosidad sobrevenida.

Es la doctrina jurídica que sostiene que el juez puede intervenir en la ejecución de la obligación con el objeto de atenuar sus efectos, cuando, a consecuencia de acontecimientos imprevisibles para las partes al momento de contratar, ajenos a su voluntad, la ejecución de la obligación se hace más difícil o más onerosa.

Tradicionalmente, se ha sostenido que el campo de aplicación de la teoría de la imprevisión se radica exclusivamente en el marco de los contratos bilaterales. Esto, pues la fundamentación de la teoría de la imprevisión alude a la mantención de cierta relación proporcional entre las contraprestaciones de ambas partes. No obstante, tanto la doctrina moderna como el derecho comparado reconocen que la bilateralidad del contrato no es un requisito de la teoría de la imprevisión. Así, ésta podría aplicarse aún a contratos unilaterales, siempre que sean de tracto sucesivo o de ejecución diferida.

Continuaremos el análisis de esta doctrina cuando estudiemos el principio de fuerza obligatoria de los contratos.

2.1.2 LA CESIÓN DE LOS CONTRATOS BILATERALES³

La doctrina denomina “cesión de contrato” a la figura por la cual uno de los contratantes conviene en que un tercero ocupe su posición jurídica en el contrato. No es propiamente un efecto de los contratos bilaterales, sino una posibilidad que tienen los contratantes en el marco de los contratos bilaterales. Corresponde al conjunto de derechos, obligaciones, potestades y expectativas las que van involucradas en la cesión de contrato, todas las que se transfieren al “cesionario” que se subroga en el contrato del cedente.

La cesión de contrato es el paso siguiente necesario después de la aceptación de la asunción de deudas, y mira como ésta a la fluidez y circulación de las relaciones contractuales.

Como dice Manuel García-Amigo⁴ “la cesión de contratos es un negocio jurídico concluido entre las partes contratantes y un tercero, cuya finalidad es sustituir a una de ellas por dicho tercero en la titularidad de la relación contractual, la cual permanece idéntica en su dimensión objetiva”.

³ CHAMORRO KEIM, Consuelo; Fragmentos de memoria de prueba para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Diciembre 2006

⁴GARCÍA-AMIGO, Manuel. *op. cit.*, p.80.

La cesión de contrato es un contrato en sí mismo, cuyo objeto es la transferencia de la posición jurídica del contratante cedente, que deberá, para su plena eficacia, contar siempre con la voluntad del contratante que permanece en el contrato, a menos que la ley imponga la cesión.

La cesión de contrato presupone un lapso temporal entre el momento de la perfección del contrato original y el de su consumación: lapso durante el cual una de las partes del contrato puede convenir con un tercero que pase a ser éste el titular de los créditos y de las deudas que configuran la relación contractual previamente establecida.

Siendo la cesión de contrato un contrato entre cedente y cesionario, rigen para él los mismos principios y reglas propias que para los contratos y en especial, lo relativo a la autonomía privada. Dentro de los límites que sean de aplicación, y hasta el máximo de eficacia que puede producir el contrato entre cedente y cesionario, estos pueden regular ésta según sus intereses y según la naturaleza y las circunstancias del negocio cedido. El papel de la autonomía privada, aplicada al contrato de cesión de contrato, explica y obliga a admitir la variedad de manifestaciones del fenómeno, tanto en relación al propio mecanismo de la cesión como acto y efecto, como en relación al resultado más o menos perfecto de modificación subjetiva del contrato cedido que puede desencadenar el negocio de cesión.

Según lo explicado, un sector de la doctrina ha sostenido que la naturaleza jurídica de la cesión de contrato es la conjunción de una cesión de derechos más una cesión de deuda.

Para otra parte de la doctrina, la cesión de contratos es un caso de subrogación convencional, en virtud de la cual un nuevo contratante pasa a ocupar el lugar del contratante subrogado, de forma única, en donde este tercero se hace titular de la relación contractual cedida en forma completa.

En el Derecho Privado Patrimonial chileno no hay ninguna disposición que prohíba la cesión del contrato en términos generales. Sin embargo, es posible encontrar diversos casos específicos frente a la figura de la cesión de contrato:

- Casos en que la ley ordena la cesión de contrato: sucesión por causa de muerte, contrato de arrendamiento (artículo 1962 del Código Civil), contrato de seguro (artículo 530 del Código de Comercio),
- Casos en que no resulta posible la cesión de contrato sea por la esencia misma, como lo son los contratos intuitu personae o cuando se trata de contratos unilaterales o por disposición de la ley, como sucede en el contrato de mandato artículo 2135.
- Casos en que la ley autoriza la cesión de contrato: contrato de arrendamiento (artículo 1946 del Código Civil, 7 y 15 del D.L. 993);

contrato de sociedad (artículo 2088 del Código Civil); contrato de seguro (artículo 27 D.F.L. 251 de 1931 y artículo 1246 del Código de Comercio), contrato de transporte (artículo 176 del Código de Comercio), algunos contratos administrativos (reglamento para contrato de obras públicas, reglamento para contratos de ejecución de obras de edificación y urbanización para servicios e instituciones de la vivienda).

2.2 CONTRATOS GRATUITOS Y ONEROSOS

Art. 1440 CC. "El contrato es *gratuito o de beneficencia* cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y *oneroso*, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro."

Lo general es que los unilaterales sean gratuitos, y los bilaterales, onerosos. Pero no es la regla absoluta.

Contratos unilaterales onerosos:

- En el mutuo: Cuando se refiere a dinero, el mutuario debe devolver la suma recibida (el capital), más los intereses devengados (Ley N° 18.010 sobre operaciones de crédito de dinero: la gratuidad no se presume en estas operaciones. A falta de estipulación, el mutuario debe pagar los intereses). El contrato entonces es provechoso para ambas partes, pero sigue siendo unilateral, pues el único que resulta obligado es el mutuario, a pagar las sumas adeudadas. En cambio, si se estipula que la suma prestada no devengará intereses de ninguna clase, el contrato será unilateral y gratuito, pues no le reportará beneficio alguno al mutuante.
- En el depósito, cuando el depositario está facultado para usar la cosa en su provecho (Arts. 2220 y 2222 número 2 CC).
- En el comodato en pro de ambas partes (Art. 2179 CC): por ejemplo, el perro de caza que se presta con la obligación de amaestrarlo; o la parcela que se presta gratuitamente, obligándose el comodatario a efectuar innovaciones que incorporen nuevas tecnologías en el manejo de los frutales.
- En las cauciones constituidas por terceros, ajenos a la obligación principal que se garantiza, en virtud de una remuneración o prestación en general realizada o prometida por el deudor principal. En tal hipótesis, el contrato de hipoteca, prenda, fianza, etc., tendrá carácter oneroso, pues tiene por objeto la utilidad del acreedor y del garante (López Santa María). Sin embargo, algunos autores estiman que en el caso anterior, el contrato es unilateral pero gratuito, pues para que fuere oneroso, las partes contratantes deben gravarse recíprocamente, y en los casos citados, es un tercero, ajeno al contrato, quien se grava a

favor de una de las partes contratantes (Somarriva).

Contratos bilaterales gratuitos:

- Mandato no remunerado: Si bien el mandato es por naturaleza remunerado, en la práctica muchas veces tiene carácter gratuito, especialmente considerando que se trata de un contrato de confianza. Cuando no se remunera al mandatario, el contrato es gratuito y exclusivamente en beneficio del mandante. Sin embargo, el contrato es bilateral, ya que siempre impone al mandatario la obligación de hacerse cargo de los negocios cuya gestión le encomienda el mandante y a éste la obligación de proporcionar al mandatario lo necesario para ejecutar el encargo.
- Donación con cargas: La donación irrevocable o entre vivos, en la que se impone al donatario una carga o modo en beneficio de un tercero, es un contrato bilateral, pues genera obligaciones para el donante y para el donatario, y al mismo tiempo gratuito, ya que no origina utilidad económica al donante sino que exclusivamente al donatario y al tercero beneficiado con el modo

Importancia de la clasificación:

1) De qué culpa responde el deudor.

En el silencio de las partes y de la ley, el deudor responde según la regla del Art. 1547 CC:

- Onerosos: Culpa leve.
- Gratuitos: Culpa levísima si sólo él reporta utilidad, o de culpa grave si el provecho es de la contraparte.

2) Presencia de una obligación de garantía.

La obligación de garantía es característica de los onerosos, imponiendo la necesidad de sanear la evicción. Es cosa de la naturaleza de los onerosos en derecho comparado; en Chile, sólo respecto de algunos.

3) Celebración en consideración a las personas intervinientes.

- Lo contratos gratuitos normalmente se celebran en consideración a las personas intervinientes; son intuito personae.
- Sólo excepcionalmente los onerosos son intuito personae.

4) Deberes de reconocimiento en quienes reciben los beneficios.

Los gratuitos imponen deberes de reconocimiento a quienes reciben los beneficios. En el derecho chileno, esto se aprecia en alguna medida, por ejemplo, en las donaciones entre vivos, que son revocables por

ingratitude del donatario; y el donante tiene beneficio de competencia.

5) Presupuestos de admisibilidad de la acción pauliana.

Los presupuestos de admisibilidad de la acción pauliana son en los contratos:

- Gratuitos: menos estrictos, basta la mala fe del deudor.
- Onerosos: se requiere mala fe del deudor y del tercero.

6) Adquirente respecto al arrendamiento.

- El adquirente a título gratuito de una cosa arrendada debe respetar el arrendamiento;
- El adquirente a título oneroso sólo debe respetarlo si se celebró por escritura pública.

7) Pago de lo no debido (reivindicación contra un tercero).

En el pago de lo no debido de una especie, si la cosa pasa a un tercero, el que pagó indebidamente puede reivindicarla si el tercero adquirió la posesión en virtud de un título gratuito; no puede, si fue a título oneroso.

8) Donaciones.

El legislador ha establecido diversas restricciones tratándose de ciertos contratos gratuitos: así, exige la ley insinuación para donar, esto es, autorización judicial para donar (artículo 1401 CC); respecto también a las donaciones hechas a legitimarios o a terceros, podrán resultar inoponibles a los legitimarios, conforme al sistema de los acervos imaginarios, que incluyen la acción de inoficiosa donación (artículos 1185 a 1187 CC).

9) Para determinar cuando el acreedor prendario no puede invocar la prenda tácita (artículo 2401 CC): cuando el deudor vende la cosa dada en garantía o constituye a título oneroso un derecho para el goce o tenencia de la cosa, y el comprador o el tercero en cuyo favor se constituye el derecho, ofrece al acreedor pagar la obligación garantizada (art. 2404 CC).

2.3 CONTRATOS ONEROSOS CONMUTATIVOS Y ALEATORIOS.

Art. 1441 CC. "El contrato oneroso es *conmutativo*, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama *aleatorio*."

Críticas al Art. 1441 CC.

1. Adoptar como criterio la equivalencia de las prestaciones recíprocas es una base doblemente falsa:

- a) Supone que el contrato oneroso es siempre bilateral, en circunstancias que también puede ser unilateral como ya vimos.
- b) Equivalencia significa igualdad de dos o más cosas, y en el contrato oneroso las utilidades que recibe cada parte no son iguales, pues siempre suponen algún grado de incertidumbre que genera desigualdad. El legislador tolera esta desigualdad; sólo en ciertos casos reacciona mediante la institución de la lesión enorme. Nuestro Derecho tolera tal desigualdad en las utilidades que obtienen las partes, y sólo excepcionalmente, en ciertos contratos, establece normas reguladoras, al existir una ruptura violenta del equilibrio en las prestaciones: lesión enorme, que puede conducir a la nulidad o a la reducción de la prestación excesiva o el aumento de la prestación ínfima. En estos casos, la regla general acerca de la subjetividad en la equivalencia de las prestaciones se modifica, tornándose dicha equivalencia objetiva.

2. Sugiere que sólo pueden tener carácter conmutativo los contratos onerosos que engendran obligaciones de dar o hacer. No hay motivo para excluir el no hacer.

3. Incorre en una ambigüedad al decir que en el contrato aleatorio, la equivalencia consiste en una incertidumbre.

Elemento distintivo de los contratos conmutativos y aleatorios.

Lo que fundamentalmente distingue a estos contratos es que:

- En los conmutativos, las partes pueden, durante los tratos preliminares y al momento de la conclusión del contrato, apreciar o valorar los resultados económicos del mismo.
- En los aleatorios, ningún cálculo racional es factible respecto a las consecuencias económicas de la operación.

Contratos aleatorios vs. Contratos condicionales.

No debemos confundir ambas clases de contrato.

En los contratos aleatorios, no queda subordinada a una contingencia la existencia o inexistencia de las obligaciones, como ocurre en los contratos condicionales. En los contratos aleatorios, lo que queda sujeto a una

contingencia es el resultado económico del contrato, es decir, la mayor o menor utilidad que obtendrán las partes. Pero el contrato aleatorio es un contrato puro y simple.

La condición es un elemento accidental, que las partes voluntariamente incorporan al acto jurídico. En cambio, la contingencia de ganancia o pérdida, que también implica proyección hacia el futuro e incertidumbre, es un elemento de la esencia de los contratos aleatorios, que las partes no pueden eliminar si acordaron celebrar un contrato de este tipo.

Con todo, hay casos en los que existe gran analogía entre contratos condicionales y aleatorios, cuando de la contingencia incierta depende ya no la extensión de lo que a una parte corresponde pagar, sino que si tiene o no que pagar, es decir, si hay o no prestación. Así ocurre, por ejemplo, en los contratos de seguro contra determinados siniestros.

La mayoría de los contratos onerosos son conmutativos. El Art. 2258 CC menciona entre los aleatorios:

- el seguro,
- la renta vitalicia,
- el censo vitalicio,
- el juego y la apuesta.
- Respecto del seguro, ha dejado de ser para las aseguradoras un contrato aleatorio, si se analiza el negocio en su conjunto, debido a los cálculos actuariales y las estadísticas. Cada contrato de seguro en sí sigue siendo aleatorio.

Algunos sostienen que los contratos aleatorios serían mal mirados por el legislador, lo que en realidad sólo resulta cierto respecto del juego y la apuesta.

Hay contratos que, según las circunstancias, pueden ser conmutativos u onerosos. Es el caso de la compraventa de cosas que no existen, pero se espera que existan, cuando las partes expresan que se compró la suerte, o esto se deduce de las circunstancias de la especie. Si no es así, es conmutativo y condicional.

Importancia de la clasificación:

Hay dos instituciones jurídicas que sólo se aplican a los contratos conmutativos:

1) Lesión enorme en algunos contratos conmutativos en que la ley expresamente lo estipula (Recordar lo visto en acto jurídico).

Recordemos que la regla general es que los contratos no sean rescindibles por lesión enorme, puesto que la equivalencia es subjetiva,

las prestaciones “se miran” como equivalentes por las partes (aunque en verdad bien puedan no serlo).

Excepcionalmente, esta equivalencia debe fijarse dentro de ciertos límites, cuando la ley así lo establece, y la sanción en caso de contravención será la nulidad relativa o la reducción de la prestación excesiva o el aumento de la prestación ínfima. Tal acontece en la compraventa y la permuta de bienes raíces, por ejemplo.

Tratándose de la lesión enorme, la equivalencia deja de ser subjetiva y se torna objetiva, considerando la grave desproporción de las prestaciones que las partes miraron como equivalentes.

2) Teoría de la imprevisión (se estudiará en profundidad a propósito del principio de fuerza obligatoria de los contratos).

2.4 CONTRATOS PRINCIPALES Y ACCESORIOS.

Art. 1442 CC. “El contrato es *principal* cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y *accesorio*, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella.”

Contratos principales y accesorios.

Son **contratos principales**, por ejemplo, la promesa, la compraventa, el mandato, la transacción, el arrendamiento, la sociedad, el mutuo, el comodato, el depósito, etc.

Son **contratos accesorios**, por ejemplo, la hipoteca, la prenda, la fianza, la anticresis. Se agregan a los anteriores otras figuras que en sí no son contratos, pero que se incorporan en él, como la solidaridad pasiva y la cláusula penal (especialmente de un tercero).

En general las **cauciones** (Art. 46 CC) son contratos accesorios. Estas pueden ser reales o personales.

1. Reales: con una cosa determinada se asegura al acreedor que se le pagará íntegra y oportunamente la obligación principal.
2. Personales: un nuevo sujeto se compromete a cumplir la obligación si el deudor principal no lo hace.

Pese a que las expresiones “garantía” y “caución” suelen utilizarse como sinónimos, hay entre ellas una relación de género a especie. En efecto, toda caución es una garantía, pero no toda garantía es caución. Por ejemplo: el derecho legal de retención es una garantía, pero no es caución, pues no se trata de una obligación “contraída” (Art. 46 CC) para asegurar otra obligación. No hay de por medio un contrato, sino que es la ley, en este caso, la fuente de la garantía.

Contratos accesorios vs. Actos jurídicos dependientes.

No deben confundirse los contratos accesorios con los llamados contratos dependientes. Estos últimos, si bien requieren para cobrar eficacia la existencia de otro contrato, del que dependen, no están destinados a garantizar el cumplimiento de este último.

Tal ocurre con las capitulaciones matrimoniales (Art. 1715 CC) Para que sean eficaces, requieren la celebración del contrato de matrimonio, pero celebrado éste, las capitulaciones, que no lo garantizan por cierto, cobran vida propia, definiendo el régimen patrimonial entre los cónyuges.

Podrían ser también actos jurídicos dependientes los subcontratos, como el subarrendamiento, la subfianza y el submandato (llamado delegación). Aludiremos a ellos al tratar de las categorías contractuales.

Importancia de la clasificación: Lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

El contrato accesorio tiene una vida refleja en relación al contrato principal (Art. 2516 CC, prescripción de acciones; Art. 2381 Nº 3; y art. 2434).

Este principio, sin embargo, no es absoluto. En efecto, cabe formular dos situaciones particulares:

- Hay casos en los cuales, no obstante extinguirse el contrato principal, subsisten contratos accesorios, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la reserva de las cauciones, al operar una novación (artículos 1642 y 1643), o en el caso de la "cláusula de garantía general", a la que aludimos seguidamente.
- Por otra parte, excepcionalmente puede ocurrir que el contrato accesorio influya en el contrato principal:
 - Por ejemplo, si la cosa dada en prenda era ajena al constituyente o si el derecho que sobre ésta tenía se resuelve, el acreedor que no reciba otra garantía equivalente podrá exigir el cumplimiento de la obligación (Arts. 2406 en relación con el 2391 CC).
 - Si el inmueble hipotecado experimenta deterioros tales que deja de ser suficiente para la seguridad de la deuda, podrá el acreedor hipotecario exigir otra garantía y de no haberla, el pago inmediato de la deuda, si ella fuere líquida (Art. 2427 CC).
 - Podemos notar que en ambos casos, la extinción del contrato accesorio, repercute en el contrato principal, operando la caducidad de los plazos convenidos para el cumplimiento de la obligación pactada en este último contrato (artículo 1496 CC)

Cláusula de garantía general.

El derecho, por razones prácticas, acepta que lo accesorio tenga nacimiento antes que lo principal. Es el caso de la cláusula de garantía general: la fianza y

la hipoteca se pueden celebrar para caucionar obligaciones principales futuras.

2.5 CONTRATOS CONSENSUALES, SOLEMNES Y REALES.

Art. 1443 CC. "El contrato es *real* cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es *solemne* cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil; y es *consensual* cuando se perfecciona por el solo consentimiento".

La clasificación se relaciona con el momento del nacimiento del contrato. El consentimiento de las partes es requisito de todo contrato.

- 1. Consensuales:** contratos para cuya formación basta el consentimiento.
- 2. Solemnes:** el consentimiento debe expresarse cumpliendo con la formalidad objetiva establecida por la ley en atención a la naturaleza del acto.
- 3. Reales:** el consentimiento debe ir aparejado a la entrega de la cosa.

Crítica al Art. 1443 CC.

Si bien el Art. 1443 CC señala que en los contratos reales es necesaria la tradición, ello es cierto sólo respecto del mutuo, que es título traslativo de dominio, y en el cual se debe restituir otro tanto del mismo género y calidad. En los demás contratos reales (depósito, comodato, etc.), la entrega se efectúa en mera tenencia.

La regla general, en nuestra legislación es que los contratos sean consensuales.

En nuestro CC, el contrato consensual es la regla general, debido al dogma de la autonomía de la voluntad. Pero el principio del consensualismo no sólo se ve afectado en los contratos solemnes y reales, sino toda vez que se exige algún tipo de formalidad (habilitante, de prueba, etc.), lo que ocurre con mucha frecuencia.

Las formalidades objetivas de los contratos solemnes varían según el contrato de que se trate:

- 1) Escritura del acto: ya sea en escritura pública (Ej. Compraventa de bienes raíces) o privada (Ej. Promesa).
- 2) Autorización o aprobación judicial (Ej. Insinuación en la donación).
- 3) Presencia de testigos (Ej. Matrimonio).
- 4) Subscripción en el Registro Civil (Ej. Capitulaciones matrimoniales).

La inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, según algunos, es una solemnidad objetiva suplementaria en ciertos casos. Sin embargo, en esos casos, la inscripción no es requisito de formación de los contratos, sino que

sirve para operar el cumplimiento de ellos, lo que viene a ser la tradición.

Entrega que da origen al contrato real vs. Entrega que integra la fase de cumplimiento.

No hay que confundir la entrega que da origen al contrato real con la entrega que integra la fase de cumplimiento de muchos contratos.

En el caso de la entrega que integra la fase de cumplimiento del contrato, el deudor cede la mera tenencia del bien respectivo, extinguiendo así su obligación de entregar.

En el caso de la entrega que constituye la forma de perfeccionarse del contrato real, quien entrega la cosa se constituye como acreedor de una obligación restitutoria.

CAPÍTULO 3. OTRAS CLASIFICACIONES DE LOS CONTRATOS.

3.1 CONTRATOS NOMINADOS O TÍPICOS Y CONTRATOS INNOMINADOS O ATÍPICOS.

1. Contratos nominados o típicos: aquellos que han sido expresamente reglamentados por el legislador en códigos o leyes especiales.

2. Contratos innominados o atípicos: no han sido reglamentados.

En virtud de la autonomía de la voluntad y su derivado, el principio de la libertad contractual, las partes interesadas pueden celebrar contratos no regulados por el legislador. Su único límite es el respeto de las exigencias comunes a todos los actos jurídicos.

La doctrina extranjera clasifica los contratos atípicos en:

1) Atípicos propiamente tales o inéditos: contratos que en nada corresponden a los regulados por el legislador. Ej. Tiempo compartido, franchising.

2) Atípicos mixtos o complejos o híbridos: son una combinación de dos o más contratos reglamentados en la ley. Ej. Hotelería, que es mezcla de arrendamiento del goce de un recinto, arrendamiento de servicios y depósito.

El contrato atípico, de acuerdo al Art. 1545 CC, también es una ley para las partes; tiene plena fuerza obligatoria. El problema está en determinar la legislación supletoria por la cual se rigen. El criterio ha sido la asimilación del contrato atípico al contrato o contratos típicos más parecidos. En consecuencia, las lagunas contractuales en los contratos atípicos se dirimen por analogía.

Sin embargo, la falta de ajuste entre el contrato singular que las partes celebran y los tipos preestablecidos por la ley puede producirse de muy diferente manera. Puede suceder que las partes creen un contrato, ajustándose en principio a los moldes y a la función socioeconómica de un tipo preestablecido, pero se separe de él en un punto concreto, mediante la adición de pactos o de cláusulas que no corresponden a dicho tipo. Por ejemplo, se conviene la cesión temporal de uso de una cosa a cambio de la realización de un servicio. En estos casos, cabe mantener todavía al contrato dentro de la tipicidad legislativa (arrendamiento), siempre que la desviación producida no afecte a la esencia del contrato conforme a su naturaleza (En el ejemplo, no podría ser comodato, ya que él es esencialmente gratuito).

Existe aún, otra clasificación doctrinaria de los contratos atípicos que distingue los contratos mixtos, los contratos coligados y los contratos complejos.

Contratos mixtos son aquellos en que dentro de un único contrato confluyen elementos que pertenecen a tipos de contratos diferentes. Por ejemplo, un contrato en que se estipula el cambio de una cosa por otra con pago de la diferencia de valor en dinero sería un contrato mixto de permuta y compraventa. (El art. 1794 del C.C. se pone en este caso)

Contratos coligados son aquellos en que las partes yuxtaponen varios contratos típicos en un negocio único, para tratar de alcanzar con la unión de todos ellos la finalidad empírica que persiguen. Por ejemplo, se concierta un arrendamiento y se estipula una opción de compra en favor del arrendatario - leasing)

Contratos complejos son aquellos en que las prestaciones de cada una de las partes, las obligaciones asumidas y los pactos establecidos, aisladamente considerados, pertenecen a un tipo contractual preexistente del cual parcialmente se aíslan para integrarse en el negocio.

Importancia de la clasificación:

La importancia de esta clasificación radica en las cláusulas de la naturaleza, en la aplicación o no a los contratos innominados de la legislación supletoria a la voluntad de las partes.

En la disciplina de este tipo de contratos debe atenderse, ante todo, a las reglas contractuales establecidas por las partes, siempre que sean lícitas y admisibles. Además, están sometidos a la disciplina normativa general. Pueden plantearse, no obstante, problemas de interpretación o de puntualización de algunas lagunas del negocio.

La doctrina, para resolver el problema de la disciplina normativa del contrato atípico ha formulado dos tesis.

- Una, la teoría de la absorción, según la cual debe buscarse dentro de la totalidad de los contratos atípicos un elemento preponderante que se corresponde con el elemento preponderante de algún contrato típico y aplicar al conjunto la disciplina normativa del contrato típico al que pertenezca dicho elemento preponderante. (supone poder identificar cuales prestaciones son principales y cuales accesorias) Por ejemplo, en el contrato de garaje el elemento preponderante es una obligación de custodia que permitirá aplicar por absorción la normativa del depósito.
- La teoría de la combinación postula que cuando en los contratos atípicos coexistan prestaciones y elementos correspondientes a diferentes contratos típicos, la disciplina normativa aplicable a aquellos deberá reconstruirse combinando las normas correspondientes a cada uno de los contratos típicos. (esta teoría parece ser adecuada para los contratos

coligados, en que la yuxtaposición no hace perder a cada contrato yuxtapuesto su peculiar naturaleza jurídica).

En todo caso, la calificación de un contrato desde este punto de vista es un punto de derecho privativo de las cortes de casación.

3.2 CONTRATOS DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA, DE EJECUCIÓN DIFERIDA Y DE TRACTO SUCESIVO.

1. Contratos de ejecución instantánea o de una sola ejecución: aquellos en los cuales las obligaciones se cumplen apenas se celebra el contrato que las generó. El contrato nace y se extingue simultáneamente. Ej. Compraventa de mueble al contado.

2. Contratos de ejecución diferida: aquellos en los cuales alguna(s) obligación(es) se cumple(n) dentro de un plazo. El plazo puede ser expreso o tácito. De esta manera, podemos distinguir dos categorías de contratos de ejecución diferida:

- La primera, es aquella en que las obligaciones se cumplen en el plazo convenido, en un solo acto, quedando liberadas las partes (por ejemplo, cuando celebrada que sea la compraventa, acuerdan los contratantes que el precio se pagará y la cosa se entregará treinta días después);
- La segunda, es aquella en que las obligaciones se irán cumpliendo en distintos plazos, hasta que al cumplirse la última de ellas, se extinga la relación jurídica (por ejemplo, mutuo que se paga en cuotas).

3. Contratos de tracto sucesivo o de ejecución sucesiva: Son aquellos en los cuales la relación contractual tiene permanencia en el tiempo. Las partes se obligan a realizar una o más prestaciones de manera sucesiva y periódica, de manera que el cumplimiento se va escalonando en el tiempo, durante un lapso prolongado. Es necesario destacar que, pese a que la relación contractual misma tiene permanencia en el tiempo, las obligaciones periódicas que emanan de dicha relación no la tienen. Éstas se van generando en cada uno de los períodos que las partes hayan pactado, y se van extinguiendo ordinariamente por medio del pago. El ejemplo paradigmático del contrato de tracto sucesivo es el contrato de provisión de suministros, en virtud del cual una parte ("el proveedor") se obliga a dar una cantidad determinada de un bien determinado a la otra parte, con la periodicidad que ambos hayan pactado. Otros ejemplos de contratos de tracto sucesivo son el contrato de trabajo o el de arrendamiento.

Estos contratos suelen llevar una cláusula en cuya virtud sus efectos se van renovando por períodos similares, salvo voluntad contraria de las partes. Cuando se verifica la renovación, se habla de "tácita reconducción".

No es contrato de tracto sucesivo la ejecución de una obra material (lo importante en este contrato es que se ejecute la obra y no que se repitan las prestaciones periódicamente)

Importancia de la clasificación:

1) Nulidad y resolución operan con efecto retroactivo o no.

- La nulidad y resolución de los contratos de ejecución instantánea y diferida se producen con efecto retroactivo (Arts. 1687 y 1689 CC).
- En los contratos de tracto sucesivo, por lo general no es posible borrar los efectos ya producidos, por lo tanto se entiende que la nulidad y resolución o terminación sólo operan para el futuro.

2) Cómo opera la teoría de los riesgos.

- En el ámbito de los riesgos, el CC pone el riesgo a cargo del acreedor (si se extingue la obligación de una parte por caso fortuito, subsiste la obligación correlativa según el Art. 1550 CC).
- En el contrato de tracto sucesivo, la extinción de una obligación produce la extinción de la obligación de la contraparte. Así por ejemplo de conformidad al Art. 1950 CC la destrucción de la cosa arrendada pone término al contrato de arrendamiento.

3) Teoría de la imprevisión.

- La teoría de la imprevisión se concibe a propósito de los contratos de tracto sucesivo.
- Los remedios contemplados son inoperantes respecto de los contratos de ejecución instantánea; y queda la duda en los de ejecución diferida.

4) Resciliación por voluntad unilateral.

- En cuanto a la resciliación, excepcionalmente puede tener lugar por voluntad unilateral, en los contratos de tracto sucesivo: terminación por desahucio.

5) La caducidad convencional del plazo (cláusula de aceleración).

- Es particularidad de los contratos de tracto sucesivo y de los de ejecución diferida, siendo inaplicable para los contratos de ejecución instantánea.

3.3 CONTRATOS INDIVIDUALES Y CONTRATOS COLECTIVOS.

1. Contrato individual: aquel para cuyo nacimiento o formación es indispensable la manifestación de voluntad de todas las personas que resultan jurídicamente vinculadas. El contrato crea derechos y obligaciones exclusivamente para los que consintieron en él.

2. Contrato colectivo: aquel que crea obligaciones para personas que no concurrieron a su celebración, que no consintieron, o que incluso disintieron, oponiéndose a la celebración del contrato.

Ej. Contrato colectivo de trabajo, convenio judicial en la quiebra, acuerdos adoptados por asambleas de copropietarios en la propiedad horizontal.

Importancia de la clasificación: Los contratos colectivos son una excepción al efecto relativo de los contratos.

3.4 CONTRATOS LIBREMENTE DISCUTIDOS Y CONTRATOS POR ADHESIÓN.

1. Contrato libremente discutido: aquel en que las partes han deliberado en cuanto a su contenido, examinando y ventilando atentamente las cláusulas del contrato.

- Es resultado de las negociaciones preliminares.
- Las partes discuten en un relativo plano de igualdad y libertad, encontrándose su autonomía limitada exclusivamente por el necesario respecto al orden público y a las buenas costumbres.

2. Contrato de adhesión o por adhesión: Tradicionalmente, se ha estimado que corresponden a aquellos cuyas cláusulas son dictadas o redactadas por una sola de las partes, limitándose la otra a aceptarlas en bloque, adhiriendo a ellas. No obstante, la jurisprudencia y la doctrina más recientes han estimado que el rasgo esencial del contrato de adhesión es la importante desigualdad de poder negociador entre ambos contratantes. Suele ser el caso que quien tiene mayor poder negociador redacte unilateralmente las cláusulas contractuales, pero este último rasgo no es de la esencia del contrato de adhesión.

Normalmente, la doctrina reconoce la existencia de un contrato de adhesión cuando la oferta es:

- i. General: destinada a una colectividad de eventuales contratantes.
- ii. Permanente: sigue en vigor mientras no es modificada por su autor.
- iii. Minuciosa: reglamenta detalladamente todos los aspectos de la convención.

El profesor Iñigo de la Maza⁵, siguiendo las características acuñadas por Todd Rackoff, señala que nos encontramos frente a un contrato por adhesión cuando se satisfacen las siguientes condiciones:

- (1) El documento cuya validez legal está en entredicho es una forma impresa que contiene una pluralidad de términos y aspira a ser un contrato;
- (2) dicha forma ha sido redactada por, o a nombre de, una de las partes de la transacción;
- (3) aquella parte que ha redactado los términos participa en numerosas transacciones de aquellas representadas por la forma y realiza rutinariamente este tipo de transacciones;
- (4) la forma impresa es presentada al adherente con la prevención que, salvo algunos pocos términos –y las más de las veces ni siquiera esto- podrán ser

⁵ De La Maza, Iñigo, Contratos por adhesión y cláusulas abusivas ¿Por qué el Estado y no solamente el mercado?, pág. 2

modificados, manteniéndose el grueso de la estructura del contrato como la diseñó la parte redactora;

(5) después de que las partes –en caso que los hayan- lleguen a un acuerdo sobre aquellos términos abiertos a la negociación, la parte adherente debe firmar la forma;

(6) comparada con la parte adherente, la parte redactora lleva a cabo un número reducido de estas transacciones y;

(7) la principal obligación de la parte adherente en la transacción considerada como un todo es el pago de una suma de dinero.

Sin embargo, otra parte de la doctrina señala que el fenómeno de la adhesión también podría darse en una convención única entre dos personas, en la cual la oferta no tendrá tales características.

El rasgo decisivo de la adhesión se encuentra en el desequilibrio del poder negociador de los contratantes: el contrato es obra exclusiva del oferente, que dicta el texto de la convención.

- El destinatario, siendo el más débil, no puede discutir la oferta y debe circunscribirse a aceptarla.
- Además, generalmente no es posible que el destinatario pueda rehusar a la contratación.

La adhesión es conceptualmente independiente de la contratación masiva, lo que no impide que a menudo vayan aparejadas.

Tratamiento en nuestra legislación.

Nuestro Código Civil no sistematiza los contratos de adhesión, pero cada día han ido cobrando mayor fuerza. Por ejemplo: los contratos suscritos con Isapres, Administradoras de Fondos de Pensiones, compañías de seguros, de cuenta corriente bancaria, de líneas de crédito bancarias o abiertas en casas comerciales, etc. También operan en el área del suministro de servicios básicos, como los relativos a energía eléctrica, agua potable, gas, etc.

Justificación de los contratos de adhesión.

Estos contratos responden a la masificación de las relaciones jurídicas, a la exigencia de una expedita conclusión y a la necesidad de unificar relaciones análogas.

Constituyen una herramienta indispensable en un sistema de producción y de distribución de masas.

Ventajas de los contratos de adhesión.

El contrato de adhesión presenta beneficios para la actividad económica, por ejemplo, distingue la doctrina:

- Reduce los costos de transacción. Se tiene la ventaja que los costos de asesoría, redacción, debate y relaciones precontractuales y el tiempo que demoran los asume el ofertante y ofrece un producto final al aceptante.
- Permite un mejoramiento de la gestión de la empresa. Facilita la división de las tareas en la organización empresarial al concentrar el trabajo jurídico.
- Reduce las necesidades de comunicación.
- Facilita la planificación.

Peligros involucrados en la adhesión⁶. -

1) Cláusulas abusivas: son aquellas notablemente desfavorables para el adherente, en términos que causan un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que derivan del contrato. La doctrina las asocia a la ruptura del deber de buena fe y equidad que suele exigirse a los contratantes.

Otros autores las denominan como cláusulas ineficientes en el sentido que el daño que infligen a los compradores es mayor que los costos que ahorran a los proveedores.

2) El monopolio del oferente: la doctrina suele afirmar que las cláusulas abusivas obedecerían a la conexión entre la utilización de contratos de adhesión y la posición monopólica de quien ofrece este tipo de negocios, pues en un mercado competitivo únicamente sobrevivirían aquellas cláusulas cuyos beneficios son positivos.

Esto, sin embargo, no es del todo exacto porque también podemos encontrar cláusulas abusivas en mercados competitivos.

3) Problemas de información. Suele ser común que los consumidores no inviertan los recursos necesarios para conocer toda la información relativa al negocio que están contratando, e incluso, cuando lo intentan se pueden presentar los siguientes problemas:

- Lenguaje difícil de entender para el consumidor promedio.
- Letra pequeña u otros obstáculos que dificultan la lectura.
- Tiempo limitado.
- El agente no posee la autoridad necesaria para negociar los términos del contrato.
- El acuerdo asigna la distribución de riesgos de ocurrencia improbable.
- Los términos utilizados en estos contratos suelen ser bastante similares en un mismo rubro.
- Los consumidores tienden a asumir que los tribunales no harán exigibles los términos excesivamente abusivos al interior de un contrato por adhesión.

⁶ Sección basada en el texto ya citado del profesor Iñigo de la Maza

Naturaleza jurídica de la adhesión.

Sobre la naturaleza jurídica de la adhesión, hay 2 doctrinas:

1. Tesis anticontractual: los contratos de adhesión no son realmente contratos.

El consentimiento en un contrato supone un debate entre las partes, lo que implica la igualdad de situación de ellas. En los contratos de adhesión, no hay discusión ni igualdad entre las partes: la exclusiva voluntad del oferente es la ley del acto jurídico.

En consecuencia, el contrato por adhesión es un acto unilateral, que produce efectos en favor o en detrimento de los que adhieren a él.

La finalidad de esta teoría es dar al juez un poder de apreciación más amplio que aquel que tiene respecto de los contratos libremente discutidos: el contrato por adhesión no sería estrictamente obligatorio para el juez.

2. Tesis contractual: el contrato por adhesión no tiene una naturaleza jurídica diversa de la de los contratos libremente discutidos.

La voluntad del aceptante es indispensable para la conclusión del acto jurídico. La adhesión es un modo especial de aceptación. En consecuencia, la adhesión no es un acto unilateral. Ambos consentimientos tienen jurídicamente el mismo valor, aunque no participen en las mismas condiciones.

Sin embargo, si tienen un peso diferente, lo lógico es que jurídicamente tengan distinto valor.

- Al parecer, la tesis anticontractual fracasó por la excesiva extensión o vaguedad de la idea del contrato de adhesión. Además, la desigualdad del poder negociador se encuentra, con mayor o menor amplitud, en todos los contratos.
- La jurisprudencia chilena, sólo excepcionalmente ha admitido la autonomía del contrato de adhesión, declarando consecuencias jurídicas particulares para él.

Soluciones a los inconvenientes de la adhesión.

Problema: el contratante más poderoso a veces impone cláusulas abusivas al adherente. Mecanismos de solución:

1) Intervención del legislador y el contrato dirigido.

En los casos marcados de abusos (Ej. Contrato individual de trabajo, arrendamiento, contratos de edición, etc.), el legislador ha intervenido reglamentando imperativamente las cláusulas más relevantes de estos contratos, para cautelar los intereses de los más débiles, lo que ha dado origen al contrato dirigido, cuando la intervención es a priori.

En estos casos la contratación deja de ser la imposición de la voluntad de una de las partes. Tanto oferente como aceptante consienten en vincularse por un marco legal preestablecido.

Los contratos de adhesión más característicos han sido sometidos a un estatuto de orden público, que atribuye carácter obligatorio a ciertas fórmulas, o prohíbe otras.

2) Homologación por el poder público de los modelos de contratos estandarizados que se van a ofrecer después a los consumidores.

Todo contrato redactado debe previamente someterse al control y autorización de una determinada entidad la que se preocupará de tutelar los intereses de los futuros aceptantes.

Ejemplo: La Ley Nº 18.660 establece que la Superintendencia de Valores y Seguros tiene la obligación de mantener un registro públicos de los modelos de los textos de las pólizas de seguros y sus modificaciones, quedando vedado a las compañías de seguros proponer a sus clientes modelos de contratos que no hubieren sido aprobados por dicha entidad.

Otro ejemplo importante podemos encontrarlo en la Ley Nº 19.496 sobre Protección a los Derechos del Consumidor, la que establece en su artículo 55 que el Sernac deberá otorgar un sello Sernac a los contratos de adhesión de Bancos e instituciones financieras, establecimientos comerciales, compañías de seguros, cajas de compensación, etc.

3) Generalización de los contratos-tipo bilaterales acordados por grupos con intereses antagónicos.

El profesor Jorge López Santa María menciona esta tercera vía. Se trata de un mecanismo a través del cual, actores con intereses contrapuestos convienen un texto de común acuerdo, que luego será empleado en la celebración de numerosos contratos individuales, calcados sobre el modelo preestablecido.

El autor propone, como ejemplo, a fin de fijar las condiciones de la contratación masiva de los seguros voluntarios contra riesgos inherentes a la conducción de vehículos motorizados, que los automovilistas chilenos podrían agruparse y negociar con las compañías aseguradoras una póliza tipo, que más tarde sería utilizada en los miles de contratos de seguros individuales, no siendo éstos, en tal caso, contratos de adhesión, atendida la participación directa o indirecta del asegurado, durante la fase previa del contrato tipo bilateral. Sería beneficioso entonces promover la celebración de contratos colectivos entre grupos que en principio, tienen intereses contrapuestos o complementarios.

4) En derecho comparado ha surgido una nueva concepción de la lesión enorme.

A través del Art. 158 del Código Civil Alemán de 1900, se abrió paso a una nueva concepción de la lesión enorme que permite morigerar los casos de abusos notorios del oferente frente al adherente. Esto al establecer que será nulo cualquier acto jurídico por el cual alguien, explotando la necesidad, la ligereza o inexperiencia de otro, obtiene, a cambio de una prestación, ventajas patrimoniales que se hallen en abierta desproporción con el valor de dicha prestación.

Sin embargo, esta concepción no se acepta en nuestra legislación que concibe una postura restringida en relación a la procedencia de la lesión.

Limitaciones legales a los contratos de adhesión en el derecho chileno.

Como una forma de impedir o atenuar la posible inequidad que supone para una de las partes el contrato de adhesión, se promulgó la Ley N° 19.496, que establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

En esta ley, se define el contrato de adhesión como aquél cuyas cláusulas han sido propuestas unilateralmente por el proveedor sin que el consumidor, para celebrarlo, pueda alterar su contenido.

Esta ley ha constituido un avance para frenar los abusos en que puede incurrir quien redacta el contrato. Especialmente significativas son las normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos de adhesión (Normas del Párrafo 4°).

El Art. 16 dispone que no producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que:

- a) Otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato o suspender unilateralmente la ejecución del contrato;
- b) Establezcan incrementos de precios por servicios, accesorios, financiamientos o recargos, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales;
- c) Pongan de cargo del consumidor los efectos de deficiencias, omisiones o errores administrativos, cuando ellos no les sean imputables;
- d) Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor;
- e) Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor.
- f) Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o inutilizados antes de que se suscriba el contrato.
- g) En contra de las exigencias de la buena fe, atendiendo para estos efectos a parámetros objetivos, causen en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que para las partes se deriven del contrato. Para ello se atenderá a la finalidad del

contrato y a las disposiciones especiales o generales que lo rigen. Se presumirá que dichas cláusulas se encuentran ajustadas a exigencias de la buena fe, si los contratos a que pertenecen han sido revisados y autorizados por un órgano administrativo en ejecución de sus facultades legales.

Reglas especiales para interpretar el contrato de adhesión.

Existen reglas de interpretación contractual que son propias de los contratos de adhesión:

- 1) Interpretación contra el redactor. Esta regla está establecida en el Art. 1566 inc. 2º CC, y es una buena herramienta para atenuar abusos de la adhesión, aunque no soluciona todos los problemas.
- 2) Preferencia de la cláusula manuscrita sobre la cláusula impresa. Esta regla no está directamente establecida en el CC, pero deriva del Art. 1560 CC, pues la cláusula manuscrita que contradice a una impresa es considerada la genuina expresión de la voluntad común.

3.5 CONTRATOS PREPARATORIOS Y CONTRATOS DEFINITIVOS.

1. Contrato preparatorio o preliminar: aquel mediante el cual las partes estipulan que en el futuro celebrarán otro contrato que por ahora ellas no pueden concluir o que está sujeto a incertidumbre, siendo dudosa su factibilidad.

Ejemplo:

- Contrato de promesa de celebrar un contrato (Art. 1554 CC).
- Otro ejemplo es el contrato de opción que consiste en la oferta unilateral de contrato que formula una de las partes de manera temporal, revocable y completa en favor de la otra que se limita a aceptar esta declaración.
- Otro ejemplo es la cláusula compromisoria.

2. Contrato definitivo: es el que se celebra cumpliendo con la obligación (de hacer) generada por el contrato preparatorio.

3.6 SEGÚN EL ROL O SERVICIO QUE CUMPLE CADA CONTRATO EN LA VIDA PATRIMONIAL DE UNA EMPRESA ⁷: CONTRATOS PREPARATORIOS, DE INTERCAMBIO, DE COLABORACIÓN Y DE GARANTÍA.

Dentro de esta clasificación de contratos que permiten organizar la vida patrimonial de una empresa, es posible distinguir entre aquellos que sirven para: (i) preparar un contrato posterior; (ii) realizar el intercambio de bienes o servicios; (iii) ordenar la colaboración de dos o más personas con un objetivo común; y, (iv) garantizar el cumplimiento de una obligación.

⁷ Clasificación de los profesores David Nuñez, Diego Pardow y Francesco Campora

1. Contratos preparatorios: Son aquellos que se utilizan para regular el proceso de negociación de un contrato posterior. Así por ejemplo, mediante acuerdos previos pueden incluirse reglas para evitar conductas oportunistas de las partes (exclusividad, confidencialidad), valorar su costo de oportunidad (cláusula penal, arras) o restringir los márgenes de la negociación (precios máximos/mínimos).

Así también, mediante un contrato de promesa pueden superarse ciertos obstáculos presentes durante la negociación (incertidumbre sobre la cosa, indeterminación del precio), otorgando por anticipado el consentimiento para el contrato posterior, pero sujeto a la condición de que se cumplan determinados requisitos (estudio de títulos, due diligence, aprobación de financiamiento). Algo similar ocurre con las opciones y ofertas irrevocables, donde una sola parte otorga por anticipado su consentimiento, quedando al arbitrio de la otra parte la celebración del contrato posterior.

2. Contratos de intercambio. Son aquellos que sirven para transferir bienes y servicios. Así por ejemplo, mediante una compraventa una parte renuncia perpetuamente a la cosa, a cambio de la renuncia también perpetua que realiza la otra parte sobre el precio.

Algo similar ocurre con el arrendamiento: una parte renuncia temporalmente a un bien o servicio, a cambio de la renuncia que realiza periódicamente la otra parte sobre una suma de dinero. Así también, mediante el mutuo y las operaciones de crédito de dinero una parte renuncia al control que tiene sobre una suma de dinero, a cambio de la renuncia futura que realizará la otra parte sobre una suma igual más intereses.

3. Contratos de colaboración. Son aquellos que sirven para compartir bienes y servicios. Así por ejemplo, mediante un mandato una parte comparte con la otra parte el control que tiene sobre un negocio, para que esta última lo administre por cuenta y riesgo de la primera. Algo similar ocurre con las sociedades de personas: dos o más partes comparten determinados bienes y servicios, para administrarlos de común acuerdo y repartirse los beneficios.

En contraste, las sociedades de capital constituyen un terreno intermedio entre los contratos de intercambio y los de colaboración, ya que dos o más partes renuncian a perpetuidad a determinados bienes y servicios, a cambio de un derecho representativo en la empresa que les permitirá compartir con sus socios ciertas decisiones importantes, elegir a los administradores y repartirse los beneficios.

4. Contratos de garantía. Son aquellos que permiten asegurar el cumplimiento de una obligación. Así por ejemplo, las garantías de propiedad condicionan la transferencia al cumplimiento de una obligación (reserva de dominio, derecho legal de retención), las garantías abstractas facilitan el cobro extrajudicial de los perjuicios derivados del incumplimiento (boleta bancaria,

cheque), las garantías reales permiten un cobro preferente sobre un bien determinado (hipoteca, prenda), y las garantías personales agregan un nuevo patrimonio para realizar el cobro de una obligación (fianza, aval).

Como se aprecia, mientras los contratos preparatorios permiten proteger los intereses de la empresa al comienzo de su relación de negocios con los distintos factores productivos, los contratos de garantía hacen lo propio respecto del final de esa relación contractual. Por esta razón, el nexo de contratos que constituye una empresa suele configurarse recurriendo a distintos contratos de intercambio y colaboración, que utilizan además contratos preparatorios para regular la negociación y contratos de garantía para asegurar su cumplimiento.

3.7 CONTRATOS "INTUITO PERSONA" Y CONTRATOS IMPERSONALES⁸

1. Contratos celebrados en atención a la persona o "intuito persona": son aquellos en que una de las partes o ambas son relevantes para contratar en el sentido que un interés ha inducido a uno de los contratantes a escoger a una persona determinada porque está dotada de cualidades o aptitudes personales, o de una especial pericia técnica.

Este contrato se vincula con la obligación de hacer no fungible, además, se presenta especialmente en el caso en que es necesaria una colaboración entre los contratantes, en la que el elemento de confianza adquiere una especial importancia.

Ejemplos de estos contratos en sede patrimonial son el mandato, el comodato, la fianza, la sociedad, la donación, el contrato de trabajo y el arrendamiento de servicios.

Consecuencias del carácter intuito persona del contrato:

- 1) La esencialidad del error en la persona del otro contratante, que dará derecho a solicitar la rescisión del contrato;
- 2) La pretensión del otro contratante a que el contrato sea ejecutado personalmente por la contraparte y no por otros, con el consiguiente derecho de rehusarse a recibir la prestación si ésta fuese obra de otra persona;
- 3) La intransmisibilidad del contrato al heredero del sujeto a quien incumbe la prestación;
- 4) La imposibilidad de ceder los derechos y las obligaciones que origina el contrato.

2. Contratos impersonales: son aquellos en que la persona del contratante es jurídicamente indiferente. En estos casos, el contrato no se celebra en consideración a la persona del otro contratante. Cualquiera podría ser la contraparte. Por ende, el error no será esencial ni dará derecho a pedir la rescisión del contrato; será admisible la ejecución por un tercero extraño al

⁸ Orrego Acuña, Juan Andrés, Teoría General del Contrato, Pág. 50

contrato (como ocurre cuando se debe, por ejemplo, una suma de dinero); operará la transmisión del contrato al heredero del contratante fallecido; será factible que cualquiera de las partes haga cesión del contrato y sea entonces sustituido por un tercero en la relación jurídica, etc.

3.8 CONTRATOS DE FAMILIA Y CONTRATOS PATRIMONIALES.

1. Contratos de familia: Los contratos de familia se refieren a la situación de una persona dentro de su familia y a sus relaciones con los restantes integrantes de la misma.

Son contratos de este tipo:

- El contrato de matrimonio;
- El acuerdo de unión civil
- El pacto a que alude el artículo 45 de la Ley 19.620, sobre Adopción de Menores;
- El pacto mediante el cual los padres que viven separados, convienen que el cuidado personal del hijo menor corresponde al padre (artículo 225, inciso 2º del Código Civil);
- etc.

Algunos de los contratos de familia tienen también resultados patrimoniales, como ocurre, por lo demás, con el propio contrato de matrimonio, pero seguirán siendo contratos de familia, en cuanto a que junto a ellos contienen elementos extrapatrimoniales, que generan deberes jurídicos no apreciables en dinero, como ocurre con el respeto mutuo, el deber de fidelidad, convivencia, cohabitación, etc.

2. Contratos patrimoniales: Son aquellos destinados a crear, modificar, transferir o extinguir un derecho susceptible de valuación en dinero. En este caso, la totalidad del contrato regula aspectos patrimoniales. Tal es el caso de todos los contratos regulados en el Código Civil, salvo el matrimonio. Algunos de estos contratos pertenecen a la esfera del Derecho de Familia, pero en cuanto tienen un contenido puramente patrimonial, no son contratos de familia; tal es el caso de las capitulaciones matrimoniales convenidas antes del matrimonio, cuando generan derechos y obligaciones para los esposos.

CAPÍTULO 4. CATEGORÍAS CONTRACTUALES.

4.1 EL CONTRATO DIRIGIDO.

Es uno de los mecanismos para solucionar los abusos en la adhesión.

Las reglas legales en materia de contratos, casi siempre son supletorias de la voluntad de las partes. En los contratos dirigidos, la reglamentación legal tiene carácter imperativo, sin que las partes puedan alterar, en el contrato particular, lo establecido de manera general y anticipada por el legislador, sea en su contenido y efectos, o en la persona con la cual se debe contratar.

Ej. Contrato de trabajo, contrato de matrimonio y contrato de arrendamiento de predios urbanos.

4.2 EL CONTRATO FORZOSO.

1. Concepto de contrato.

Contrato forzoso: aquel en que el legislador obliga a celebrar o dar por celebrado.

No están en esta situación el contrato que hay que celebrar como consecuencia de un contrato preparatorio libremente acordado, ni el contrato necesario por circunstancias excepcionales de hecho (Ej. Depósito necesario).

2. Clasificación de los contratos forzosos.

❖ **Contrato forzoso ortodoxo:** Se forma en dos etapas.

- En primer lugar, interviene un mandato de autoridad que exige contratar.
- Luego, quien recibe el mandato, procede a celebrar el contrato respectivo, pudiendo generalmente elegir a la contraparte y discutir con ella las cláusulas del negocio. En esta segunda etapa, el contrato conserva la fisonomía de los contratos ordinarios.

Casos de contratos forzosos ortodoxos en la legislación chilena.

Ej.

1) El del artículo 775 del Código Civil, en el usufructo para el ejercicio del derecho de usufructo: "El usufructuario no podrá tener la cosa fructuaria sin haber prestado caución suficiente de conservación y restitución...".

2) El del artículo 374, inciso 1º, del Código Civil, para el ejercicio del cargo de guardador: "Para discernir la tutela o curaduría será necesario que preceda el otorgamiento de la fianza o caución a que el tutor o curador esté obligado."

3) El del artículo 1 de la Ley número 18.490, que establece el seguro obligatorio de accidentes personales causados por circulación de vehículos motorizados. Se trata de un seguro contra riesgo tanto por accidentes personales, como por los daños causados a vehículos con ocasión de un accidente de tránsito. Además, la norma introduce aquí una prenda sin desplazamiento legal: "Todo vehículo motorizado que para transitar por las vías públicas del territorio nacional requiera de un permiso de circulación, deberá estar asegurado contra el riesgo de accidentes personales a que se refiere esta ley. Además, si el vehículo no contare con un seguro por los daños personales y materiales causados con ocasión de un accidente de tránsito, el vehículo conducido quedará gravado con prenda sin desplazamiento y será puesto a disposición del tribunal respectivo, de forma de responder por las indemnizaciones contempladas en esta ley.

4) El del artículo 36, inciso 1º, de la Ley Nº 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, que ordena al administrador de un condominio contratar un seguro contra incendios: "Salvo que el reglamento de copropiedad establezca lo contrario, todas las unidades de un condominio deberán ser aseguradas contra riesgo de incendio, incluyéndose en el seguro de los bienes de dominio común en la proporción que le corresponda a la respectiva unidad.

5) Contratos forzosos implícitos: la ley impone una conducta y obligación, que no puede cumplirse sin celebrar un contrato. Ej. El del artículo 2151 del Código Civil, en el contrato de mandato: se ha señalado que habría un contrato forzoso implícito en el caso de que el mandatario actúe a nombre propio y no a nombre de su mandante. Si así ocurre, el primero está obligado, mediante un contrato, a traspasarle al segundo todos los derechos reales y personales y todas las obligaciones que adquirió o contraído, respectivamente, al contratar con los terceros en ejecución de la gestión confiada.

- ❖ **Contrato forzoso heterodoxo:** Se caracteriza por la pérdida completa de la libertad contractual. Un acto único del poder público determina:
- El vínculo jurídico.
 - Las partes y el contenido negocial.

Casos de contratos forzosos heterodoxos en la legislación chilena.

Ej.

1) El de los artículos 2305 en relación al 2081 del Código Civil, que establecerían, a juicio de algunos, una suerte de contrato de mandato tácito y recíproco, entre los socios y entre los comuneros. La ley lo entiende celebrado, sin que los que integran una sociedad, en un caso, o los indivisarios, en otro caso, hayan manifestado su voluntad al efecto.

2) En los contratos leyes, normalmente el legislador tiene por celebrado

un contrato.

3) En la hipoteca legal del Art. 660 y 662 del Código de Procedimiento Civil. Dispone el artículo 660: "Salvo acuerdo unánime de las partes, los comuneros que durante el juicio divisorio reciban bienes en adjudicación, por un valor que exceda del ochenta por ciento de los que les corresponda percibir, pagarán de contado dicho exceso. La fijación provisional de éste se hará prudencialmente por el partidor."

A su vez, establece el artículo 662: "En las adjudicaciones de propiedades raíces que se hagan a los comuneros durante el juicio divisorio o en la sentencia final, se entenderá constituida hipoteca sobre las propiedades adjudicadas, para asegurar el pago de los alcances que resulten en contra de los adjudicatarios, siempre que no se pague de contado el exceso a que se refiere el artículo 660. Al inscribir el conservador el título de adjudicación, inscribirá a la vez la hipoteca por el valor de los alcances. / Podrá reemplazarse esta hipoteca por otra caución suficiente calificada por el partidor."

4) El del artículo 2401 del Código Civil, referido a la prenda tácita: la norma señala:

"Satisfecho el crédito en todas sus partes, deberá restituirse la prenda. Pero podrá el acreedor retenerla si tuviere contra el mismo deudor otros créditos, con tal que reúnan los requisitos siguientes:

1º Que sean ciertos y líquidos;

2º Que se hayan contraído después que la obligación para la cual se ha constituido la prenda;

3º Que se hayan hecho exigibles antes del pago de la obligación anterior."

3. Carácter propiamente contractual de los contratos forzosos.

El problema surge especialmente a propósito del contrato forzoso heterodoxo, pues en él, la voluntad pierde toda autonomía.

La solución está en distinguir entre:

- el contrato como acto de constitución de la relación jurídica
- y el contrato como relación jurídica constituida.

El contrato es ambas cosas, pero hay que separarlas. Normalmente existe relación causal entre ambas. Pero es un error pretender que el acto de constitución sólo puede consistir en un acuerdo de voluntades. Un contrato puede quedar configurado:

1) Por la voluntad con la cooperación de las normas legales: caso de los contratos nominados e innominados en que existe real acuerdo de voluntad, de los contratos de adhesión y de los contratos estandarizados.

2) Por la norma legal con la cooperación de la voluntad: caso de los contratos dirigidos y de los contratos forzosos ortodoxos.

3) Por la norma legal sin la intervención de la voluntad: caso de los contratos forzosos heterodoxos.

4. Supremacía de la obligación contractual sobre la obligación legal.

Muchas veces el legislador prefiere situar una relación jurídica en el marco contractual, en lugar de situarla en el marco de las obligaciones puramente legales.

❖ Razones aplicables sólo al contrato forzoso ortodoxo:

1. Ventajas prácticas que resultan de la flexibilidad que posee el contrato y no la ley, y también por razones psicológicas: en la mayoría de los casos, los deudores de obligaciones contractuales las cumplen oportunamente, lo que no ocurre con las obligaciones legales.

2. A diferencia del contrato, que involucra un gran poder de precisión tanto respecto de las partes como del objeto, la ley, disponiendo un mandato, prohibición o permisión genérica y abstracta, encuentra dificultades para conseguir determinar al acreedor o el objeto.

❖ Razón aplicable a ambos contratos forzosos:

Las reglas técnicas del contrato, en cuanto relación jurídica ya constituida, son de las más afinadas que existen en todo el derecho. En ausencia de una elaboración refinada en materia de obligaciones legales, es inteligente y útil que el legislador someta determinadas relaciones jurídicas a la técnica contractual.

4.3 EL CONTRATO TIPO.

1. Contrato tipo y condiciones generales de la contratación.

Contrato tipo: acuerdo de voluntades en cuya virtud las partes predisponen las cláusulas de futuros contratos, que se celebrarán masivamente. El contrato tipo consiste en un acuerdo por el cual se prefijan las condiciones generales de la contratación.

Los contratantes adoptan un formulario, por lo general impreso, destinado a ser reproducido sin alteraciones en múltiples casos posteriores.

Utilidad: con la estandarización de las relaciones jurídicas, la fase de negociaciones precontractuales se ha reducido, y de esto ha resultado una economía de tiempo y una simplificación de las transacciones. Los contratos tipo han redundado en la aparición de reglamentaciones más acabadas y realistas.

Desventaja: implican un peligro, pues los contratos tipos unilaterales suelen ser el instrumento que emplean las empresas para imponer cláusulas abusivas a la contraparte.

2. Clasificación de los contratos tipo.

1) Contrato tipo unilateral o cartel:

- Quienes concluyen el contrato tipo destinado a fijar las condiciones generales del tráfico comercial son grupos económicos o empresas cuyos intereses son convergentes.
- Los futuros clientes no participan en el acto jurídico destinado a fijar la fórmula tipo.
- Hay aquí un contacto estrecho con el contrato por adhesión. La diferencia está en que las características del contrato tipo son la redacción previa y la generalidad con que se aplica; en cambio, el contrato de adhesión se distingue por la desproporción entre el poder negociador del oferente y del aceptante.
- Ejemplo: Seguro, transporte aéreo y marítimo y acuerdos entre comerciantes y distribuidores para uniformar los precios de venta al público.

2) Contrato tipo bilateral:

- Las partes que participan en la conclusión del contrato tipo tienen intereses divergentes.
- En este caso, no hay contacto con la adhesión.
- Ejemplo: Convenciones colectivas de trabajo acordadas por los representantes de los trabajadores y de los empleadores.

Es importante tener presente que el contrato tipo tiene eficacia jurídica desde que es celebrado, creando para quienes concurren a su conclusión precisamente la obligación de respetar sus cláusulas (las condiciones generales) en los contratos individuales que se celebren.

Las condiciones generales de la contratación no siempre tienen como fuente un contrato tipo. La prerredacción de los contratos puede derivar de la voluntad exclusiva de una persona (por lo que no hay contrato previo), y cada contrato que se celebre en base a ese modelo es un contrato por adhesión.

Si las condiciones generales son fruto de un contrato tipo unilateral, los contratos posteriores serán habitualmente por adhesión. En cambio, si son fruto de uno bilateral, justamente se evita la adhesión.

Otro fenómeno de estandarización de los contratos se presenta a propósito del alcance de determinadas palabras o términos de uso frecuente. Ej. Incoterms.

Diferencias entre Contrato tipo vs. Contrato colectivo vs. Contrato de adhesión (Propuestas por la doctrina italiana).

- Formulación de las cláusulas:
 - El contrato colectivo contiene cláusulas formuladas abstractamente, que deben incluirse en los esquemas de los contratos individuales,

pero no proporciona estos esquemas.

- el contrato tipo es ya, él mismo, el esquema concreto del contrato, de manera que las partes no tienen que agregar nada más que su firma.
- Contenido de la contratación:
 - Mientras el contrato colectivo concierne únicamente a la materia del trabajo (esto, válido para el derecho italiano),
 - el contrato tipo y el contrato de adhesión pueden operar en las relaciones contractuales ordinarias entre individuos.
- Relación entre las partes:
 - Por regla general, se recurre al contrato tipo, cuando los contratantes futuros forman parte, ambos, de categorías contrapuestas y organizadas de interesados.
 - Se recurre en cambio al contrato de adhesión cuando, faltando la organización de una de las categorías de interesados, la previa disposición no puede ser sino obra de una de las partes, componente de la única categoría organizada.
- Elaboración de su contenido:
 - El esquema del contrato tipo puede ser el resultado de una elaboración de su contenido desarrollada en paridad de condiciones por los representantes de las dos categorías de los futuros contratantes interesados;
 - El esquema del contrato de adhesión es elaborado siempre por la única parte que se ha denominado como económicamente más fuerte y en el que, por lo tanto, existe disparidad de condiciones. Por lo tanto, cuando también el contrato tipo es elaborado y su contenido es establecido de antemano por una sola de las partes (como sería el que algunos llaman contrato tipo unilateral o cartel), coincide con el contrato de adhesión.
- Estipulación verbal o escrita:
 - No debe excluirse, en principio, que el contrato de adhesión se estipule verbalmente;
 - El contrato tipo presupone orgánicamente el uso del documento, es decir, del formulario.

4.4 EL CONTRATO LEY.

1. Fundamentación.

Para fomentar el desarrollo de determinadas actividades productivas, recaudar fondos del sector privado, o en general alcanzar metas económicas o sociales, el Estado otorga franquicias o regalías. Pero este estímulo no es eficiente si se tiene el temor de que los gobernantes modifiquen la ley vigente y retiren las franquicias. Para eso se crea el contrato ley.

2. Concepto.

Contrato ley: aquel por el cual el Estado garantiza que en el futuro no modificará ni derogará las franquicias contractualmente establecidas.

La ley puede dictarse antes o después del contrato.

El ejemplo clásico de contrato ley era el DL 600 sobre Estatuto de la Inversión Extranjera, que garantizaba a los inversionistas una absoluta invariabilidad respecto a los términos de sus inversiones en nuestro país. Dicha norma ha sido derogada por la ley 20.848, de 2015.

3. Jurisprudencia.

La jurisprudencia ha respaldado la eficacia de los contratos leyes, y ha señalado que el Estado no puede unilateralmente desahuciarlos, porque se trata de convenciones de carácter bilateral. Los beneficios que otorga son para los terceros un derecho adquirido.

4. Crítica a los contratos leyes.

Hay quienes sostienen una opinión diversa a la de la Corte Suprema, señalando que estos contratos son una inadmisibile enajenación de la soberanía nacional, pues no obstante que en Derecho Público sólo se puede hacer lo que la ley expresamente permite, sin una autorización legal el Poder Legislativo se cercenaría a sí mismo la facultad de modificar o derogar normas preexistentes. Para esta postura, la Corte Suprema cometería un error, al concebir únicamente desde una perspectiva individualista un problema de interés general de la Nación (como es establecer tributos), aplicando criterios de derecho privado donde habría correspondido resolver en conformidad al derecho público.

5. Situación actual de los contratos leyes.

Hoy en día, es derecho vigente en virtud del Art. 19 N° 24 de la CPR que los créditos derivados de los contratos son intangibles. Existe propiedad sobre los derechos personales engendrados por los contratos, y nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de una ley expropiatoria. Si una ley que no es expropiatoria, modifica o priva a un acreedor de sus derechos personales, esa ley es inconstitucional.

A fortiori, si los efectos de los contratos ordinarios son intangibles, menos podría el legislador alterar las franquicias obtenidas en virtud de un contrato ley.

4.5 EL SUBCONTRATO.

1. Concepto.

Subcontrato: nuevo contrato derivado y dependiente de otro contrato previo

de la misma naturaleza.

2. Casos de subcontratos.

El CC reguló los subcontratos de:

- subarrendamiento,
- delegación del mandato y
- subfianza.

Además, va implícita la figura del subcontrato en:

- el contrato de construcción por suma alzada,
- y en el contrato de sociedad.

En el CCom, expresamente se admite a propósito de los contratos de transporte terrestre y de mandato.

Al margen de estos casos, la subcontratación puede tener como antecedente contratos base atípicos.

3. Requisitos del contrato base.

1. Debe ser de ejecución diferida o de tracto sucesivo.
2. Es necesario que no sea traslativo de dominio, pues de lo contrario, no hay subcontrato, sino un contrato nuevo.

4. Partes que intervienen en la subcontratación.

Desde el punto de vista subjetivo, se caracteriza por la presencia de 3 partes:

- el primer contratante, que sólo es parte del contrato base;
- el segundo contratante o intermediario, que es parte en ambos contratos;
- y
- el tercer contratante, que sólo es parte del subcontrato.

5. Clases de subcontratos.

a) Subcontratación propia: aquella en que existe identidad esencial entre el contrato base y el subcontrato, como ocurre con el arrendamiento y el subarrendamiento.

Subcontratación impropia: aquella en que no existe identidad entre el contrato base y el subcontrato, como acontece por ejemplo entre el arrendamiento y el comodato. En este último caso, el arrendatario subcontrata, cediendo en comodato el bien que a su vez le habían cedido en arriendo.

6. Relación entre el contrato base y el subcontrato.

- Desde el punto de vista objetivo, se caracteriza por la dependencia del subcontrato al contrato base. Como el intermediario da origen al

subcontrato usando su posición de parte en el contrato base, debe actuar exclusivamente con los derechos y obligaciones que éste le otorga.

- Las prestaciones a las cuales obliga el subcontrato deben ser de igual naturaleza que las prestaciones derivadas del contrato base.
- Finalmente, si se extingue el contrato base, se extingue el subcontrato.
- Terminado el contrato base, hay inoponibilidad de ejecución del subcontrato (excepcionalmente, no ocurre lo anterior respecto de la subfianza, Art. 2383 CC).
- No existe una regla uniforme en cuanto a la posibilidad de que el primer contratante pueda accionar directamente en contra del tercer contratante o que éste pueda accionar directamente en contra del primero.

7. Subcontrato vs. Cesión de contrato.

Cesión de contrato: traspaso por uno de los contratantes a un tercero de su íntegra posición jurídica en un contrato determinado, lo que debe hacerse con la concurrencia de la voluntad del cocontratante primitivo, y desapareciendo definitivamente el cedente del escenario del contrato.

En el subcontrato:

- Es innecesaria la voluntad del primer contratante.
- Además, el intermediario emplea sólo una parte de los derechos y obligaciones derivados del contrato base.
- Ninguna de las partes del contrato base desaparece.
- Entre el contrato base y el subcontrato hay una relación de simultaneidad; en la cesión de contrato, la relación es substitutiva, no existen simultáneamente dos entidades jurídicas con existencia propia, sino que una sola, que después es reemplazada por otra.

4.6 EL AUTOCONTRATO.

1. Concepto.

Autocontrato: acto jurídico que una persona celebra consigo misma, sin que sea menester la concurrencia de otra, y en el cual ella actúa, a la vez:

- i. ya sea como parte directa y como representante de la otra parte;
- ii. ya sea como representante de ambas partes;
- iii. ya sea como titular de dos patrimonios sometidos a regímenes jurídicos diferentes.

2. Hipótesis de autocontratos.

Hay 3 series de casos:

1. El sujeto que interviene actúa tanto a nombre propio como a nombre ajeno.
Ej. Mandatario que compra para sí lo que el mandante le ha ordenado vender.

2. Situaciones de doble representación. Ej. Mandatario que lo es tanto del vendedor como del comprador.

3. Casos independientes de la representación. Ej. Partición consigo mismo. Dos hipótesis:

- a) En la sociedad conyugal, mujer que aporta un terreno del cual es copropietaria, y luego adquiere con dineros de su patrimonio reservado la cuota del tercero.
- b) Heredero a quien se ha concedido la posesión provisoria de los bienes del desaparecido, que además era copropietario de dichos bienes con él.

3. Naturaleza jurídica del autocontrato.

1) Es un acto jurídico unilateral (Postura de don Arturo Alessandri): es imposible pretender encuadrar el autocontrato dentro de un concepto que, como el del contrato, supone necesariamente un concurso de voluntades.

Es un acto híbrido, porque requiere una sola voluntad, como el acto unilateral, pero pone dos patrimonios en relación, como el contrato.

2) Es un contrato (Postura de don Luis Claro Solar): si un acto jurídico produce obligaciones contractuales, importa en realidad un contrato, aunque sea de naturaleza especial. Esta tesis se basa en la idea de que en la representación, el representante no manifiesta su propia voluntad, sino la del representado (teoría de la representación ficción). Pero esto tiene dos inconvenientes:

- i. No es aplicable a la tercera serie de casos.
- ii. Se basa en la idea de representación ficción, que ha sido superada por la de representación modalidad.

Para don Jorge López Santa María el autocontrato es siempre un contrato. Por razones de orden práctico, es jurídicamente posible que la personalidad de un individuo se desdoble, de modo tal que la voluntad del sujeto que autocontrata simultáneamente se exterioriza a diversos títulos. Además, hay que recordar que debemos analizar funcionalmente el contrato como relación jurídica ya constituida, no siendo de la esencia el acuerdo de voluntades como generador del contrato (como en los contratos forzosos heterodoxos).

4. Restricciones y prohibiciones al autocontrato.

La regla general es la validez del autocontrato. Pero por diversas razones, como proteger a los incapaces o evitar que una misma persona represente intereses incompatibles, las legislaciones prohíben algunos autocontratos, y sujetan a otros al cumplimiento previo de formalidades habilitantes.

Ejemplos de casos en que la ley restringe el autocontrato:

- Art. 2144 CC: "No podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona,

comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere con aprobación expresa del mandante.”;

- Art. 2145 CC: “Encargado de tomar dinero prestado, podrá prestarlo él mismo al interés designado por el mandante, o a falta de esta designación, al interés corriente; pero facultado para colocar dinero a interés, no podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante.”;
- Art. 412, inciso 1º CC, respecto de las guardas: “Por regla general, ningún acto o contrato en que directa o indirectamente tenga interés el tutor o curador, o su cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de sus hermanos, o de sus consanguíneos o afines hasta el cuarto grado inclusive, o alguno de sus socios de comercio, podrá ejecutarse o celebrarse sino con autorización de los otros tutores o curadores generales, que no estén implicados de la misma manera, o por el juez en subsidio.”

Ejemplos de casos en que la ley prohíbe el autocontrato:

- Art. 412, inciso 2º CC: “Pero ni aun de este modo (o sea, en la forma señalada en el inciso 1º) podrá el tutor o curador comprar bienes raíces del pupilo, o tomarlos en arriendo; y se extiende esta prohibición a su cónyuge, y a sus ascendientes o descendientes.”;
- Art. 1796 CC: “Es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente, y entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad.”¹⁹⁹

La doctrina entiende que el autocontrato es excepcional. Ello, ante la posibilidad de que el representante sacrifique el interés del representado, esto es, que ante el conflicto u oposición de intereses, el que actúa (que representa al interés ajeno) lo resuelva en beneficio propio.

En general, se entiende que el autocontrato será válido:

- 1) Cuando el representado haya autorizado especialmente la conclusión del contrato;
- 2) Si el representado ratifica el acto; y
- 3) Cuando, aun sin la autorización del representado, el contenido del contrato está determinado por la ley, de manera que quede excluida la posibilidad del conflicto de intereses entre representante y representado.

4.7 EL CONTRATO POR PERSONA A NOMBRAR Y EL CONTRATO POR CUENTA DE QUIEN CORRESPONDA.

1. Contrato por persona a nombrar:

- Concepto: es aquel en que una de las partes se reserva la facultad de designar, mediante una declaración posterior, a la persona que adquirirá retroactivamente los derechos y asumirá las obligaciones inicialmente

radicados en su patrimonio.

Se caracteriza por la inmutabilidad de una de las partes y por el carácter fungible o alternativo de la otra.

- Recepción en nuestra legislación: El CC desconoce esta figura. No así el Código de Comercio, que la reconoce al tratar de la comisión (Art. 256 CCom). Puede el comisionista reservarse el derecho de declarar más tarde por cuenta de qué persona celebra el contrato. Hecha la declaración, el comisionista quedará desligado de todo compromiso, y la persona nombrada lo sustituirá retroactivamente en todos los derechos y obligaciones resultantes del contrato”.
- Ejemplo:
 - El mandante desea que su nombre permanezca desconocido porque quiere adquirir un inmueble colindante al suyo y si el vecino lo sabe subirá el precio. Instruye entonces al mandatario para que celebre una compraventa por persona a nombrar.
 - Otra ejemplo, en este mismo caso, sería la del mandato sin representación: el mandatario finge ante el vendedor que está actuando a nombre propio, comprando para sí, lo que permite el Art. 2151 CC.
- Improcedencia de esta figura en contratos intuitu persona: Tratándose de un contrato por persona a nombrar, el tercero que contrata con el mandatario sabe que existe un mandato, pero ignora la identidad del mandante. Lo anterior nos permite concluir que el contrato por persona a nombrar es inconcebible tratándose de actos jurídicos intuitu persona.
- Plazo para declarar por quien se contrata: La declaración del contratante “fungible” (sustituible), designando a la persona que lo subrogará y ocupará su mismo lugar jurídico, debe formularse dentro de un plazo determinado.
 - Si la declaración designando al nuevo contratante no se emite dentro del plazo estipulado o el plazo legal, o si la declaración no surtiere efectos, el contrato tendrá fuerza obligatoria entre los contratantes originarios.
 - Si la declaración se realiza dentro del plazo pertinente, la persona nombrada adquiere la posición de contratante con efecto retroactivo al día de la formación del contrato, como si hubiese estipulado en propia persona. De esta manera, no hay en ningún momento falta de certeza jurídica acerca de la persona del contratante.
- Diferencias entre el contrato por persona a nombrar vs. representación y agencia oficiosa.

El contrato por persona a nombrar no debe confundirse con otras figuras, que presentan ciertas semejanzas.

- No es un caso de representación, porque quien participa en el contrato declara en nombre propio y no en nombre de otro, y si no hace la declaración de nombramiento, habrá estipulado en su propio interés.
- No es un caso de gestión de negocios ajenos, ya que el nombre de la persona no se invoca en el momento de la estipulación del contrato y, cuando se invoca, a través del nombramiento, la declaración de aceptación de la persona nombrada excluye, con efecto retroactivo, la representación.
- Tampoco es un caso de estipulación a favor de otro, porque ésta implica que el contrato produce efectos a favor del estipulante y del tercero y, además, el tercero no es parte del contrato.
- Por último, no es un caso de promesa de hecho ajeno, porque en ésta se obliga el promitente a una prestación del tercero, mientras que en el contrato por persona a nombrar se obliga a un hecho propio y eventualmente al hecho de un tercero, si se efectúa el nombramiento en el plazo pactado.

2. Contrato por cuenta de quien corresponda:

- Concepto: aquel en el cual una de las partes queda inicialmente indeterminada, en la seguridad de que posteriormente será especificada.

Al celebrarse el contrato, uno de los participantes tiene formalmente el carácter de parte, pero será necesaria y forzosamente reemplazado más tarde por el verdadero o real contratante: por quien corresponda.

- Se trata de un contrato a beneficio de un tercero (mientras tanto indeterminado) mediante el cual es posible cautelar un interés suyo, en espera de que se revele quién es el sujeto de tal interés.
- Al momento de celebrarse el contrato uno de los participantes tan solo tiene formal o aparentemente el carácter de parte, puesto que necesaria y forzosamente será reemplazado más tarde por el verdadero contratante, "quien corresponda".

Diferencias entre el contrato por persona a nombrar y el contrato por cuenta de quien corresponda:

1) Partes.

- Contrato por persona a nombrar: las partes reales son el contratante inmutable y el contratante fungible. Este último puede serlo en forma definitiva si no nombra válida y oportunamente al reemplazante.

- Contrato por cuenta de quien corresponda: hay también un contratante inmutable, pero el otro, el contratante formal, no es parte. Las partes son siempre el contratante conocido desde el comienzo y el contratante real.
- 2) Designación del contratante.
- Contrato por persona a nombrar: la designación del reemplazante (si se produce) es obra de una de las partes, que se reservó el derecho a designarlo.
 - Contrato por cuenta de quien corresponda: la individualización del contratante (que necesariamente tendrá lugar) puede ser obra de una de las partes o el resultado de un hecho extrínseco.

CAPÍTULO 5. LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN.

5.1 LA DOCTRINA DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD.

1. Concepto.

Principio de la autonomía de la voluntad: doctrina de filosofía jurídica, según la cual toda obligación reposa esencialmente sobre la voluntad de las partes. Esta es, a la vez, la fuente y la medida de los derechos y de las obligaciones que el contrato produce.

Esta doctrina sirve de telón de fondo a la mayoría de los principios fundamentales de la contratación, los cuales pueden considerarse subprincipios de la autonomía de la voluntad.

Ahora bien, es necesario mencionar que ciertos sectores de la doctrina contemporánea son críticos con respecto al dogma de la autonomía de la voluntad. Como veremos en la sección siguiente, existen buenas razones, tanto filosóficas como económicas, para dudar de la autonomía de la voluntad como fundamento de la contratación en sus formas contemporáneas.

2. Subprincipios de la autonomía de la voluntad.

- 1) Consensualismo.
- 2) Libertad contractual.
- 3) Fuerza obligatoria.
- 4) Efecto relativo.

- Los dos primeros dicen relación con la formación del contrato;
- los dos últimos, con los efectos del contrato.

Hay un quinto principio, independiente de la autonomía de la voluntad: la buena fe, que se proyecta sobre todo el íter contractual.

5.1.1 FUNDAMENTO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. BOSQUEJO DE CRÍTICAS.

1. Fundamento filosófico.

Reposa en la afirmación de la libertad natural del ser humano, resultado del racionalismo filosófico, y que quedó plasmado en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Así, la sociedad debe reconocerle a la persona las más amplias garantías individuales, como expresión de la libertad que le pertenece naturalmente.

La persona no puede quedar vinculada por obligaciones en las cuales no ha consentido y, recíprocamente, toda obligación querida por la persona debe

producir efectos.

La misión del derecho positivo es asegurar a las voluntades el máximo de independencia que resulte compatible con la libertad ajena. Dándole una fuerza obligatoria a los contratos libremente celebrados, se garantiza tanto la libertad como la responsabilidad de cada contratante por los actos que realiza.

Estas ideas, que consagran el individualismo filosófico, tienen un vicio esencial: no toman en suficiente consideración de la naturaleza social del individuo. La voluntad del ser humano no es un absoluto. Tampoco es la única fuente de los derechos y obligaciones. El dogma de la autonomía de la voluntad, tomada como un principio absoluto, no logra dar cuenta de estos matices.

Además del marcado individualismo del dogma de la autonomía de la voluntad, la doctrina contemporánea ha subrayado su insuficiencia como principio fundamental de la contratación. En primer lugar, es necesario destacar la posición del profesor Carlos Pizarro Wilson en relación al artículo 1545, que tradicionalmente se concibe como la consagración normativa de la autonomía de la voluntad. Según Pizarro⁹, un análisis de las fuentes del artículo 1134 del *code* frances, norma en la cual se inspira nuestro artículo 1545, permite concluir que dicha norma no se funda en la autonomía de la voluntad, sino en la equidad y la moral.

Por otro lado, la idea del ser humano racional y capaz de autodeterminarse sería ficticia. Muy por el contrario, el hecho de que los contratos tengan una fuerza obligatoria se debe precisamente al hecho de que el ser humano es un ser que se guía más frecuentemente por sus apetitos y por su instinto que por la fría razón. La obligatoriedad del contrato sería una forma de evitar que los contratantes sucumban al impulso de incumplir, no una forma de reconocerles su autonomía.

Adicionalmente, la idea de la autonomía de la voluntad no parece coherente con la forma de la contratación. En primer lugar, en sociedades de mercado como la nuestra, ningún proyecto de vida razonable puede llevarse adelante sin contratar. En ese sentido, dado que el sujeto moderno no tiene otra opción que contratar para satisfacer sus intereses, la autonomía no parece un fundamento sólido. Adicionalmente, la contratación por adhesión, que reduce a la mayoría de los contratantes a la posición de emitir un "sí" o un "no", no parece coherente con la autonomía como fundamento de la contratación. Por último, aunque dejásemos de lado las críticas mencionadas, la autonomía de la voluntad solo serviría para fundamentar las cláusulas expresamente pactadas por las partes. Esto entra en contradicción con la existencia de abundantes normas de carácter imperativo que se incorporan en la contratación contemporánea.

⁹ Pizarro, C. *Notas críticas sobre el fundamento de la fuerza obligatoria del contrato. Fuentes e interpretación del artículo 1545 del Código Civil Chileno*. Revista Chilena de Derecho. 2004. Pp. 225-237-

2. Fundamento económico.

La autonomía de la voluntad es el fruto del liberalismo económico. El contrato garantiza la justicia y la utilidad social, pues el libre juego de las iniciativas individuales asegura espontáneamente la prosperidad y el equilibrio económico. Si el derecho objetivo asegura la vigencia absoluta de los contratos libremente celebrados, se maximiza el bienestar social producido por las interacciones naturales del mercado.

Sin embargo, la identidad de lo contractual con lo justo es una falacia: únicamente en circunstancias de real igualdad entre los contratantes, podría tal idea tener alguna verosimilitud. Pero la igualdad de los contratantes, válida en el terreno de los principios, no necesariamente corresponde a la práctica. El dogma de la autonomía de la voluntad desconoce las desigualdades económicas de hecho de los contratantes.

Es igualmente inexacto que la libertad contractual produzca siempre resultados económicos socialmente útiles. La pura espontaneidad de la voluntad de cada agente en el mercado no necesariamente maximiza el bienestar social ni le asegura a la sociedad prosperidad y justicia.

5.2 EL PRINCIPIO DEL CONSENSUALISMO CONTRACTUAL

El examen de este principio consiste en averiguar si los contratos surgen a la vida jurídica como simples pactos desnudos, por la sola manifestación de la voluntad de las partes (tesis consensualista), o si es necesario cumplir con formalidades externas al celebrarlos (tesis del contrato como pacto vestido).

Para ser consecuente con el dogma de la autonomía de la voluntad, ha debido afirmarse la vigencia del principio del consensualismo contractual: los contratos quedan perfectos por la sola manifestación de las voluntades internas de las partes. Esto es históricamente falso: casi siempre los contratos han sido formales. El consensualismo sólo surge en los tiempos modernos.

5.2.1 RECAPITULACIÓN Y SUBCLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS CONSENSUALES.

Los contratos que en Chile se llaman consensuales (no solemnes ni reales) muchas veces son formales, en cuanto precisan el cumplimiento de alguna formalidad habilitante, de prueba, de publicidad o convencional.

En consecuencia, tenemos dos grupos de contratos consensuales:

1) Contratos propiamente consensuales: son aquellos que corresponden a la concepción moderna del contrato como pacto desnudo. Por ejemplo: contrato de compraventa de cosa mueble.

2) Contratos consensuales formales: son aquellos contratos que siendo consensuales, en cuanto no son solemnes ni reales, están sin embargo inmersos en el universo de los formalismos, pues requieren, para tener plena eficacia, del cumplimiento de formalidades habilitantes, de prueba, de publicidad o convencionales.

Por ejemplo:

- Art. 9 del Código del Trabajo, que establece que el contrato de trabajo es consensual, pero que no obstante lo anterior, deberá constar por escrito;
- Tratándose del arrendamiento de predios urbanos, cuando el contrato no consta por escrito, "se presumirá que la renta será la que declare el arrendatario" (artículo 20 de la Ley número 18.101).
- En el caso del contrato de depósito, a falta de pacto escrito, será creído el depositario respecto de los aspectos esenciales del contrato (Art. 2217 CC).

5.2.2 EXCEPCIONES Y ATENUANTES AL PRINCIPIO DEL CONSENSUALISMO CONTRACTUAL.

1. Excepciones: contratos solemnes y reales. En ellos, en lugar de regir el principio de que lo que obliga es el mero consentimiento, el ordenamiento jurídico exige que las partes se sometan a la ritualidad prescrita por el legislador.

2. Atenuantes:

1) Formalidades habilitantes: tienen como finalidad brindar protección a los incapaces. Casi siempre consisten en la necesidad de obtener una autorización. Su omisión es sancionada con la nulidad relativa.

2) Formalidades de publicidad: su objetivo es obtener la divulgación o noticia a los interesados de haberse celebrado un acto jurídico. Protegen a los terceros.

Su omisión:

- A veces acarrea la completa ineficacia del acto (Ej. Art. 1723 CC relativo al pacto de separación total de bienes),
- Lo más frecuente es que se sancione con la inoponibilidad.

Consisten en:

- Notificaciones (Ej. Cesión de créditos nominativos),
- Inscripciones (Ej. Embargo sobre bienes raíces),
- Subinscripciones (Ej. Contraescrituras públicas),
- Publicaciones (Ej. Disolución de la sociedad), etc.

Algunos autores las clasifican en:

- Medidas de publicidad sustanciales (cuya omisión acarrea inoponibilidad)

- y de simple noticia (cuya omisión sólo da derecho al afectado a demandar indemnización).

Existen formalidades de carácter fiscal, cuyo incumplimiento impide que el acto se haga valer en sedes judicial y administrativa.

3) Formalidades de prueba: son aquellas que sirven de principal medio de prueba a los actos consensuales, de modo tal que no puede ser acreditado en juicio contradictorio a través de otro medio de prueba, sea porque lo prohíbe la ley (negando un medio de prueba), sea porque la ley dispone que el único medio de probar el negocio es precisamente a través de dicha formalidad (de forma positiva) o sea bien porque la ley altera la carga de la prueba.

- Todas las solemnidades, al mismo tiempo que se exigen en atención a la naturaleza de los actos, juegan ad probationem (Art. 1701 CC).
- Deben extenderse por escrito todos los contratos que contengan la entrega o promesa de una cosa que valga más de 2 UT. La omisión se sanciona con la inadmisibilidad judicial de la prueba de testigos (Arts. 1708 y 1709 CC).
- En el CC y leyes especiales hay otras formalidades de prueba, que también consisten en la escrituración, pero bajo otras sanciones.

Clasificación de las formalidades por vía de prueba en atención a su sanción:

a) Aquellas que prohíben la utilización de un medio de prueba determinado (Negativas) Ejemplo: art. 1709 excluye la prueba de testigos.

b) Aquellas en que el legislador impide la utilización de todos los medios de pruebas, salvo la documental propia de que consta la formalidad (Positivas). Ejemplo: Art. 14 ley 18010. La estipulación de intereses o la exoneración de su pago debe constar por escrito.

c) Aquellas que provocan la alteración de la carga de la prueba. Ejemplo: art. 20 Ley 18801. En los contratos de arrendamiento de predios urbanos si la renta no consta por escrito se presumirá que es la que diga el arrendatario.

4) Formalidades convencionales: son aquellas pactadas por las partes, y cuyo posterior cumplimiento permite que recién el contrato se repunte definitivamente celebrado. El efecto característico es que cualquiera de las partes puede retractarse del contrato mientras la forma pactada no se haya cumplido.

En Chile sólo existen normas especiales sobre formalidades convencionales (Ej. Art. 1802 CC relativo a la compraventa), pero se pueden pactar en cualquier contrato.

5.2.3 VENTAJAS DEL FORMALISMO. REFLEXIONES DE IHERING.

El término 'formalismo' suele ser empleado en un sentido peyorativo: el formalista es el burocrático, el ineficiente. Sin embargo, el formalismo también tiene sus ventajas en el derecho de los contratos. Dado que los contratos materializan la libertad individual, una preocupación especial de los juristas debe ser que el ejercicio de la libertad de cada uno resulte compatible con la de todos. El apresuramiento contractual, las maniobras de contratantes inescrupulosos y el abuso de los expertos hacia los inexpertos son una amenaza a esta compatibilidad de las libertades de cada uno. Por otro lado, el consensualismo puro presenta dificultades probatorias.

Frente a las problemáticas recién descritas, las formas del derecho pueden ser una solución eficaz. Si bien las formalidades pueden implicar costos en cuanto al tiempo y los recursos que requieren, son un mecanismo eficaz para cautelar el correcto ejercicio de la libertad contractual. La siguiente frase de Rudolf Von Ihering, famosa por la profundidad y la simpleza de su contenido, expresa esta idea de buena manera: "Enemiga jurada de la arbitrariedad, la forma es hermana gemela de la libertad. Es, en efecto, el freno que detiene las tentativas de aquellos que arrastran la libertad hacia la licencia; la que dirige la libertad, la que la contiene y la protege."

5.3 EL PRINCIPIO DE LA LIBERTAD CONTRACTUAL Y SU DETERIORO.

La libertad contractual comprende:

1. La **libertad de conclusión**: las partes son libres para contratar o para no contratar, y en caso afirmativo, para escoger al cocontratante.
2. La **libertad de configuración interna de los contratos**: las partes pueden fijar las cláusulas o contenido del contrato.

En Chile no está consagrada positivamente. Las legislaciones que la consagran advierten que no es absoluta, sino que tiene como límites la ley, el orden público y las buenas costumbres. En algunos casos se incluye expresamente la posibilidad de celebrar contratos atípicos.

La mayor ruptura de la libertad contractual desde un punto de vista:

- 1) **Cuantitativo**, se pierde la libertad de configuración interna. Está configurada por el contrato dirigido.
- 2) **Cualitativo**, se pierde la libertad de conclusión. Es el contrato forzoso. En el contrato forzoso heterodoxo, se produce un quiebre total de la libertad contractual.

Cada vez que el legislador, por razones de orden público, fija imperativamente

las cláusulas más relevantes de ciertos contratos u obliga a las partes a celebrarlos, se produce una ruptura del principio de la libertad contractual.

La doctrina distingue los siguientes límites a la libertad contractual:

- 1) Casos en que el esquema del contrato está previamente diseñado, en todo o en parte, por uno solo de los contratantes, de manera que el otro no sea admitido a concurrir a su determinación (Contrato de adhesión).
- 2) Libertad de determinar el contrato está supeditada al respeto a las normas legales imperativas.
- 3) Rechazo a la conclusión de contratos en que se pretende realizar intereses no merecedores de tutela jurídica, según el ordenamiento jurídico, como son los contratos ilícitos, imposibles o en fraude de la ley

5.4 EL PRINCIPIO DE LA FUERZA OBLIGATORIA DE LOS CONTRATOS.

El principio de la fuerza obligatoria de los contratos se expresa en el aforismo *pacta sunt servanda*: los pactos deben observarse; las palabras deben cumplirse; los contratos obligan.

Art. 1545 CC. "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales."

Ahora bien, el hecho de que el legislador asimile ley y contrato no debe inducirnos a confusión. Si bien existen semejanzas entre la ley y el contrato, entre las cuales sobresale la obligatoriedad de ambos, las diferencias son numerosas. Podemos citar las siguientes:

- 1) El contrato reglamenta una situación jurídica particular y en principio sólo produce efectos entre las partes. La ley en cambio contiene un mandato, prohibición o permiso de carácter general y abstracto, que alcanza a todos cuantos se encuentren en los supuestos de hecho previstos en la norma.
- 2) El procedimiento de formación de las leyes en nada se parece a la formación de los contratos.
- 3) El contrato a menudo tiene vida efímera, pues está destinado a extinguirse apenas se cumplan las obligaciones por él generadas. La ley, de ordinario, permanece en el tiempo.
- 4) Si una ley puede derogar expresa o tácitamente a otra ley, no siempre un contrato se deja sin efecto mediante otra convención en sentido inverso, ya que existen contratos, como el de matrimonio, en que es improcedente el mutuo disenso o resciliación; o en otros en que basta un acto unilateral para ponerle término, como el desahucio en el contrato de arrendamiento, o la revocación o renuncia en el mandato.

- 5) La interpretación de las leyes no se efectúa de igual modo que la interpretación de los contratos. A las primeras, se les aplican los arts. 19 a 24 CC; a los segundos, los arts. 1560 a 1566 CC.

5.4.1 FUNDAMENTOS DE LA FUERZA OBLIGATORIA DE LOS CONTRATOS.

El problema de la fundamentación de la fuerza obligatoria de los contratos es uno de los temas clásicos de la filosofía jurídica y moral. El interés que reviste la pregunta por el fundamento de la obligatoriedad del vínculo contractual radica en que su solución debe conjugar distintos valores, como lo son la justicia, la libertad y la eficiencia social. En tal sentido, dicho problema ha sido abordado de diferentes maneras, y con diversas formulaciones por parte de distintos filósofos y juristas. En este apartado, reseñaremos tres posturas que resultan especialmente relevantes, y las consecuencias que, al menos en teoría, debiesen producir sobre los contratos.

En primer lugar, una tradición intelectual asocia la obligatoriedad del contrato a consideraciones sustantivas de justicia. Así, el filósofo griego Aristóteles formuló una noción sustantiva de la justicia como una determinada proporción en la cual se configura una relación de equilibrio o de 'justo medio' entre los individuos. Otros pensadores posteriores como Tomás de Aquino, han sido influenciados por esta noción sustantiva de la justicia. El punto es, para esta tradición, que el contrato es obligatorio porque es justo. La justicia del contrato radica en que ella respeta la relación proporcional entre lo que ofrecen los individuos contratantes, que es lo propio de la justicia.

Resulta interesante notar que, si seguimos el razonamiento de esta fundamentación, el contrato perdería su fuerza obligatoria si dejara de ser justo o, lo que es lo mismo, si las prestaciones del contrato dejaran de ser proporcionales. Esta es precisamente la fundamentación que podría ofrecerse para instituciones tales como la lesión enorme¹⁰.

En segundo lugar, otra tradición intelectual asocia la obligatoriedad del contrato a la autonomía de la voluntad. Immanuel Kant es el autor más emblemático de esta tradición. Kant recurre a la fuerza autovinculante de la voluntad humana, la cual resulta obligatoria para el individuo que se vincula libremente con otro por medio de un contrato. Así, el contrato es obligatorio porque ha sido consentido libremente, con absoluta prescindencia de cualquier consideración sustantiva acerca de la justicia ni la eficiencia social del mismo. Para un pensador como Kant, si el consentimiento ha sido prestado de manera libre y espontánea, no existe consideración de ningún tipo que pueda mellar la fuerza obligatoria del contrato, la cual es concebida como absoluta.

¹⁰ En el siglo XVI, el pensador español Tomás de Mercado acuñó, recogiendo los aportes de distintos autores de esta tradición filosófica, el término "justo precio" para referirse al precio al que debían celebrarse los contratos de compraventa. Consideraba que el precio justo era aquel que fluía espontáneamente de las interacciones sociales, es decir, el precio de mercado.

En tercer lugar, podemos identificar un tercer tipo de fundamentación, que dice relación con consideraciones relacionadas a la eficiencia social del contrato. Esta tradición, que arranca desde el utilitarismo de Bentham y de J.S. Mill, tiene su expresión contemporánea en las escuelas del análisis económico del derecho. En términos generales, este tipo de fundamentación alude a que el cumplimiento de los contratos permite lograr un óptimo de eficiencia social, de modo que los contratos resultan obligatorios precisamente porque su obligatoriedad es una condición para el óptimo de eficiencia social y el consiguiente aumento en el bienestar general de las personas. En otras palabras, los contratos son obligatorios porque resulta socialmente eficiente que así lo sean.

Resulta interesante notar que, puesto en estos términos, podrían haber contratos cuyo incumplimiento sea más eficiente que su cumplimiento. Por ejemplo, si entre el momento de la celebración del contrato y el momento de su ejecución han cambiado radicalmente las circunstancias, en términos que encarecen sumamente la prestación de una de las partes, lo socialmente eficiente sería morigerar la fuerza obligatoria del contrato y permitir el incumplimiento o al menos la revisión del contrato. Bajo este razonamiento, la teoría de la imprevisión sería absolutamente procedente.

Resumiendo, podemos identificar (al menos) tres fundamentaciones distintas de la obligatoriedad del contrato: i) El contrato es obligatorio porque el contrato es justo; ii) El contrato es obligatorio porque el contrato ha sido consentido de manera libre; iii) El contrato es obligatorio porque su obligatoriedad es socialmente eficiente.

5.4.2 LA FUERZA OBLIGATORIA DE LOS CONTRATOS FRENTE AL LEGISLADOR.

La obligatoriedad del contrato se traduce en su **intangibilidad**: el contrato válidamente celebrado no puede ser modificado ni por el legislador ni por el juez.

Sin embargo, la intangibilidad no es absoluta. El propio legislador algunas veces vulnera la fuerza obligatoria del contrato:

1) Leyes de emergencia:

Se trata de leyes de carácter transitorio, dictadas en virtud del acaecimiento de circunstancias excepcionales de hecho, que implican concesión de beneficios a los deudores, no previstos ni queridos en los respectivos contratos.

Ejemplos:

- Las "leyes moratorias" (Ley Nº 17.663, de 1972, que suprimió la reajustabilidad automática de las deudas provenientes de los contratos de mutuo, otorgados para fines habitacionales, por Institutos de Previsión y Servicios Públicos de la Vivienda).
- Leyes que han condonado parte de las deudas que mantenían con la Corporación de Reforma Agraria o los organismos que le sucedieron, los

asignatarios favorecidos con la adjudicación de los inmuebles que fueron expropiados.

- Ley N° 5.001, publicada en el Diario Oficial el 13 de noviembre de 1931, que dispuso en su artículo 1º que la renta de arrendamiento de los predios urbanos y rústicos debía ser pagada, durante su vigencia, con una rebaja del 20% con relación a la que el mismo arrendatario pagaba el 1º de enero de 1931.

2) Normas permanentes:

El legislador transgrede la fuerza obligatoria de un contrato al:

- Interpretar legalmente una cláusula. Ej. Art. 1789 CC, respecto del pacto comisorio calificado: "Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido, se resuelva ipso facto el contrato de venta, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir, pagando el precio, lo más tarde, en las veinticuatro horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda."
- Al pasar por sobre lo acordado por las partes en virtud del acaecimiento de un suceso imprevisto. Ej. Art. 2180 CC: "El comodatario es obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo convenido; o a falta de convención, después del uso para que ha sido prestada. / Pero podrá exigirse la restitución aun antes del tiempo estipulado, en tres casos: (...) 2º Si sobreviene al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa."
- Ordenar la mantención de una relación contractual que había expirado a la luz del título convencional. Ej. Prórrogas automáticas de los contratos de arrendamiento de inmuebles urbanos expirados, los que subsisten durante los plazos de restitución indicados por la ley. Art. 4 inciso 1 de la Ley N° 18.101: "En los contratos de plazo fijo que no excedan de un año, el arrendador sólo podrá solicitar judicialmente la restitución del inmueble, y en tal evento, el arrendatario tendrá derecho a un plazo de 2 meses, contado desde la notificación de la demanda".

3) Leyes especiales que modifican los contratos en curso:

Leyes que se dictan con efecto retroactivo y que vulneran no sólo la fuerza obligatoria, sino también los derechos adquiridos.

El principio, en el derecho positivo chileno, es que el legislador carece de atribuciones para modificar los derechos y obligaciones emanados de contratos ya celebrados (Art. 19 N° 24 CPR), pues existe un derecho de dominio sobre los derechos personales: el acreedor es propietario de los derechos personales derivados del contrato. De acuerdo con la CPR, sólo se puede ser privado del dominio mediante una ley de expropiación y previo pago de indemnización.

Además, de acuerdo al Art. 22 LERL, en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Por tanto, las

normas legislativas sobre contratos sólo rigen a los contratos que se celebran después de que entren en vigor. Y aunque esta disposición sea de carácter legal, ello no implica que el legislador pueda dictar normas retroactivas sobre contratos, pues se encuentra limitado por el derecho de propiedad, que es constitucional. Así se ha fallado.

Los derechos contractuales son esencialmente derechos adquiridos, y su adquisición se produce en el momento mismo de la conclusión del contrato.

Crítica de la situación privilegiada en que hoy se encuentran los contratos en curso frente al legislador chileno (Postura del profesor Jorge López Santa María).

1) Este autor no simpatiza con la idea de propiedad sobre derechos personales. Tanto en el derecho romano clásico como en el postclásico, el dominio exclusivamente se entiende respecto a las cosas corporales, con las cuales llega a identificarse. Una hipotética vuelta al derecho de dominio cosificado no sería inconveniente a la admisión excepcional de propiedades especiales, como la intelectual y la industrial.

2) Para ser consecuentes con la idea del dominio sobre derechos personales, deberíamos aceptar también su posesión. Esto es opuesto al sistema del CC, pese a las dudas que levanta el Art. 715 CC, pues la principal consecuencia de la posesión, la prescripción adquisitiva, no tiene aplicación respecto de los derechos personales. Además, el Mensaje del CC descarta dicha posesión (Recordar discusión estudiada en bienes).

3) No se concibe que el derecho de dominio pueda versar sobre una cosa incorporal. El titular de un derecho personal ejercita las facultades que le corresponden, no porque sea dueño de una cosa, sino porque es acreedor.

4) La tesis mayoritaria sostiene la intangibilidad de los contratos en base al Art. 22 LERL. Pero el Art. 12 LERL permite argumentar en sentido contrario.

5) Supuesta la propiedad sobre derechos personales, la nueva ley que modifique contratos en curso no es inconstitucional si las limitaciones impuestas a los acreedores derivan de la función social de la propiedad. Así lo ha fallado la CS.

6) En un fallo, la CS admitió que un acto lícito de la Administración, que impone limitaciones a la propiedad, no excluye la posibilidad de que el afectado sea indemnizado. Así, podría dirimirse el problema admitiendo la procedencia de la modificación de los contratos por el legislador, en los casos en que lo exija el interés general de la nación, sin perjuicio del derecho de los contratantes perjudicados a exigir la reparación judicial de los daños sufridos.

7) Se han dictado en Chile diversas leyes que modifican contratos, las que han sido toleradas por los afectados, quienes no han luchado en defensa de sus

intereses, reclamando la inconstitucionalidad. Prácticamente, la ciudadanía ha aceptado la posibilidad de modificación.

En resumen, la vulneración de la obligatoriedad de los contratos por el legislador, aunque sea excepcional, es una realidad jurídica. Este fenómeno, que en ciertos casos puede ser adecuado y en otros no, demuestra que el principio de la fuerza obligatoria de los contratos es relativo, y no absoluto.

5.4.3 LA FUERZA OBLIGATORIA DE LOS CONTRATOS FRENTE AL JUEZ. DOCTRINA DE LA IMPREVISIÓN O DE LA VARIACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS VIGENTES AL CONTRATAR.

En virtud de la fuerza obligatoria del contrato, las partes deben cumplirlo, aunque les resulte perjudicial.

Si los contratos son intangibles para el legislador, lo son también para el juez, que no puede modificarlos con el pretexto del cambio de las circunstancias existentes al momento de contratar.

El que concluye un contrato asume un riesgo. De este riesgo normal no puede dispensarse nadie sin afectar la seguridad contractual. No puede admitirse la revisión judicial de los contratos como una institución permanente del derecho positivo, pues la subsistencia jurídica de un contrato no puede depender de que el obligado se encuentre económicamente en situación de cumplirlo. La revisión judicial debe quedar limitada a los casos en que la ley lo ha admitido expresamente.

La jurisprudencia chilena reiteradamente ha establecido la **intangibilidad de los contratos en curso**, desconociendo a los jueces la posibilidad de revisarlos o modificarlos. Infringe el Art. 1545 CC el tribunal que establece decisiones que suponen el desconocimiento de la ley del contrato.

Sin embargo, la aplicación inflexible del axioma pacta sunt servanda puede conducir a resultados injustos para una de las partes contratantes.

Para evitar esto, se ha desarrollado la **teoría de la imprevisión**: estudio de los supuestos bajo los cuales los jueces estarían autorizados para prescindir de la aplicación del contrato al pie de la letra, y estudio de las soluciones posibles al desajuste producido, que son fundamentalmente dos:

- revisión judicial del contrato y
- resolución por excesiva onerosidad sobreviniente.

Nuestro Código Civil no ha establecido una norma general que acepte o rechace la teoría de la imprevisión.¹¹ En ciertos casos la acepta y ciertos casos la

¹¹ Es necesario notar que, motivado por los efectos pandemia del Covid-19, el legislador ha ingresado un proyecto de ley que establece expresamente la teoría de la imprevisión

rechaza.

Casos en que el CC la acepta:

- 1) Art. 2180 CC: el **comodante** puede exigir anticipadamente la restitución de la cosa si le sobreviene una necesidad imprevista y urgente de ella.
- 2) Art. 2227 CC: el **depositario** puede obligar al depositante a recibir la cosa antes de lo esperado.
- 3) Art. 2003 regla 2ª CC: el **empresario** puede exigir la revisión judicial del contrato de construcción por suma alzada, si circunstancias desconocidas ocasionan costos que no pudieron preverse.

Casos en que el CC la rechaza:

- 1) Art. 1983 CC: el **arrendatario de un predio rústico** no puede pedir rebaja de la renta si sobreviene destrucción o deterioro de la cosecha.
- 2) Art. 2003 regla 1ª CC: el **empresario** no puede pedir aumento de precio si con posterioridad aumenta el valor de los materiales o la mano de obra.

El genuino ámbito de la teoría de la imprevisión corresponde a las situaciones no zanjadas por la ley.

Argumentos de texto para acoger la teoría de la imprevisión en nuestro Código Civil.

Se basa en los Arts. 1546, 1547, 1558 y 1560 CC.

- Argumento de la buena fe objetiva: el acreedor vulneraría el Art. 1546 CC si le exige a su deudor un cumplimiento mucho más gravoso del previsto al celebrar el contrato, susceptible incluso de arruinarlo. La buena fe impone tener en cuenta el cambio de circunstancias.
- Art. 1547 CC. El deudor puede alegar que el cumplimiento le significa una diligencia mayor a la exigida por la ley.
- Art. 1558 CC Como no hay dolo en el incumplimiento, no deben repararse los perjuicios que genera este suceso sobreviniente, pues se trata de daños imprevistos.
- Art. 1560 CC. En la interpretación de los contratos debe estarse a la intención de los contratantes más que a lo literal de las palabras. La intención de las partes será que se mantengan las circunstancias que se tuvieron en vista al contratar para mantener los términos del contrato.

en nuestro ordenamiento jurídico. Al respecto, revisar anexo II al final de este apunte.

5.4.3.1 LA REVISIÓN JUDICIAL DE LOS CONTRATOS EN CURSO Y LA RESOLUCIÓN POR EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE.

Tres posturas equivocadas a favor de la revisión judicial de los contratos, en opinión del profesor López Santa María.

1. Cláusula rebus sic stantibus: las partes contratan en consideración a las circunstancias existentes al momento de celebrar el acto, subentendiéndose la cláusula tácita de los contratantes, en virtud de la cual la intangibilidad del contrato quedaría subordinada a la persistencia del estado de cosas que existían al momento de la contratación.

Crítica: la cláusula es artificial. Si las partes hubieran querido la posible revisión del contrato, lo habría dicho. Lo que las partes no estipularon, no puede darse por tácitamente convenido, salvo que ello sea la real intención de las partes que sea descubierta en un proceso de interpretación por el juez.

2. Enriquecimiento sin causa: para que proceda la acción, deben concurrir los siguientes requisitos:

- 1) Que haya enriquecimiento del demandado y empobrecimiento correlativo del demandante.
- 2) Que el enriquecimiento carezca de una causa que lo legitime o justifique.
- 3) Que el actor no tenga otro medio de obtener satisfacción.
- 4) Que la acción no se interponga para burlar una norma legal imperativa.

Crítica: en los casos de la teoría de la imprevisión, siempre un contrato sirve de justificación al enriquecimiento de una de las partes.

3. Doctrina del abuso del derecho: para que exista abuso del derecho deben darse tres condiciones:

- 1) Que el hechor cause un daño al ejercer un derecho subjetivo.
- 2) Que no se trate un aquellos derechos llamados absolutos.
- 3) Que el ejercicio del derecho sea abusivo. ¿Cuándo ocurre esto? Todos están de acuerdo en que hay abuso cuando el derecho se ejerce con intención de causar daño, con dolo.

Pero, ¿qué pasa si no hay dolo? 2 posibilidades:

- Hay abuso cuando el derecho se ejerce contrariando la finalidad social o económica en vista de la cual fue conferido.

Crítica: este criterio es vago e impreciso, pues no siempre se puede apreciar exactamente la finalidad de cada derecho. Además, abre espacio a la arbitrariedad judicial.

- El abuso del derecho es una especie de acto ilícito, al cual corresponde aplicar las reglas generales de la responsabilidad civil extracontractual, de la cual el

abuso del derecho es una manifestación concreta.

Crítica: esta tesis quedaría, en consecuencia, fuera de un tema contractual, como es la teoría de la imprevisión.

Los requisitos de admisibilidad que se plantean en doctrina para la acción de revisión son:

- 1) Que se trate de un contrato, oneroso, conmutativo, de ejecución diferida o de tracto sucesivo, cuyo cumplimiento se encuentre pendiente.
- 2) Que sobrevenga un suceso independiente de la voluntad de las partes, imprevisible al instante de la formación del consentimiento,
- 3) Que ese suceso dificulte de manera considerable el cumplimiento de las obligaciones de uno de los contratantes, no haciéndolo imposible, pero volviéndolo excesivamente oneroso.

Resolución por excesiva onerosidad sobrevenida.

Opera de la siguiente manera: la parte afectada por la imprevisión recurre a los tribunales, demandando la resolución del contrato por excesiva onerosidad sobrevenida. El juez pondera las circunstancias y, en su caso, acoge la resolución. Pero el acreedor demandado puede enervar la acción, ofreciendo modificar equitativamente el contrato.

Este mecanismo no existe en el derecho positivo chileno.

5.4.3.2 ADAPTACIÓN DEL CONTRATO A LAS NUEVAS CIRCUNSTANCIAS POR ACUERDO DE LAS PROPIAS PARTES.

Técnicas estrictamente convencionales de adaptación del contrato a las nuevas circunstancias.

En el plano del comercio internacional, se advierte una nueva práctica: incorporar en el texto del contrato inicial, cláusulas en virtud de las cuales las partes se comprometen a modificarlo, si se producen alteraciones no previstas.

Ej. Government take clause, first refusal clause, cláusula del cliente más favorecido, cláusula de alza y de baja, cláusula de fuerza mayor y cláusula hardship.

Cláusula hardship: permite a cualquiera de las partes exigir una adaptación del contrato si se produce un cambio en las circunstancias que las llevaron a vincularse, de modo que este cambio le ocasione un rigor (hardship) injusto. Estas técnicas de adaptación anulan el esquema contractual tradicional: la idea de que el contrato es conciliación definitiva de intereses opuestos, dotado de fuerza obligatoria y de intangibilidad.

Demuestran que en los contratos a largo plazo, las estipulaciones no siempre son definitivas; que las partes son colaboradoras; que el ideal del contrato es que todos ganen, o al menos que nadie se arruine.

Reprogramación voluntaria de los contratos facilitada por la autoridad.

Otras técnicas de modificación por las partes de contratos en curso no dependen de cláusulas pactadas de antemano, sino que de la fijación por la autoridad de ciertas bases que incentivan o permiten la reprogramación voluntaria de lo inicialmente pactado.

Ej. En Chile: proceso de reprogramación de las deudas hipotecarias (década 80).

5.4.4 LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O DEL AGOTAMIENTO DE SU FUERZA OBLIGATORIA.

Terminación normal:

- Las obligaciones generadas por el contrato se cumplen totalmente, a través del pago o los modos de extinguir las obligaciones equivalentes al pago.
- También por el vencimiento del plazo,
- También por el desahucio de una de las partes.

Terminación anormal o invalidación: por la voluntad de las partes o por causas legales (Art. 1545 parte final CC).

a) Resciliación: convención en que las partes interesadas consienten en dar por nula la obligación (Art. 1567 inc. 1º CC). Inexactitudes de la disposición:

- 1) No toda obligación puede extinguirse por resciliación.
- 2) En ciertas situaciones es posible la resciliación unilateral, por lo que no es una convención.
- 3) La obligación no se da por "nula".

b) Causas legales: las principales son:

- 1) Nulidad absoluta y relativa.
- 2) Resolución.
- 3) Resolución por excesiva onerosidad sobrevenida (derecho comparado).
- 4) Revocación (acción pauliana).
- 5) Caso fortuito, cuando produce la extinción de la obligación correlativa.
- 6) Muerte de uno de los contratantes (contratos intuitu personae).

5.5. EL PRINCIPIO DEL EFECTO RELATIVO DE LOS CONTRATOS. EFECTO RELATIVO Y EFECTO ABSOLUTO U Oponibilidad DE LOS CONTRATOS.

Principio del efecto relativo de los contratos: los contratos sólo generan derechos y obligaciones para las partes contratantes que concurren a su

celebración, sin beneficiar ni perjudicar a los terceros.

El CC no lo consagra de manera expresa y general, pero la doctrina y jurisprudencia lo admiten, desprendiéndose tácitamente del artículo 1545 CC que señala que el contrato legalmente celebrado es ley para las *partes*.

Este principio es otra consecuencia lógica y necesaria del dogma de la autonomía de la voluntad: si la voluntad es fuente y medida de los derechos y obligaciones contractuales, sólo lo es a condición de que haya voluntad.

Sin embargo, la declinación de este principio, en el derecho contemporáneo, surge desde dos vías:

- **Excepciones al efecto relativo:** casos en que un contrato crea derechos u obligaciones para un tercero absoluto.
- **Efecto expansivo o efecto absoluto de los contratos:** indirectamente, los contratos pueden beneficiar o perjudicar a personas que no revisten el carácter de partes.

5.5.1 SUJETOS CONCERNIDOS POR EL PRINCIPIO DEL EFECTO RELATIVO DE LOS CONTRATOS.

1. Situación de las partes:

Son partes del contrato aquellos que concurren a la celebración del contrato, personalmente o representados.

Como lo señala la ley, una parte puede estar conformada por una o más personas, que articulan un solo centro de interés (artículo 1438 del Código Civil).

Generalmente, se llama autor a la persona que genera, al manifestar su voluntad, un acto jurídico unilateral, mientras que se reserva la expresión “parte”, a los que concurren para que se perfeccione un acto jurídico bilateral.

También, por regla general, y desde el fallecimiento de los contratantes, los herederos, pues representan a los contratantes para sucederles en sus derechos y obligaciones transmisibles.

Excepcionalmente, las obligaciones contractuales son intransmisibles:

- 1) Contratos intuitu personae.
- 2) Contratos en que se estipula expresamente su terminación por el fallecimiento de los contratantes.
- 3) Herederos que aceptan con beneficio de inventario.
- 4) Obligaciones que por disposición de la ley, no pasan a los herederos.

2. Situación de los terceros:

En general, se entiende por tercero toda persona, que no ha participado ni ha sido válidamente representada en la formación del acto. Se trata de todos aquellos que incluso habiendo participado físicamente en el acto jurídico, sus voluntades no han sido determinantes para la generación del mismo.

Entre los terceros, debemos distinguir: entre los terceros absolutos y los terceros relativos.

(1) Terceros absolutos: aquellos que fuera de no participar en el contrato, ni personalmente, ni representados, no están ligados jurídicamente con las partes por vínculo alguno. El contrato no les empece.

(2) Terceros relativos: también llamados “interesados”, son aquéllos que si bien no han formado con sus voluntades el acto jurídico, están o estarán en relaciones jurídicas con las partes, sea por su propia voluntad o por disposición de la ley. La idea de terceros relativos presupone, por una parte, un acto al cual el tercero es extraño, y por otra parte, un nuevo acto o hecho jurídico en general, en el que esta persona es parte con relación a uno de los sujetos del primer acto y en virtud del cual, llega, necesariamente, a encontrarse en relación con el otro sujeto que intervino en el primer acto, a consecuencia del contenido de las dos estipulaciones.

A su vez, entre los terceros relativos o interesados diferenciamos dos categorías: los causahabientes a título singular y, en opinión de una parte de la doctrina, los acreedores comunes del deudor

- **Causahabientes a título singular:** quienes suceden a una persona, por acto entre vivos o mortis causa, en un bien específicamente determinado, y no en la totalidad de su patrimonio o cuota de él.

Son causahabientes a título singular por acto entre vivos el comprador, el donatario, el mutuario. Lo son mortis causa, los legatarios.

¿Afectan a los causahabientes a título singular los contratos celebrados por el causante o autor con otros sujetos?

- El problema, por cierto, se circunscribe exclusivamente a los contratos celebrados por el causante sobre la cosa o derecho que específicamente se transfiere o transmite al causahabiente singular, antes que éste pase a ocupar el lugar jurídico de su autor. Según la mayoría de la doctrina, especialmente extranjera, la respuesta es afirmativa, debiendo tenerse a los causahabientes singulares como partes en tales actos.

- Sin embargo, los ejemplos de la doctrina, casi siempre dicen relación con la constitución de derechos reales limitativos del dominio, por lo que la respuesta afirmativa es una consecuencia del derecho de persecución o efecto erga omnes propio de los derechos reales. Así ocurre cuando el causante, antes de transferir un inmueble, lo había hipotecado o gravado con servidumbres, censo o usufructo (artículos 2428 inc. 1, 825, 2033 y 792 del Código Civil).
- La cuestión en análisis se torna problemática, cuando el causante había limitado sus poderes sobre la cosa en el ámbito estrictamente de las obligaciones y derechos personales y no en el de los derechos reales desmembrados del dominio. Por ejemplo, si el causante se había obligado a no enajenar un bien ¿es oponible tal cláusula al causahabiente singular o adquirente? A través de la doctrina de las obligaciones ambulatorias o propter rem, se responde afirmativamente: son obligaciones ambulatorias aquellas cuyo sujeto pasivo es variable, de tal modo que el rol del deudor lo asume quien se encuentre en la posición jurídica del dueño de la cosa. Estas obligaciones se traspasan al causahabiente singular junto con la transmisión del derecho de dominio sobre la cosa. Ejemplo por acto entre vivos: obligación de pagar las expensas comunes, en el ámbito de la Copropiedad Inmobiliaria. Esta obligación, que comprende los gastos de conservación y mantención del inmueble y los gastos de administración del edificio, tiene carácter ambulatorio, pues va aparejada a la calidad de actual dueño de cada unidad o departamento, extendiéndose incluso a las expensas devengadas por los precedentes dueños. En materia de obligaciones tributarias del causante, ellas pueden exigirse al comprador, cesionario o adquirente de la industria, negocio o bien determinado. Incluso puede ocurrir que el contrato completo que había celebrado el antecesor, se traspasa por mandato de la ley al causahabiente singular: en los tres casos del Art. 1962, obligación de respetar el contrato de arrendamiento.
- ¿Qué ocurre en las hipótesis no previstas por el legislador? Aunque el asunto es discutible, a falta de norma expresa pareciera que las obligaciones contraídas por el causante no empecen al causahabiente singular. Este, en virtud del efecto relativo de los contratos, podría sostener que la obligación convenida en relación con el bien en que sucede, le es inoponible. Por su parte, a quien contrató con el causante, sólo le quedaría la posibilidad de demandarlo por incumplimiento de la obligación, pero no podría exigir el pago al causahabiente singular.
- **Acreeedores de las partes:** son terceros absolutos en los contratos que su deudor celebre con otras personas. Pero, indirectamente, son

alcanzados por el efecto expansivo o absoluto de los contratos.
Pueden impugnar los contratos que el deudor celebre en perjuicio de ellos con la acción de simulación y la acción pauliana, por ejemplo.

5.5.2 EXCEPCIONES AL EFECTO RELATIVO DE LOS CONTRATOS.

I. CONTRATOS COLECTIVOS.

II. ESTIPULACIÓN POR OTRO O CONTRATO EN FAVOR DE UN TERCERO.

Art. 1449 CC. "Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él.
Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato."

En estipulación en favor de otro intervienen 3 personas, a saber, el estipulante, el prometiende, y el beneficiario, aunque lo hacen de manera distinta. En rigor, las partes del contrato a favor de otro son el prometiende y el estipulante. El beneficiario, sin haber sido parte del contrato, adquiere un derecho sobre la prestación a la cual se ha obligado el prometiende, sin haber concurrido al acto. Su aceptación no es condición de la adquisición del derecho, sino un requisito de exigibilidad del mismo.

Así, la estipulación a favor de un tercero puede ser pensada como una verdadera excepción al efecto relativo de los contratos. No obstante, esta afirmación puede resultar controversial, en la medida en que la naturaleza jurídica de esta figura resulta discutible. Así, como ya veremos, la estipulación en favor de un tercero será una verdadera excepción al efecto relativo de los contratos solo si es que aceptamos la teoría de la adquisición directa del derecho.

Teorías sobre la naturaleza jurídica de la estipulación en favor de un tercero:

1) Teoría de la oferta:

La estipulación en favor de un tercero se descompone en dos convenciones:

- (1) Primer contrato: el prometiende se obliga frente al estipulante, quien se transforma en acreedor de la estipulación.
- (2) Segundo contrato: el estipulante ofrece su crédito al tercero, por cuya aceptación se forma este segundo contrato, que sirve de título traslativo a la cesión del crédito.

Críticas:

- i. El crédito contra el prometiende inicialmente ingresa al patrimonio del estipulante, por lo que podría ser embargado por sus acreedores.
- ii. La cesión a título gratuito podría ser invalidada, a posteriori, a iniciativa de los herederos del estipulante, por la acción de inoficiosa donación.
- iii. La oferta caduca por muerte o incapacidad del oferente. Si el estipulante muere antes de la aceptación del tercero, no es posible consolidar la operación.

2) Teoría de la gestión de negocios ajenos:

El estipulante obra como gestor de los negocios del tercero, como agente oficioso. Por la aceptación del tercero, se transforma retroactivamente la operación cuasicontractual en un contrato de mandato. El beneficiario es parte, no tercero.

Crítica: la teoría es ficticia porque:

- 1)** El estipulante actúa a nombre propio, no como agente oficioso.
- 2)** Faltan dos elementos de la agencia oficiosa:
 - El interesado en la gestión debe cumplir las obligaciones contraídas por el agente si éste ha administrado bien el negocio (Art. 2290 CC). El tercero en la estipulación puede rechazarla.
 - El agente, después de iniciada la gestión, está obligado a proseguirla (Art. 2289 CC). El estipulante puede revocar la estipulación de común acuerdo con el prometiende, mientras no acepte el tercero.

3) Teoría de la declaración unilateral de voluntad:

El prometiende adquiere el rol de deudor (del tercero) por su exclusiva voluntad.

Críticas:

- 1)** Es dudoso que el derecho chileno acoja la declaración unilateral como fuente de las obligaciones.
- 2)** Desconoce el contrato que media entre estipulante y prometiende.
- 3)** No explica por qué es necesaria también la voluntad del estipulante para revocar la estipulación.

4) Teoría de la adquisición o creación directa del derecho:

La figura es original, de carácter excepcional: hay una derogación del principio del efecto relativo. El derecho se crea directamente en favor del tercero, desde el instante mismo en que se celebra el contrato entre estipulante y prometiende, aunque el tercero lo ignore. La aceptación es

sólo un requisito para que él pueda exigir la prestación, un presupuesto de exigibilidad, pero no crea el derecho.

Efectos de la estipulación por otro:

(1) Entre estipulante y prometiente: son las partes en el contrato; se producen entre ellos los efectos normales de los contratos (reglas de resolución).

- Pero sólo el tercero beneficiario puede demandar lo estipulado.
- El estipulante puede exigirle al prometiente que le cumpla al tercero.
- Además, estipulante y prometiente pueden revocar el contrato mientras el beneficiario no haya aceptado. Tanto revocación como aceptación pueden ser actos jurídicos tácitos.

(2) Entre prometiente y beneficiario: el prometiente se encuentra directamente obligado frente al beneficiario.

- El beneficiario es acreedor desde el momento de la celebración del contrato, y tiene acción, desde que acepta, para exigir el cumplimiento forzado y/o la indemnización moratoria o compensatoria, pero no tiene acción resolutoria.
- Si el beneficiario muere antes de aceptar, el derecho ya está en su patrimonio, por lo que transmite la facultad de aceptar.

(3) Entre estipulante y beneficiario: jurídicamente son sujetos extraños.

❖ LA PROMESA DE HECHO AJENO NO ES UNA EXCEPCIÓN AL EFECTO RELATIVO DE LOS CONTRATOS.

Art. 1450 CC. "Siempre que uno de los contratantes se compromete a que por una tercera persona, de quien no es legítimo representante, ha de darse, hacerse o no hacerse alguna cosa, esta tercera persona no contraerá obligación alguna, sino en virtud de su ratificación; y si ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la promesa."

Esto no es una excepción al principio del efecto relativo, ya que el contrato no crea ningún derecho, y menos una obligación a cargo del tercero absoluto.

El único que resulta obligado es el prometiente, que se compromete a obtener que otra persona acepte efectuar la prestación en favor del acreedor. Lo que el deudor promete es un hecho propio.

- Si el prometiente fracasa en cumplir su obligación de hacer, debe indemnizar al acreedor por los perjuicios que se deriven del incumplimiento.
- Si el tercero acepta y después no cumple, se aplican las reglas de los

efectos de las obligaciones entre acreedor y tercero, sin que el acreedor pueda demandar al promitente, a menos que éste se hubiera obligado solidaria o subsidiariamente, o a través de otra caución.

- Si el tercero no acepta, el acreedor sólo puede demandar al promitente el cumplimiento forzado por equivalencia; no procede la ejecución forzada en naturaleza.

Fuente de la obligación del tercero:

1) Cuasicontrato de agencia oficiosa: el promitente, que no puede representar al tercero, actúa como gestor de negocios del mismo.

Crítica: la agencia oficiosa crea obligación para el interesado si el negocio ha sido bien administrado (criterio objetivo, Art. 2290 CC). En la promesa de hecho ajeno, todo depende de la voluntad del tercero (criterio subjetivo).

2) Voluntad unilateral del deudor: la fuente de la obligación es la voluntad del tercero que ratifica.

Crítica: el Art. 1536 inc. 2º CC, referido a la cláusula penal, señala que la obligación puede no tener efecto por falta de "consentimiento". En consecuencia, la promesa de hecho ajeno implica, para su eficacia, un acuerdo de voluntades, y no la voluntad aislada del deudor.

3) Es más simple admitir que la fuente de la obligación del tercero es la ley.

5.5.3 EL EFECTO ABSOLUTO O EXPANSIVO DE LOS CONTRATOS.

I. Concepto.

Además de ser la fuente de relaciones jurídicas obligacionales, los contratos son hechos jurídicos que, como tales, son partes integrantes de la realidad jurídica. En este sentido, el contrato produce efectos como acto jurídico bilateral (los derechos y obligaciones de las partes) y como hecho jurídico. Para referirse a esta dualidad en los efectos del contrato, la doctrina distingue entre la eficacia directa (derechos y obligaciones de las partes) y eficacia indirecta del contrato. El efecto absoluto de los contratos es parte de la eficacia indirecta de los contratos.

Dentro de la eficacia indirecta de los contratos, a su vez, podemos distinguir entre los efectos reflejos del contrato, por un lado, y el efecto absoluto o expansivo del contrato, por el otro.¹²

La eficacia refleja del contrato consiste en las repercusiones que el contrato

¹² Hemos optado por seguir la terminología del profesor Álvaro Vidal, tal como la formula en su artículo "El efecto absoluto de los contratos", en: *Revista Chilena de Derecho Privado*, 2006, pp. 51-85. Por otro lado, el profesor López Santa María no distingue entre los efectos reflejos y el efecto absoluto de los contratos, utilizando solo este último término para referirse en general a la eficacia indirecta de los contratos.

produce con relación a otras relaciones jurídicas preexistentes, vinculadas o conectadas con él. Tal es el caso, por ejemplo, con las relaciones contractuales subordinadas, como es el caso de la fianza. En este caso, si las partes rescilian el contrato principal, el efecto reflejo de esa resciliación es la extinción de la fianza.

El efecto absoluto o expansivo del contrato de los contratos se refiere a la posibilidad de invocar el contrato como fundamento de una pretensión o de una toma de actitud, ya sea por las partes en contra de terceros, o por terceros en contra de las partes. Si las partes invocan un contrato celebrado entre ellos para fundar una pretensión en contra de un tercero, hablamos de la oponibilidad del contrato. Si terceros invocan un contrato ajeno para fundamentar una pretensión suya en contra de una de las partes, se habla de la utilización o la utilizabilidad del contrato.¹³

Como ya dijimos, la eficacia indirecta de los contratos emana de su carácter de hechos jurídicos. En tal sentido, el efecto expansivo de los contratos no es una excepción al principio del efecto relativo de los contratos, pues no ha surgido ningún derecho u obligación directamente para los terceros. A lo sumo, podría considerarse como una atenuación a dicho principio.

II. Casuística del efecto expansivo o efecto absoluto de los contratos.

1. Procedimientos concursales de reorganización o liquidación. En los procedimientos concursales de reorganización o liquidación, regidos por la ley 20.720, una vez que los créditos han sido reconocidos en la forma en que lo ordena dicha ley, estos no podrán ser desconocidos por los demás acreedores argumentando que provienen de contratos que no les empecen.

2. Ventas sucesivas. En los efectos de las ventas sucesivas de una misma cosa a dos o más personas, el comprador en desventaja resulta perjudicado por el efecto expansivo de la compraventa (Art. 1817 CC).

3. Acción directa en contra del cocontratante. A veces el legislador confiere al acreedor una acción directa que le habilita para actuar en nombre propio, en sede contractual, contra el cocontratante del deudor. el demandante puede oponer al demandado un contrato en el que sólo el segundo fue parte.

- En nuestra legislación, el caso más importante lo encontramos en la Ley Nº 18.490, en materia de seguro obligatorio contra riesgos personales derivados de la circulación de vehículos motorizados. La víctima de un accidente del tránsito puede accionar directamente contra el asegurador, a pesar de que la primera sea un tercero absoluto en el contrato de seguro. No obstante ello, podrá esgrimir, a título personal, el contrato ajeno.
- Igual ocurre en algunas hipótesis de subcontrato, como en el

¹³ Nuevamente, esta distinción no es compartida por el profesor López Santa María, quien habla indistintamente de oponibilidad de los contratos para designar ambas hipótesis.

- submandato (Art. 2138), al permitirse al mandante accionar directamente en contra del delegado o submandatario;
- También en el caso de los subcontratistas, que pueden exigir el pago de sus remuneraciones u honorarios al propietario de la obra, y no sólo al empresario o constructor que contrató al subcontratista (Art. 2003, regla 5ª)
 - O, en el caso del subarrendamiento, cuando se posibilita al arrendador para expeler al subarrendatario de la casa o edificio, si hubiere tenido notoria mala conducta (Art. 1973)

4. Convenciones en perjuicio de terceros: el contrato fraudulento celebrado por el deudor con otra persona puede ser atacado por el acreedor (tercero absoluto), mediante la acción pauliana.

5. Contratos del derecho de familia, que producen efectos erga omnes. Ej. Adopción. Señala Somarriva, los actos de familia son de efectos absolutos en el sentido de que el estado civil a que ellos dan origen puede oponerse a cualquiera persona.

En todos estos casos, hay norma legal que sirve de fundamento al efecto expansivo. No es así en el siguiente caso:

Oponibilidad de un contrato por terceros a las partes o viceversa, en materia de responsabilidad civil extracontractual (derecho comparado):

1) Oponibilidad de un contrato por terceros a las partes: se ha admitido que el incumplimiento de un contrato por una de las partes, sea invocado contra ella por un tercero como base fundamental de una demanda indemnizatoria en sede extracontractual.

2) Oponibilidad de un contrato por las partes a terceros: se trata de la responsabilidad civil extracontractual del tercero cómplice de la violación de un contrato. En Chile, se ha aceptado la oponibilidad de un contrato por las partes a terceros en el caso del precario.

5.5.4 LA INOPONIBILIDAD DE LOS CONTRATOS.

I. Concepto

El CC no la trata sistemáticamente. Si bien ella se produce, nunca la nombra.

Inoponibilidad: sanción civil que impide que se haga valer ante terceros un derecho. (Nacido de la celebración de un acto jurídico, de la nulidad o de otra causal de terminación anormal de un acto jurídico).

II. Diferencias con la nulidad.

1. Presencia de vicios en el acto.
 - La nulidad deriva de vicios producidos en el momento del nacimiento del acto.
 - La inoponibilidad es independiente de la generación del acto por las partes; el acto es válido, pero otras circunstancias determinan su ineficacia frente a terceros.
2. A quiénes alcanzan los efectos (Partes o terceros)
 - La nulidad produce efectos entre las partes y respecto de terceros.
 - La inoponibilidad, sólo respecto de terceros.
3. Posibilidad de renunciar a ella.
 - La nulidad es una sanción de orden público, que no puede renunciarse anticipadamente.
 - La inoponibilidad está establecida exclusivamente en beneficio de los terceros, y es de orden privado: puede renunciarse.
4. Declaración de oficio.
 - La nulidad absoluta puede declararse de oficio.
 - La inoponibilidad jamás.

Algunos autores sostienen que los terceros beneficiados con la inoponibilidad son sólo los relativos. Pero esto no es efectivo: en algunos casos, beneficia a absolutos.

III. Principales motivos de inoponibilidad.

1. Incumplimiento de las formalidades de publicidad. Ej. Art. 2513 CC, Art. 297 CPC.

a) Las contraescrituras: Según el art. 1707 inc. 2º para que las contraescrituras públicas de escrituras públicas afecten a terceros, es necesario que se tome razón de ellas al margen de la escritura original y de la copia con la cual está obrando el tercero.

b) La prescripción adquisitiva o usucapión: *Art. 2513. La sentencia judicial que declara una prescripción hará las veces de escritura pública para la propiedad de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos; pero no valdrá contra terceros sin la competente inscripción.* Esta inscripción en el Registro del Conservador de BBRR no es tradición; sólo constituye una formalidad de publicidad, destinada a mantener la historia del inmueble del cual se trate.

c) Cesión de créditos: Se perfecciona entre las partes por la entrega del título, y respecto del deudor cedido y terceros, por la notificación o aceptación del deudor. *Art. 1901. La cesión de un crédito personal, a cualquier título que*

se haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título. Art. 1902. La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste. Mientras la notificación no se efectúe o el deudor acepte la cesión, ésta es válida entre cedente y cesionario, quien pasa a ocupar la calidad del acreedor, pero no puede oponerla ni al deudor ni a terceros, y uno de éstos, acreedor del cedente, podría válidamente embargar el crédito, ya que la cesión no le empece.

d) Enajenación de cosas embargadas: Según el art. 1464 hay objeto ilícito, y por ende, nulidad absoluta, a menos que el juez o el acreedor la autoricen, pero según al art. 453 CPC, si el embargo recae en bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos, no producirá efecto legal alguno respecto de terceros, sino desde la fecha en que se inscriba en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de BBRR respectivo; mientras ella no se efectúe, el embargo es inoponible a terceros, y así no podría invocarse la nulidad contra el tercero adquirente si la inscripción no se ha efectuado antes de la enajenación. Acorde a la Ley del Tránsito, son inoponibles a terceros los gravámenes, prohibiciones, embargos y medidas precautorias que afecten a los vehículos, mientras no se anoten en el Registro de Vehículos Motorizados.

e) La medida precautoria de prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados: El tribunal puede decretar prohibición de celebrar actos o contratos con relación a los bienes que son materia del juicio o respecto de otros bienes determinados del demandado, cuando sus facultades no ofrezcan suficiente garantía para asegurar el resultado del juicio (Art. 296 CPC). Si recae sobre inmuebles, la prohibición debe inscribirse en el Registro de Prohibiciones e Interdicciones, sin lo cual no produce efectos respecto de terceros. (Art. 297 inc. 1º CPC). Si versa sobre muebles, sólo produce efecto respecto de terceros que tengan conocimiento de ella al tiempo del contrato; pero el demandado será en todo caso responsable de fraude, si ha procedido a sabiendas (Art. 297 inc. 2º CPC).

2. Falta de fecha cierta. Los instrumentos privados pueden antedatarse o postdatarse por los otorgantes, por lo cual carecen de fecha cierta; por tanto son inoponibles respecto al día en el cual aparecen suscritos. Pero esto no es absoluto, pues hay circunstancias que a partir de su acaecimiento acarrear plena claridad de la fecha de los documentos privados. Hay seguridad de que la fecha no es posterior. Ej. Muerte de un otorgante (Art. 1703 CC).

3. Falta de consentimiento.

En nuestra legislación, en general todos los actos sobre bienes ajenos no son nulos. *Art. 1815. La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso de tiempo.*

Pero esta venta no es oponible al verdadero dueño, quien puede reivindicar el inmueble mientras su acción no se extinga por la prescripción adquisitiva a favor del comprador. También el arrendamiento de cosa ajena, la prenda y la hipoteca de cosa ajena, etc.

4. Nulidades u otras causales de ineficacia de los actos jurídicos.

- 1) La nulidad de un acto confiere acción reivindicatoria contra terceros, aunque estén de buena fe pero existen excepciones. Ej. Tercero que adquiere la cosa por prescripción. (Excepciones al Art. 1689 CC)
- 2) El matrimonio nulo putativo o simplemente nulo es inoponible a los hijos relativamente a su filiación determinada (Art. 51 LMC).
- 3) La resolución judicialmente declarada es inoponible a terceros de buena fe. (Art. 1490 y 1491 CC)
- 4) En la donación, normalmente la resolución, rescisión y revocación son inoponibles a terceros poseedores de los bienes donados (Art. 1432 CC).

5. Simulación. las partes no pueden oponer el acto oculto a terceros. Los terceros pueden optar por prevalecerse del acto ostensible o del oculto.

6. Fraude: acción pauliana o revocatoria. En cualquier relación jurídica, el deudor mantiene la libertad de seguir actuando con su patrimonio en el mundo de los negocios jurídicos. El acreedor debe soportar en consecuencia, la posible disminución del patrimonio de su deudor, y de tal punto de vista, los actos del último le son oponibles. Afectarán el derecho de prenda general del acreedor. Pero éste no está obligado a tolerar actos que supongan una disminución del patrimonio del deudor, en los cuales éste ha actuado fraudulentamente. Recurrirá entonces el acreedor a uno de sus derechos auxiliares: la acción pauliana o revocatoria.

Esta es una acción de inoponibilidad, ya que el contrato que se revoca no tiene eficacia frente al acreedor perjudicado por el fraude.

También esta es una inoponibilidad de fondo.

IV. Cómo se invoca la inoponibilidad.

La inoponibilidad se puede hacer valer como acción o excepción.

Como acción, reclamando del acto inoponible, como por ejemplo en la venta de cosa ajena si el verdadero dueño ejerce la acción reivindicatoria; en la simulación, por la acción de simulación. La acción pauliana, si se acepta que es inoponibilidad, también se ejerce por esta vía.

El tercero interpondrá la inoponibilidad como excepción cuando se invoque en

su contra el acto afecto a esta sanción; así ocurrirá normalmente en la inobservancia de una medida de publicidad; por ejemplo, si se enajena un bien raíz embargado, pero cuyo embargo no se ha inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y el ejecutante demanda la nulidad de la enajenación, el adquirente le opondrá como excepción la inoponibilidad.

En cuanto a las partes legitimadas para invocar la inoponibilidad, ello depende de los casos que se presenten porque a veces ella está establecida en beneficio de todos los terceros, y entonces aquel en cuya contra se invoque el contrato inoponible podrá negarle eficacia. Pero hay otras inoponibilidades que están establecidas en beneficio exclusivo de ciertos terceros, como, por ejemplo, las del mandatario excedido a favor del mandante, quien es el único que puede invocarla.

Y en cuanto a las personas contra quienes se interpondrá, serán todos aquellos, partes o terceros, que pretendan asilarse en el acto inoponible, como el comprador en la venta de cosa ajena y sus sucesores en la posesión de la cosa vendida; el que contrató con el mandatario excedido, etc.

V. Extinción de la inoponibilidad.

Tampoco es posible establecer reglas generales que abarquen todas las situaciones en que la inoponibilidad se presenta, para determinar las causales de extinción de ellas.

- Las inoponibilidades por falta de publicidad se sanean por el cumplimiento de las formalidades omitidas.
- Toda inoponibilidad termina por la renuncia a ella, que afecta sólo a quien la efectúa, y en consecuencia, otros terceros podrían siempre invocarla.
- En la inoponibilidad por falta de concurrencia, como ella corresponde exclusivamente a aquel cuyo consentimiento fue omitido, él es el único que puede invocarla, y su renuncia, que toma el nombre de especial de ratificación, sana totalmente el acto.
- Finalmente, puede extinguirse la inoponibilidad por prescripción cuando ella se haga valer como acción. Como la acción de simulación no tiene plazo especial, prescribe en 5 años; la revocatoria tiene plazo especial, y la reivindicatoria se extinguirá cuando el poseedor adquiera la cosa por prescripción adquisitiva.
- Normalmente, el acto inoponible no dejará de serlo por prescripción para los efectos de oponerla como excepción, salvo que ella hubiera podido invocarse como acción.

5.5.5. LA SIMULACIÓN Y EL EFECTO RELATIVO DE LOS CONTRATOS.

I. Frecuencia de la simulación. Simulación lícita e ilícita; absoluta, relativa y mediante interposición de persona.

En la simulación existe conflicto entre la voluntad declarada y la voluntad real. Hay simulación cuando los efectos de un acto aparente o simulado son modificados o completamente suprimidos por otro acto destinado a permanecer en secreto.

El CC no regula la simulación. La doctrina y jurisprudencia han construido el estatuto jurídico en base al Art. 1707 inc. 1º CC.

La simulación no siempre es reprobada por el Derecho. Existen instituciones que también descansan en la insinceridad, y que reciben tutela jurídica. Ej. Mandato sin representación (permite al mandatario ocultar el carácter de tal), asociación o cuentas en participación.

Simulación ilícita: únicamente la que tiene por preciso objeto burlar a los terceros.

Simulación lícita: puede deberse a muchas razones. Ej. Sustraerse a disgustos, vanidad, conservar apariencias sociales, etc.

La jurisprudencia ha establecido que la simulación, no mediando perjuicio de tercero, es perfectamente lícita.

II. Grados o categorías de simulación:

a) Absoluta: el acto ostensible no oculta realidad alguna. Tras el acto simulado existe la no contratación.

b) Relativa: se celebra un acto jurídico real, pero las partes lo disfrazan o disimulan bajo una apariencia distinta, ya sea alterando la naturaleza jurídica del acto, o modificando una o más cláusulas.

c) Por interposición de personas: a fin de burlar las incapacidades y prohibiciones legales, se utiliza un intermediario, quien, con su intervención consciente y deliberada, permite la burla o el fraude a la ley.

III. Efectos y prueba de la simulación.

1) Efectos entre las partes: prevalece el acto secreto y no el aparente, lo que se deduce de una interpretación contrario sensu del Art. 1701 CC.

- Si se prueba la simulación, y desaparece el acto aparente, el acto real debe analizarse según las reglas generales.
- La acción de simulación no es una acción de nulidad, sino una acción de

certeza, meramente declarativa.

- Demostrada la simulación absoluta, nuestros tribunales han resuelto que existe nulidad absoluta por falta de consentimiento de las partes. La genuina sanción civil debería ser la inexistencia.
- Demostrada la simulación relativa o la interposición de personas, el acto oculto puede tener variados destinos, de acuerdo a las reglas generales: ser revocado por la acción pauliana, ser anulado, etc. Pero si el acto secreto no adolece de vicios ni se ha celebrado en perjuicio de terceros, producirá plenos efectos.

2) Efectos respecto de terceros (relativos): el acto secreto, que se descubre mediante la acción de simulación, es inoponible a los terceros (Art. 1707 CC).

- Si bien las partes no pueden oponerle a los terceros el acto secreto, en cambio estos últimos sí están autorizados para invocarlo, a condición de que puedan probarlo.
 - Hay terceros que pueden querer:
 - a) Valerse del acto secreto (aquellos contra quienes se realizó el engaño);
 - b) Otros pueden querer valerse del acto ostensible (aquellos que actuaron en vista de la apariencia generada por el acto).
- ***En realidad, los terceros tienen un derecho de opción, para invocar cualquiera de los dos, de acuerdo a su interés. Si se produce un conflicto entre terceros, hay consenso en que debe preferirse al tercero que está en posesión del bien de que se trate.

3) Prueba de la simulación:

- ❖ Entre las partes: la forma ordinaria es mediante la exhibición de la contraescritura en la cual se dejó constancia de la verdadera intención de las partes.
No se puede probar por testigos, de acuerdo a los Arts. 1708 y 1709 CC. Podría teóricamente probarse mediante la confesión o absolución de posiciones, y sobre todo mediante presunciones judiciales.
- ❖ Respecto a los terceros: puede acreditarse por todos los medios de prueba, sin que se apliquen las limitaciones a la admisibilidad de la testimonial. La más importante será la prueba de presunciones judiciales.

5.6 EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE CONTRACTUAL.

La buena fe evoca la idea de rectitud, de corrección. En sede no jurídica, designa una persuasión subjetiva interna (carácter ético) de estar actuando o haber actuado correctamente.

Proyectada al derecho civil, asume 2 direcciones: buena fe subjetiva y buena fe objetiva. Esta última pierde aquella fisonomía psicológica.

La buena fe es un principio general del derecho.

❖ BUENA FE SUBJETIVA.

Es la convicción interna o psicológica de encontrarse el sujeto en una situación jurídica regular, de actuar conforme a derecho, aunque objetivamente no sea así; aunque haya error. Por tanto, la buena fe es una noción justificativa del error.

Casos:

- 1) Posesión de buena fe (Art. 706 inc. 1º CC).
- 2) Matrimonio putativo (Art. 51 LMC).
- 3) Pago de lo no debido (Arts. 2300 y ss. CC).
- 4) En materia de contratos: pactos de irresponsabilidad por el saneamiento (Arts. 1842 y 1859 CC), renuncia del socio (Art. 2110 CC) y acción pauliana (Art. 2468 CC).
- 5) Pago de buena fe hecho al poseedor del crédito (art. 1576 incº2 CC)

❖ BUENA FE OBJETIVA.

Es la que más interesa en el ámbito de los contratos.

Art. 1546 CC. "Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella."

La regla de la buena fe objetiva impone a los contratantes el deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas, desde el inicio de los tratos preliminares y hasta momentos incluso posteriores a la terminación del contrato.

Es un estándar de conducta, un parámetro flexible cuyo manejo y concreción, en cada caso, queda entregado al criterio del juez, pero que tiene una unidad de significado básica e inamovible, que el juez debe acatar.

A diferencia de la buena fe subjetiva, que se aprecia en concreto, la buena fe objetiva se aprecia en abstracto prescindiendo el juez de las creencias o intenciones psicológicas de los contratantes, para puntualizar la conducta socialmente exigible de las partes, exclusivamente en base a la equidad, a los usos y en general, al modelo del hombre razonable, o sea, a los estándares legales.

Como el estándar de la buena fe tiene valor normativo, no sólo por estar consagrada legalmente en el ordenamiento, sino por autorizar al tribunal para determinar los efectos jurídicos del contrato, resulta que su aplicación configura una cuestión de derecho. La decisión es susceptible de ser revisada por vía de casación en el fondo.

5.6.1 FUNCIONES DE LA BUENA FE OBJETIVA EN MATERIA DE CONTRATOS.

Se ha dicho que tres formas, distintas pero íntimamente relacionadas, parecen reflejar de manera más idónea las funciones de la buena fe en las relaciones contractuales:

1. Como un canon o criterio para la interpretación y la integración de los contratos: La interpretación ha de hacerse de tal manera que el sentido que se atribuya a los contratos sea el más apropiado para llegar a un desenvolvimiento leal de las relaciones contractuales. La noción de lealtad se refiere al marco de expectativas que se establece en torno a una relación contractual. Tal marco traza los límites de lo que razonablemente pueda esperar un acreedor y de lo que es tolerable para un deudor, según la finalidad del contrato. Se dice que, aún cuando en las normas de interpretación de los contratos no exista una norma que se refiera directamente a la buena fe, la aplicación de este principio en la interpretación de aquellos deriva del propio tenor del artículo 1546. Es decir, la interpretación de un contrato contraria a la buena fe, afecta los alcances de las obligaciones contractuales, y con ello, viola el artículo 1546. Nuestros tribunales así lo han entendido, sosteniendo que “la buena fe es un principio primario en la interpretación de los contratos.”

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en un fallo de la Corte Suprema, pronunciado el 29 de enero de 2002 en conocimiento de un recurso de casación en el fondo. El litigio era entre una Universidad y una empresa constructora. La Universidad demandaba indemnización de perjuicios por el retardo en la entrega de obras por parte de la empresa, la cual se defendía alegando que dicho retardo se debía a una toma por parte de los estudiantes. El problema es que el contrato establecía que la determinación de qué podía constituir caso fortuito para efectos del cumplimiento del contrato quedaba entregado exclusivamente a la Universidad, y ésta estimó que la toma no lo era. La Corte rechazó el recurso de la Universidad y denegó la indemnización de perjuicios. Sostuvo que la facultad de determinar unilateralmente qué constituía caso fortuito debía entenderse limitada por la buena fe, no pudiendo ejercerse en los términos absolutos y arbitrarios que la literalidad del contrato sugería.

Además, la buena fe sirve como criterio para la integración de los contratos. La integración del contrato se encuentra en una relación de género-especie con la interpretación. Así, integrar un contrato consiste en determinar la reglamentación interna de un contrato cuando las partes no la han pactado expresamente. De esta manera, frente a una situación particular para la cual ninguna de las cláusulas del contrato ofrezca una respuesta, la buena fe permite determinar cómo ha de ser llenado dicho vacío.

2. Como un canon o criterio para limitar el ejercicio de derechos subjetivos: Fueyo expresaba al respecto que de los contratos “nacen obligaciones que admiten adecuación razonable por intervención de factores extraños al tenor literal y rígido del contrato. En tal virtud, se debe todo lo explícitamente

acordado que luego, sin embargo, pasará por el tamiz de la buena fe y la lealtad que se deben los contratantes.”

Podemos encontrar un ejemplo en un fallo pronunciado el 22 de mayo de 2019, en que la Corte Suprema determinó que el acreedor de un servicio de suministro había ejercitado la facultad de terminación unilateral del contrato de manera contraria a la buena fe. Por lo tanto, aunque el contrato le confiera expresamente esta facultad al acreedor, la forma de su ejercicio tiene su límite en el estándar de la buena fe: “Por ende, no parece posible abstraerse sin más de la ulterior responsabilidad que podría conllevar esa unilateral decisión por la sola circunstancia de haberse convenido en el contrato, ya que un término intempestivo, abrupto o abusivo bien podría importar una infracción de la obligación de ejecutar el contrato de buena fe, considerando, como acontece en la especie, que el prestador del servicio pudo incurrir en gastos en su actividad y/o sufrir perjuicios derivados de la resistencia de su contraparte en la continuación del vínculo que los ligaba, todo lo cual hace razonable reconocer el derecho a la indemnización de todo el daño que se sufra como consecuencia del término de los servicios”.

3. Como un criterio de conducta, conforme al cual deben ser cumplidas las obligaciones: En la buena fe puede basarse una ampliación del deber de prestación, más allá de los términos resultantes del contexto del contrato o de la ley. Así, se reconoce en la doctrina chilena que se deberá lo que no figura explícitamente y que resulta de aplicar los módulos buena fe y lealtad. Esta ampliación de deberes la realizará el juez, mediante una interpretación supletoria o integradora, mediante la que el juez añade, a lo estipulado por las partes, aquello que resulta necesario, para alcanzar los fines del convenio. Se afirma que esta interpretación supletoria del contrato, se sitúa en una zona gris, intermedia entre la interpretación propiamente tal y la determinación de los términos implícitos del contrato. Así, interpretar el contrato para dirigirlo a su ejecución leal, implica, muchas veces, dar lugar a obligaciones que no se pactaron expresamente, pero que las partes, sin embargo, asumieron implícitamente.

Por ejemplo, el deudor no puede esperar que se considere que ha entregado la mercadería a su debido tiempo si llega al establecimiento del acreedor el día previsto, pero a las 12 de la noche. Tampoco actúa de buena fe el acreedor si al determinar el medio de transporte a costo del deudor, envía las mercaderías con un correo-express.

5.6.2 MANIFESTACIONES DE LA BUENA FE OBJETIVA.

Aunque el CC sólo señala que los contratos deben ejecutarse de buena fe, hay una proyección normativa de la buena fe a todo el iter contractual, el cual abarca: i) tratativas preliminares; ii) celebración del contrato; iii) ejecución del contrato y; iv) terminación del contrato y relaciones post-contractuales.

1. Tratos preliminares.

No es posible enumerar todas las manifestaciones concretas de la buena fe durante todo el "íter contractual" porque éstas tienen una determinación flexible. Sin embargo, pueden señalarse algunos ejemplos:

- En los tratos preliminares **cada uno de los negociadores debe presentar las cosas conforme a la realidad**. Deben expresarse con claridad, absteniéndose de afirmaciones falsas o inexactas o de un silencio o reticencia que puede llevar a una errada representación de los elementos subjetivos y objetivos del contrato que se pretende celebrar.
 - Así, por ejemplo, respecto a los sujetos, no debe incurrirse en inexactitudes sobre la solvencia de los negociadores, sobre su salud mental, sobre sus aptitudes laborales, artísticas o técnicas, etc.
 - En relación al objeto, por ejemplo en el seguro contra incendio de un inmueble, debe informarse fielmente sobre los materiales de que se compone la cosa.
- En algunos casos, estas hipótesis pueden **configurar dolo en la conclusión del contrato**, aplicándose entonces el Art. 1458 CC.
- Incluso sin dolo, toda vez que se violan negligentemente los deberes de información, ha de remediarse lo hecho indemnizando por "culpa in contrahendo", configurándose **responsabilidad civil precontractual**.
- Otro ejemplo de buena fe objetiva durante los tratos preliminares, es el **deber de guardar los secretos** conocidos durante las negociaciones.
- También podemos encontrar el **deber de advertir que no se está en situación de concluir un contrato válido**, ya que se puede generar daño para la parte por haber sido envuelto en negociaciones inútiles, a raíz del retiro intempestivo y arbitrario del otro partícipe o por el ocultamiento de situaciones que resulten ser, posteriormente, causas de nulidad del contrato resultante.

2. Celebración del contrato.

Los **deberes precontractuales** subsisten en el instante de la conclusión del contrato.

En nuestro Código, algunos ven un ejemplo en el **Art. 1815 CC** sobre la venta de cosa ajena: las indemnizaciones a que tiene derecho el comprador en caso de ser evicta la cosa, se vinculan con la buena fe objetiva.

Don Jorge López Santa María **critica la limitada concepción actual de la lesión enorme** en Chile, que opera en muy pocos casos y que no permite anular (a

diferencia de lo que acontece en el derecho comparado) contratos a través de los cuales una de las partes hubiese explotado el estado de necesidad o la inexperiencia de la otra, obteniendo ventajas patrimoniales desproporcionadas e ilegítimas. Destaca el autor citado que cuando menos, estas situaciones de hecho podrían ser sancionadas por infringir el deber de rectitud y lealtad contractuales que la buena fe impone, otorgando una indemnización al afectado. La buena fe debiera imponer entonces un equilibrio mínimo a las utilidades que caracterizan el contrato conmutativo.

La buena fe, asimismo, impone **el deber de redactar la convención con la claridad necesaria**. Si se infringe este deber, podría tener aplicación la regla subsidiaria del Art. 1566, en el ámbito de la interpretación de los contratos. De esta forma, se castigaría indirectamente la mala fe de la parte que redactó la cláusula oscura o ambigua.

Los artículos 1468 y 1683 del Código Civil, se vinculan con la mala fe al momento de celebrar contrato.

- Art. 1468 CC. "No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícitas a sabiendas". De esta manera, quien contrató de mala fe, y ésta consistía en haber conocido la ilicitud del objeto o de la causa, no podrá obtener que se le restituya su prestación, tras la declaración de nulidad del contrato.
- Art. 1683 CC. "La nulidad absoluta (...) puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba": así las cosas, se castiga la mala fe, impidiendo que aquél que incurrió en ella, demande la nulidad del contrato.

3. Cumplimiento del contrato.

La **responsabilidad por incumplimiento es más amplia si hay dolo** (Art. 1558 CC). Pero no esto no es novedoso.

Progresos explicativos: En las instituciones vigentes, la buena fe contractual puede servir de argumento complementario, por ejemplo, a la excepción de contrato no cumplido.

Novedades normativas posibles:

- 1) Desestimación de la demanda de resolución por incumplimiento de poca monta.
- 2) Desestimar la demanda indemnizatoria por incumplimiento de un contrato, cuando la aplicación de la buena fe representare una causal de inexigibilidad (Por ejemplo, respecto del artista que no se presentó al espectáculo público a que se había comprometido, por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar cercano).
- 3) Admitir por los tribunales, conforme a las últimas tendencias de la doctrina, la posibilidad de revisar los contratos en casos de excesiva onerosidad sobreviniente.

4) Morigeración del sistema subjetivista de interpretación de los contratos.

4. Terminación del contrato y relaciones postcontractuales.

Después de terminada la relación contractual, la regla de la buena fe objetiva sobrevive, imponiendo **deberes específicos que dependen de las circunstancias**. La **idea general** es impedir conductas mediante las cuales una parte pudiere disminuir las ventajas patrimoniales de la otra.

Entre las conductas que impone la buena fe después de la muerte del contrato, destaca por ejemplo:

- Terminado el contrato de arrendamiento de oficinas o locales comerciales, el propietario debe **permitir al antiguo arrendatario colocar un aviso** anunciando el lugar al que se ha trasladado.
- También en lo que respecta al **deber de secreto, reserva o confidencialidad**. Aquellas cuestiones que uno de los contratantes hubiere conocido con motivo o con ocasión del contrato celebrado y ejecutado, y cuya difusión o conocimiento por terceros pueda dañar a la contraparte, deben permanecer en el secreto o reserva.

5.6.3 CONCLUSIÓN.

El principio de la buena fe es un instrumento morigerador de la autonomía de la voluntad en materia contractual, ya que permite, cuando corresponda, apartarse del tenor literal del contrato, ya sea ampliándolo o restringiéndolo, en virtud de las circunstancias propias del caso. Así, entre los principios de la autonomía de la voluntad y de la buena fe contractual existe una cierta tensión, toda vez que la autonomía de la voluntad implica una relación puramente estratégica entre contratantes que cautelan su propio interés, mientras que la buena fe impone criterios de lealtad hacia el otro contratante. En este sentido, podría decirse que la buena fe opera como un límite a la autonomía de la voluntad.

La buena fe objetiva permite equilibrar la fuerza obligatoria del contrato con los requerimientos de la justicia.

CAPÍTULO 6. INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS.

En términos muy amplios y generales, podemos decir que la interpretación consiste en aquella actividad por medio de la cual un sujeto (el intérprete) se enfrenta a un acto comunicativo (lo interpretado, generalmente un texto), con el objetivo de descifrar su significado.

En términos más concretos, la interpretación del contrato consiste en la actividad de determinar el contenido de la declaración de voluntad que consta en el contrato, con el objetivo de delimitar sus alcances y determinar las reglas aplicables a sus efectos jurídicos.

En doctrina se reconocen dos tipos de interpretación: la interpretación subjetiva y la interpretación objetiva. La interpretación subjetiva, vigente en países como Chile (art. 1560 CC) y Francia (art. 1156 del Code), concibe la tarea del intérprete en términos de una búsqueda de la intención de los contratantes al momento de celebrar el contrato. La interpretación objetiva, vigente en países como Alemania, prescinde de la intención subjetiva de las partes contratantes, y concibe la tarea del intérprete como la búsqueda de aquella interpretación que coincidiría con el sentido que un contratante promedio le daría a la convención en cuestión.

6.1 ¿CUÁNDO DEBEN INTERPRETARSE LOS CONTRATOS?

Al respecto, se han planteado dos posiciones:

- a) Los contratos solo deben ser interpretados cuando carecen de claridad. Es decir, el contrato solo debe ser interpretado si es oscuro o ambiguo, si sus términos no se concilian con la naturaleza del mismo, o si la relación entre sus distintas cláusulas es poco clara.
- b) La obscuridad del contrato no es un requisito de su interpretación, pues la distinción entre una cláusula clara y una cláusula obscura es, ella misma, el resultado de un proceso de interpretación. Así, el único requisito para proceder a la interpretación del contrato sería la existencia de un conflicto entre las partes.

Esta última postura es la que prima en la doctrina y jurisprudencia actuales. Se estima que no es posible formular un criterio a priori para distinguir entre una cláusula obscura y una cláusula clara, como para excluir ciertos contratos de la posibilidad de ser interpretados. Basta que haya un conflicto entre las partes, que reclamen la intervención judicial, y el juez está habilitado para interpretar el contrato.

A continuación, presentamos una enumeración no exhaustiva de las causas que podrían dar lugar a una contienda entre las partes en relación al alcance de un contrato:

- 1) Ambigüedad en el contrato: admite dos o más sentidos totalmente

diferentes entre los cuales se puede dudar.

- 2) Oscuridad en el contrato: no presenta ningún sentido determinado.
- 3) Los términos del contrato pueden ser claros, pero insuficientes.
- 4) Los términos pueden ser claros, pero excesivos.
- 5) Los términos pueden ser claros en sí mismos, pero haber sido empleados de manera dudosa.

6.2 INTERPRETACIÓN SUBJETIVA DE LOS CONTRATOS

Como ya hemos dicho, el sistema de interpretación vigente en nuestro ordenamiento jurídico, siguiendo el modelo francés, es un sistema subjetivo. La esencia del sistema subjetivo de interpretación consiste en que la tarea del intérprete es buscar la voluntad de las partes contratantes, para lo cual debe indagar en la intención de los mismos.

Dicho sistema se encuentra consagrado en el art. 1560 del Código Civil.

Art. 1560 CC. "Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras."

Al aludir a la "intención", ordena al intérprete una investigación psicológica. La meta del intérprete es la voluntad interna del sujeto. Esto no es tarea fácil.

¿Qué ocurre si el juez no puede encontrar la intención de las partes? De todos modos debe resolver la cuestión: debe buscar la voluntad "virtual" de las partes (cómo probablemente se habrían pronunciado las partes). Esto es aún más difícil.

Sin embargo, el Art. 1560 CC prescribe que el intérprete no puede pasar por encima de las palabras sino cuando llega a conocer claramente la intención de los contratantes. Por tanto, no hay lugar a intenciones virtuales, a diferencia del sistema francés. La intención debe tener un carácter de evidencia, lo cual se desprende de la fórmula "conocida claramente", empleada por el legislador.

Pese a ello, en la práctica, cuando no se logra conocer con claridad la intención de las partes, y la declaración es oscura, el proceso interpretativo se ve forzado a recurrir a los mismos arbitrios que en Francia, es decir, a indagar por la voluntad virtual de las partes.

En consecuencia, en ambos sistemas, cuando el intérprete no logra reconocer la voluntad psicológica real de los contratantes, se ve en la necesidad de inducir de las circunstancias del caso, de los elementos intrínsecos y extrínsecos a la declaración, su voluntad virtual o probable.

En este contexto, resulta fundamental tener en cuenta lo que la doctrina ha denominado 'circunstancias de la especie': Todos los hechos que configuran el contexto práctico en que tuvo lugar la convención, y que posibilitan esclarecer el sentido de la misma. Pueden ser anteriores, posteriores o concomitantes a la conclusión de la convención.

Podemos encontrar un ejemplo legal de la figura de las circunstancias de la especie en el art. 1564 incº2 CC, acerca de las cláusulas de otro contrato celebrado entre las mismas partes.

6.3 REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Reglas de interpretación: principios y moldes que sirven de base a los razonamientos del intérprete, y que le ayudan en la búsqueda de la intención común de los contratantes.

El intérprete debe servirse, en la medida de lo posible, de estas reglas para realizar su tarea, pero nada impide que tome también en consideración otros principios que no tengan sanción legal directa.

El Art. 1560 CC, más que una regla de interpretación propiamente hablando, sirve de principio rector a las reglas que le siguen. Su papel es superior al de una regla de interpretación, pues consagra en Chile, por sí solo, el sistema subjetivo tradicional de interpretación de los contratos.

6.3.1 NATURALEZA JURÍDICA DE LAS REGLAS DE INTERPRETACIÓN ¿NORMAS O CONSEJOS?

Importancia: determinando si son normas o simples consejos distinguiremos si se trata de una cuestión de hecho o de derecho y, por lo tanto, procede o no control de la interpretación de los contratos a través del recurso de casación en el fondo que conoce la Corte Suprema.

Dos posturas:

1. Constituyen consejos dados por el legislador a los jueces. Son reglas técnicas destinadas a actuar como criterios directivos del prudente arbitrio del juez, que es soberano en su interpretación. Por tanto, su dictamen sólo puede revisarse por vía de apelación, no de casación. Este criterio ya no tiene mucha vigencia.

2. Se trata de verdaderas normas jurídicas de carácter imperativo, cuya inobservancia por parte del juez puede ser impugnada en casación. (Opinión de don Jorge López Santa María). Dos argumentos:

- 1) Hay que buscar una forma para que las mismas normas de experiencia utilizadas por las partes lo sean también por el intérprete. Para ello, nada mejor que imponer al juez la utilización de ciertas reglas de interpretación. Así, se elimina la variabilidad de soluciones frente a un punto concreto.

- 2) Estas reglas de experiencia constituyen derecho, pues constituyen proposiciones que integran una norma jurídica.

6.3.2 CASOS DE INTERPRETACIÓN LEGAL.

En los casos de interpretación legal, el legislador no se limita a dar una indicación al intérprete, sino que realiza, abstracta y anticipadamente, y en todas sus partes la interpretación, dictando una solución que el juez deberá aplicar a todos los casos que correspondan a la hipótesis prevista por la ley. En todos estos casos, la solución dada por el legislador se reputa corresponder a la voluntad virtual del o los emisores de la declaración.

1) Casos en que el legislador fija el sentido que debe darse a una determinada cláusula dudosa si las partes la introducen sin explicar su extensión.

Ej.

- Arts. 567 a 575 (muebles e inmuebles),
- 1823 (venta a prueba) y
- 1874 CC (pacto comisorio calificado).

2) Casos en que las partes no se pronuncian sobre un aspecto particular. La ley suple este silencio dando la solución que corresponde a la voluntad que las partes habrían tenido. Ej. Regulación sobre compraventa, arrendamiento, sociedad, etc.

3) Casos en que la voluntad de las partes es interpretada por el legislador, frente a un silencio absoluto. Ej. Normas sobre sucesión intestada.

6.3.3 REGLAS DE INTERPRETACIÓN RELATIVAS A LOS ELEMENTOS INTRÍNSECOS DEL CONTRATO.

Interpretar a partir de los elementos intrínsecos significa interpretar el texto del contrato por sí mismo, considerando sólo los elementos que se encuentran, de una u otra manera, en la misma declaración contractual. Regla de:

1) La utilidad de las cláusulas:

Art. 1562 CC. "El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno."

Si una cláusula por su ambigüedad o por su oscuridad puede llevar a dos conclusiones diferentes, pero una de estas no tiene significado alguno y solamente alguna de ellas puede producir algún efecto, deberá preferirse esta última interpretación, porque es lógico suponer que las partes estipularon esa cláusula para que produjera algún efecto. La idea central de este precepto es que es lógico suponer que las partes no han deseado introducir en el contrato cláusulas inútiles o sin sentido.

Ejemplo: Si en un contrato de arrendamiento se determina que el arrendatario deberá pagar las contribuciones, debe entenderse que son las que imponen al dueño o al arrendador del local y no las que de todas formas afectan al arrendatario. Interpretar en sentido contrario la cláusula, conllevaría a que ésta no produjera efecto alguno, pues no se concibe que el arrendador quisiera imponer obligaciones que en modo alguno pueden afectarle.

2) Del sentido natural:

Art. 1563 CC. "En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato."

Cuando en un contrato los términos son susceptibles de dos sentidos, deben comprenderse en el sentido más conveniente a la naturaleza del contrato.

Por ejemplo: si se fija que la renta de arrendamiento de un inmueble urbano será de \$ 300.000, debe concluirse, aunque no se haya dicho expresamente, que se trata de una renta mensual y no anual o por el período que dure el contrato, pues es de la naturaleza de los arrendamientos de predios urbanos destinados a la habitación, que la renta se pague mensualmente.

Alessandri y Meza Barros incluyen en esta regla el inciso 2º del art. 1563, referido a las cláusulas de uso común. López Santa María, en cambio, las concibe como una regla diferente, que denomina regla de las cláusulas usuales.

3) La armonía de las cláusulas:

Art. 1564 inc. 1º CC. "Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad."

La interpretación de un contrato debe comenzar con la observación del contrato en su totalidad. Lo común es que las cláusulas de un contrato estén subordinadas unas a otras, de forma que haya entre ellas una correspondencia y armonía. De aquí, que el juez no puede interpretar las cláusulas de un contrato de manera aislada.

Sin embargo, podría ocurrir que las cláusulas observadas individualmente sean coherentes pero se tornen confusas y contradictorias al verlas en conjunto.

Ejemplo: Si en una carta-poder se autoriza al mandatario para cobrar las cantidades adeudadas hasta obtener el pago, y se agrega, en otra cláusula, que aquél pedirá que los valores se giren a favor de otra persona, se concluye que el mandatario no está facultado para percibir.

Otro ejemplo: Si en una cláusula de un contrato se dice que una de las partes

dona a la otra parte una porción de terreno, comprometiéndose, la segunda, en otra cláusula del contrato, a construir una línea férrea, la enajenación del terreno no puede estimarse hecha a título de donación gratuita, sino que debe considerarse como el equivalente de la construcción.

6.3.4 REGLAS DE INTERPRETACIÓN RELATIVAS A LOS ELEMENTOS EXTRÍNSECOS DEL CONTRATO.

1) Regla de la aplicación restringida del texto contractual:

Art. 1561 CC. "Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado."

La regla del artículo 2.462 CC relativa a la transacción tiene el mismo sentido, al señalar que: "Si la transacción recae sobre uno o más objetos específicos, la renuncia general de todo derecho, acción o pretensión deberá sólo entenderse de los derechos, acciones o pretensiones relativas al objeto u objetos sobre que se transige."

Por lo tanto, si se estipula una transacción que termina un litigio pendiente o precave un litigio eventual por mutuas concesiones recíprocas, y si "X" se obliga a pagar a "Y" \$ 500.000.-, estableciéndose que las partes se declaran libres de sus pretensiones respectivas, los términos generales del contrato no perjudican los derechos de "X" contra "Y" que surjan después de la transacción, ni tampoco aquellos que ya existían al momento de la celebración de la transacción pero de los cuales las partes no tenían conocimiento.

2) Regla de la natural extensión de la declaración:

Art. 1565 CC. "Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por sólo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda."

Esta disposición establece una regla aparentemente opuesta a la anterior. Los ejemplos puestos en un contrato, no implican que se aplique sólo al caso que se esboza como ejemplo.

La oposición entre el Art. 1561 CC y el Art. 1565 CC es puramente aparente, ya que son manifestaciones distintas de un mismo principio general, el que ordena al intérprete considerar todas las circunstancias de la especie.

Por ejemplo (siguiendo el ejemplo de Pothier), si en una capitulación matrimonial se dice que los esposos estarán en comunidad de bienes, en la cual entrará el mobiliario de las sucesiones que pudieren tocarles, esta cláusula no impide que también ingresen a la comunidad todas las otras cosas que a ella entran según el derecho común, pues el caso colocado por las partes sólo fue agregado para evitar dudas sobre el particular.

3) Regla de los otros contratos de las partes sobre igual materia:

Art. 1564 inc. 2º CC. "Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia."

Esta regla consiste en que se permite al juez recurrir a otros contratos celebrados por las mismas partes sobre idéntica materia. La convención que puede tenerse en cuenta durante la interpretación puede ser previa o ulterior al contrato objeto del litigio. Esta regla tiene especial aplicación en aquellos negocios que se realizan a través de una serie de contratos, todos ellos referentes a la misma materia.

Ejemplo: Si un contrato en que el actual demandando se comprometió a pagar una comisión por determinados servicios adolece de vaguedad, puede recurrirse, para interpretarlo, a un contrato que sobre la misma materia celebraron las partes con anterioridad y que dejaron subsistente para ciertos efectos indicados en el contrato posterior.

4) Regla de la interpretación auténtica:

Art. 1564 inc. 3º CC. "O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra."

La doctrina y la jurisprudencia han destacado la importancia de esta regla de interpretación. Luis Claro Solar, por ejemplo, ha sostenido que, esta disposición contiene la regla interpretativa más importante después de la regla general del art. 1560 CC. La razón concreta de la importancia de este precepto dice relación con el hecho de que la aplicación práctica que hagan las partes, o una de ellas con aprobación de la otra, respecto de las cláusulas que ellas mismas han pactado, debe entenderse como una "conducta interpretativa" acerca del contenido de sus estipulaciones. En esta conducta interpretativa encontramos un testimonio de su verdadera intención, en los términos del art. 1560 CC. En otras palabras, la importancia de este principio radica en que la mejor manera de conocer claramente la intención de los contratantes radica, precisamente, en la forma en que ejecutan lo pactado.

Podría pensarse que esta norma es problemática, en tanto su aplicación permite a los contratantes separarse de lo pactado en el contrato después de su entrada en vigencia. Esta objeción sería relevante si entendiésemos que esta regla permite que la aplicación práctica de una sola de las partes sirviese como criterio interpretativo. Pero debe ser descartada, toda vez que se exige la concurrencia de la voluntad de ambas partes para que la aplicación práctica del contrato sea tenida como una conducta interpretativa del contenido del mismo.

Ejemplo: En un contrato de suministros en que no quedan claramente

establecidos ni el lugar ni el momento en que debe hacerse la entrega de las mercaderías, pero en que el proveedor lleva varios meses entregándolas el día 5 de cada mes en el lugar "A", debe entenderse que ésa es la periodicidad y el lugar pactado para la entrega. Adicionalmente, no serían admisibles alegaciones que, invocando otras reglas de interpretación del contrato, pretendiesen que se determinase que el lugar y la periodicidad pactados eran otros.

6.3.5 REGLAS SUBSIDIARIAS DE INTERPRETACIÓN CONTRACTUAL.

1) Regla de las cláusulas usuales:

Art. 1563 inc. 2º CC. "Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen."

Esta regla es consecuencia de la referencia del Art. 1546 CC a la costumbre. Tiene poca aplicación práctica porque la costumbre en materia civil sólo tiene valor según ley. El intérprete sólo los considera cuando las partes se han referido formalmente a ellos o han sido recogidos por las normas legales supletorias de la voluntad.

2) Regla de la última alternativa y regla de la interpretación del contrato en contra del redactor:

Art. 1566 inc. 1º CC. "No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella."

Esta regla es aplicación de la regla del onus probandi: incumbe probar las obligaciones al acreedor (Art. 1698 CC).

La jurisprudencia nacional ha aplicado este precepto, respecto de contratos de adhesión.

Refiriéndose Alessandri al Art. 1566, inciso 1 CC, señala que su fundamento descansa en que aquél que ha querido obligarse, ha querido obligarse a lo menos. En cuanto al inciso 2, afirma que busca impedir que la parte que redactó el contrato o la cláusula en discusión, saque provecho de su negligencia y aun de su malicia. Como anotó Bello al respecto, "En caso de duda, se tiene menos consideración a aquel de los contratantes que pudo explicarse con más claridad, y omitió hacerlo".

Ejemplo: Suponiendo ambiguas o dudosas las cláusulas de un contrato de seguro relativas a una doble indemnización por muerte por accidente, debe

interpretárselas contra el asegurador que redactó el formulario contenido en la póliza, ya que la ambigüedad provendría de una falta de explicación que debió dar el asegurador. Por tanto, debe acogerse la demanda en que se cobra la doble indemnización.

6.4 CRÍTICA DEL PROFESOR LÓPEZ SANTA MARÍA AL SISTEMA SUBJETIVO DE INTERPRETACIÓN CONTRACTUAL.

❖ EL CARÁCTER FICTICIO DEL SISTEMA SUBJETIVO DE INTERPRETACIÓN.

El intérprete es concebido más como un psicólogo que como un jurista.

Las voluntades de los seres humanos son frágiles, contradictorias, caprichosas; incluso arbitrarias. Además, la voluntad interna, la real voluntad psicológica es incognoscible.

Es un engaño insistir en la búsqueda de las intenciones comunes, pues hay una cantidad de aspectos que, habiendo sido considerados por las partes, lo fueron de un modo diverso por cada una.

Debería eliminarse de la interpretación toda referencia a voluntades tácitas, probables o virtuales de los contratantes. Estas nociones no tienen sentido. O hay elementos de convicción suficientemente fuertes y entonces la voluntad es real, o no los hay y entonces la voluntad es impenetrable.

Llegado el momento de la interpretación, el contrato no interesa como acto genético de constitución de la relación jurídica, sino que como relación jurídica ya formulada.

❖ EL CARÁCTER INDIVIDUALISTA DEL SISTEMA SUBJETIVO DE INTERPRETACIÓN CONTRACTUAL.

El individualismo es una doctrina que, al afirmar que la sola voluntad del individuo es la fuente de los derechos subjetivos, no puede ser aceptada. En lo relativo a la interpretación de los contratos debería rechazarse el principio de la voluntad soberana, corrigiéndolo mediante la consideración, por el intérprete, de los elementos sociales susceptibles de proveer los modelos aptos para determinar, sin ficciones, los derechos y obligaciones que el contrato interpretado ha hecho nacer.

6.5. INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE LOS CONTRATOS.

1. Las normas del CC Alemán sobre interpretación contractual.

En cuanto a la interpretación de los contratos, la nueva doctrina alemana ha significado la creación de un sistema objetivo, en el cual no interesa la voluntad que tuvieron las partes al concluir el contrato, debiendo fijarse el alcance a las cláusulas discutidas de acuerdo al sentido normal de la declaración, de manera que los efectos jurídicos serán los que cualquier hombre razonable atribuiría a la convención.

El juez, al interpretar objetivamente, no toma sólo en cuenta el texto de la declaración, sino que también todos aquellos matices que rodean las relaciones

de las partes: las circunstancias de la especie.

2. Las circunstancias ostensibles de la especie. Comparación con el sistema subjetivo.

En ambos sistemas hay una idea común: el rechazo a la interpretación puramente literal de los contratos. Ambos consideran las circunstancias de la especie. Sin embargo:

1) Los límites son mucho más amplios en el sistema subjetivo, pues en el objetivo sólo interesan las circunstancias notorias, que fueron conocidas, o debieron serlo, por las partes. En el subjetivo, interesan todas las circunstancias susceptibles de esclarecer el contrato.

2) Las finalidades son diferentes. En el sistema subjetivo, las circunstancias sirven al intérprete para establecer la común voluntad interna y para fijar el sentido y alcance de la convención. En el sistema objetivo, sólo contribuyen a precisar y completar la declaración, que se interpreta después.

Principales aspectos a que se refieren las circunstancias de la especie:

- a) Objeto de la convención.
- b) Lugar donde se celebra.
- c) Finalidades generalmente económicas de las partes.
- d) Relación de parentesco o amistad entre las partes.

3. El hombre razonable como criterio de la interpretación objetiva.

El intérprete debe preguntarse por el modo como el destinatario ha comprendido la declaración. Pero esto no soluciona el problema.

El intérprete debe hacer resaltar una voluntad contractual puramente jurídica, una voluntad ideal que no es ni la del oferente ni la del aceptante, sino la del hombre medio razonable. Pero este estándar es algo indefinido; sólo sirve como principio general orientador.

4. El intérprete debe considerar los resultados económicos perseguidos por los contratantes.

Dentro de las circunstancias de la especie, los resultados económicos perseguidos por las partes ocupan un lugar destacado.

Para precisar la finalidad económica, es necesario conocer el significado de los signos utilizados por las partes, lo que sólo se puede lograr con las reglas de la experiencia: el juez debe poner en práctica sus conocimientos extrajurídicos.

5. La buena fe en la interpretación contractual objetiva.

La buena fe impide establecer como contenido de la declaración, salvo reserva expresa de las partes, algo diverso a lo que es usual o normal. La interpretación en correlación con la buena fe es aquella que se efectúa de acuerdo a lo dispuesto por los usos.

- Pero si las partes, de común acuerdo, atribuyen a la declaración un sentido diverso del usual, la buena fe exige respetar ese acuerdo, y

- prescindir en la interpretación de los usos.
- Si no hay tal acuerdo, ni usos susceptibles de determinar el sentido de la convención, la buena fe exige, en último término, la aplicación del criterio del hombre correcto u hombre medio razonable. Esto no difiere mayormente de la interpretación conforme a la equidad.

6.6. INTERPRETACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO

Para analizar este punto debemos distinguir dos situaciones: en primer lugar, la posible infracción, por parte del juez, a la ley misma del contrato (aquella que emana de la obligatoriedad del vínculo contractual, en los términos del artículo 1545), por errónea interpretación; y, en segundo lugar, la infracción a las normas de interpretación de los mismos (reguladas en los artículos 1560 y siguientes), por errónea calificación.

Por otro lado, es necesario tener presente la norma del artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, que establece la causal de procedencia del mencionado recurso. Sabemos, a propósito del contenido literal de dicha norma, que es posible impugnar una sentencia cuando ésta ha sido pronunciada con una infracción de ley que influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

La primera pregunta a resolver es, entonces: ¿procede la casación en el fondo contra la infracción a la ley del contrato?, es decir, ¿está comprendida la expresión “ley” dentro del artículo 767 nro. 1 del CPC? Pese a que es una materia discutida, hay razones para responder afirmativamente:

1. A pesar de que la ley del contrato está lejos de ser una ley general, su obligatoriedad para las partes, y en especial para el juez, es suficiente para concluir que su violación autoriza la interposición del recurso.
2. Los tribunales deben aplicar las leyes precisamente debido a su carácter obligatorio, debiendo en consecuencia, aplicarse los contratos por la misma razón. Pues donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición.
3. En base a la libertad contractual, los particulares pueden celebrar las estipulaciones que quieran, bastando que no violen disposiciones de orden público. El resto de la legislación es supletoria de la voluntad de las partes; es esta voluntad la que configura la ley principal. Si se sigue el criterio opuesto, los jueces podrían prescindir, en lo regulado por las partes, de las cláusulas estipuladas y resolver conforme a lo que les parezca más conveniente, pero en lo no estipulado, quedarían obligados por la ley supletoria. Se haría una diferencia inaceptable entre los contratantes prolijos que regulan todos los aspectos de su contrato, y aquellos que sólo regulan lo esencial.

4. La historia fidedigna del establecimiento de la ley así lo confirma. Además, así lo ha resuelto la jurisprudencia, pese a que en un principio no fue uniforme.

De esta manera, si un juez yerra formalmente en la aplicación de un contrato, decidiendo, por ejemplo, que no hay contrato cuando sí lo hay, o cuando se equivoque en su aplicación, junto con estar infringiendo el contrato mismo está vulnerando también la ley, en el sentido formal de la palabra.

Una segunda pregunta a resolver es: ¿procede la casación en el fondo por infracción a las normas de interpretación de los contratos?

Sabemos que la aplicación de un contrato puede llevar a divergencias respecto de diversos aspectos: (a) si ellas están vinculadas o no contractualmente; (b) cuál es el tipo de vínculo, es decir que se difiera sobre la calificación jurídica del contrato; (c) la existencia de una determinada obligación emanada de ese contrato; (d) por último, el sentido o extensión de la obligación.

Para resolver esas controversias el Código Civil ofrece un catálogo de normas de interpretación, que presuponen su existencia, pero también pueden servir para dar por establecido el contrato.

La norma del artículo 1560 nos ayuda a comprender que todo proceso interpretativo tiene dos aspectos: uno puramente material, fáctico o de hecho; y otro de tipo normativo. Determinar que dos partes han celebrado un contrato es un tema de hecho, y así también lo es saber en qué consiste lo que han convenido. Todo esto, igualmente, supone una labor probatoria cuya finalidad no es otra que asentar las bases físicas sobre las que se apoyará el proceso interpretativo.

Luego de tener por probada la materialidad del contrato y su contenido literal, entonces el juez debe entrar al proceso interpretativo, que busca fijar su alcance, es decir, su contenido normativo: a qué están obligadas las partes. No es una cuestión de hecho, sino que es normativa, pues busca fijar, conforme al contrato, aquello que se le impone a las partes.

Entonces, si no hay prueba clara de que hay una intención distinta a la que formalmente se ha expresado, el contrato debe aplicarse conforme con el tenor literal que se ha probado. Si, por el contrario, las partes han ofrecido prueba suficiente de que hay inconsistencia entre la literalidad expresada en el contrato y la común intención de los contratantes, el juez habrá de interpretar el contrato conforme a esa común intención y no dejarse llevar por su literalidad. En la búsqueda de fijar dicha intención, el contenido de la tarea del juez vuelve a entrar en el ámbito normativo.

Las reglas contenidas en los artículos 1561 a 1566 actúan como reglas subsidiarias, en cuanto buscan precisar la regla contractual. Por lo mismo, son

reglas obligatorias para el intérprete: si no son aplicadas, existe infracción legal que puede ser controlada por la vía del recurso de casación.

6.6.1 CASACIÓN EN EL FONDO POR ERRÓNEA CALIFICACIÓN DEL CONTRATO.

La calificación de los contratos atiende al hecho de determinar la naturaleza jurídica y las reglas aplicables al mismo. Según parte de la doctrina, esta situación no puede quedar puramente entregada a los jueces del fondo, toda vez que la mala apreciación de los hechos deja sin aplicación una norma estrictamente legal.

En concreto, la calificación de un contrato alude a: (1) establecer su naturaleza jurídica, (2) encuadrándolo en alguno de los tipos que regula la ley o en otro que, no estando considerado por ella, sea expresión de la libertad contractual de las partes, (3) operándose sobre la base de la esencia misma de los hechos que configuran el acto y no sobre la denominación que los contratantes pudieran haber empleado, (4) con el objetivo de determinar las reglas aplicables al mismo.

Siempre la interpretación debe preceder a la calificación: una resolución acertada comienza por investigar cuál fue la voluntad de las partes, para que, una vez fijado el alcance de la manifestación de voluntad que constituye el contrato, se proceda a su calificación. De lo contrario, existe el riesgo de prejuzgar las apariencias que pueden conducir a conclusiones erróneas.

La calificación del contrato es cuestión posterior a la interpretación del mismo. No obstante, esto es solo una regla general. Hay casos en que sólo se interpreta, pero no se califica. En otros casos ocurre lo inverso (poco probable). Pero lo frecuente es que el juez deba interpretar y calificar el contrato.

Toda errónea calificación de los contratos autoriza a la parte agraviada para deducir el recurso de casación en el fondo, pues la calificación de los contratos es una cuestión de derecho.

Una errónea calificación viola:

- 1) La ley del contrato.
- 2) La ley que define el contrato nominado.
- 3) La ley que define el contrato que la equivocada calificación suponga celebrado.
- 4) Las disposiciones legales que se pueden aplicar al contrato efectivamente celebrado, en el carácter de supletorias de la voluntad de las partes, como asimismo las disposiciones propias del contrato que la errónea calificación estima celebrado.

6.6.2 DISCUSIÓN SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO POR ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.

I. Improcedencia del recurso.

Las reglas de interpretación son meros consejos para el intérprete. La interpretación de los contratos es una facultad exclusiva de los jueces de instancia:

- 1) "Ley" en el Art. 767 CPC se refiere al Art. 1º CC, y no incluye la ley del contrato a que alude el Art. 1545 CC.
- 2) Siempre la interpretación de un contrato envuelve una cuestión de hecho.
- 3) No puede sostenerse que la fijación del alcance del contrato infrinja la ley del mismo, pues el contrato es precisamente el que los jueces dan por celebrado.

II. Improcedencia del recurso, salvo desnaturalización del contrato.

a) **Doctrina francesa de la desnaturalización:** la casación procede cuando una cláusula clara ha sido desnaturalizada por el juez. La interpretación de las cláusulas oscuras es privativa de los jueces del fondo, pero las claras deben ser respetadas, ya que no cabe interpretarlas. Si el juez pretende fijar el sentido de una cláusula clara, desnaturaliza el contrato.

b) **Doctrina de Luis Claro Solar:** no comparte la distinción entre cláusulas claras y oscuras: ambas deben ser interpretadas. La interpretación es una cuestión de hecho. Pero acepta la idea de la desnaturalización. Se desnaturaliza el contrato cuando el juez da a la voluntad una inteligencia contraria a la realidad, desconociendo la voluntad de las partes.

Crítica: Pero esto es tan amplio que permite la casación frente a cualquier interpretación errónea, aun considerando que es una cuestión de hecho. La doctrina de la desnaturalización sólo se entiende en base a la distinción entre cláusulas claras y oscuras.

La jurisprudencia ha aceptado la doctrina de la desnaturalización, pero la mayoría de los fallos la han entendido en el sentido que la plantea Claro Solar.

ANEXO I – COVID-19, CASO FORTUITO Y TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN.

Actualmente, una de las preguntas más recurrentes frente al derecho de contratos es si acaso la pandemia provocada por el Covid-19 y sus consecuencias son excusas que puedan invocarse legítimamente para fundamentar el incumplimiento de un contrato, ya sea por parte de una persona natural o jurídica, y principalmente por personas vulnerables en el caso de los deudores.

En este sentido se desarrolla el siguiente anexo, a propósito de distintos manuales y columnas de profesores y profesoras¹⁴.

1. El Caso Fortuito y sus elementos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, etc. De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser **inimputable**, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; **imprevisible**, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e **irresistible**, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.

2. Roles del caso fortuito en el Código Civil.

En materia contractual se estudia a propósito de una de las hipótesis que vendría a operar como causal de exención de responsabilidad. En este sentido, y como regla general, libera de responsabilidad al deudor (Arts. 1547 inc. 2o y 1558 inc. 2o CC).

En materia extracontractual se revisa a propósito de causales de justificación en relación con la imputabilidad a título de culpa o de dolo, y esencialmente en relación a la exclusión de la causalidad por caso fortuito o fuerza mayor.

3. Clases de imposibilidad que reconoce nuestro ordenamiento.

Parafraseando y siguiendo un conocido artículo del profesor Enrique Barros¹⁵, debemos tener en cuenta la diferencia entre estar obligado y ser responsable.

De la obligación surge el deber jurídico de cumplir la prestación de dar, hacer o no hacer algo en beneficio del acreedor. Es decir, de realizar o ejecutar la prestación.

¹⁴ Para quien desee profundizar, recomendamos la columna del profesor Mauricio Tapia, disponible online en: <http://derecho.uchile.cl/comunicaciones/columnas-de-opinion/el-covid-19-es-un-caso-fortuito---mauricio-tapia>

¹⁵ *La diferencia entre estar obligado y ser responsable*, Enrique Barros B. n H. Corral y M: S. Rodríguez (editores), Estudios de Derecho Civil II, Santiago, Lexis Nexis, 2007, pp. 721-752.

En cambio, la responsabilidad civil es la potestad que le confiere el derecho a los acreedores para dirigirse sobre todos los bienes que el deudor posea al momento de ejercerse la acción.

Estas diferencias se manifiestan entre otros, en los siguientes aspectos:

1. En cuanto al ejercicio de las respectivas acciones:

a) Para que se proceda al cumplimiento en naturaleza de la obligación (lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer, llamada también obligación de primer grado), basta con que se pruebe de los requisitos de su existencia (la existencia de un contrato, por ejemplo).

b) En cambio, para proceder a la acción de responsabilidad civil, se requieren exigencias adicionales. En efecto, para que tenga lugar la obligación indemnizatoria (obligación de segundo grado), se requiere que exista un incumplimiento y que éste sea imputable al deudor. Esto último significa que se efectúa un juicio de valor respecto del deudor: el incumplimiento se debe a que el deudor actuó con dolo o culpa.

Por lo tanto, sólo a condición de que la obligación de primer grado no sea cumplida en naturaleza, surge la acción de responsabilidad contractual, que tiene por objeto obtener la indemnización de los daños derivados del incumplimiento total o parcial o del retardo en su cumplimiento.

Y para cumplir en naturaleza la obligación, no debe efectuarse juicio de reproche alguno sobre la conducta del deudor.

2. Las diferencias se manifiestan, también, en la posibilidad de exoneración del deudor de cumplir la obligación, y en la posibilidad del mismo de exonerarse de la responsabilidad civil derivada del incumplimiento.

a) La exoneración de la obligación sólo puede resultar exitosa cuando no resulta posible su cumplimiento en naturaleza (por ejemplo, porque la cosa debida se perdió fortuitamente).

b) La exoneración de la responsabilidad supone atacar los supuestos en que se funda, como son el incumplimiento de la obligación de primer grado y que ese incumplimiento se deba a culpa o dolo del deudor.

4. ¿La pandemia del COVID-19 es un “caso fortuito” que permita justificar incumplir compromisos, postergarlos o, tal vez, solicitar reformularlos?

Todos los compromisos los asumimos teniendo presente un estado normal de cosas: que seguiremos trabajando y recibiendo sueldo, que podremos enviar a nuestros hijos al colegio, que el transporte y las ciudades seguirán funcionando, etc. El caso fortuito o “fuerza mayor” rompe esa normalidad, pues se trata de

infortunios, impensados e inevitables.

¿Qué requisitos debe cumplir el COVID-19 para ser caso fortuito? La dificultad que presenta esta noción, es que los requisitos que debe cumplir un suceso, para que sea considerado una hipótesis de caso fortuito, no son simples y, casi siempre, es difícil determinar si concurren. En esencia, un suceso, para ser considerado caso fortuito, debe ser imprevisible, irresistible y externo. Su dificultad se encuentra en que esos requisitos no son “absolutos” –porque lo absoluto no es de este mundo–, sino que se miden en relación con las posibilidades humanas. En síntesis, estos requisitos deben analizarse en función de lo que es imprevisible e inevitable para una persona normal y que honra sus compromisos en condiciones habituales. Por lo demás, basta que solo uno de sus requisitos no se presente en el COVID-19 para descartar la existencia del caso fortuito.

En cuanto a la imprevisibilidad, la pregunta clave es cuán probable era la ocurrencia de una pandemia de esta naturaleza. Se trata de una pandemia extraordinaria, de muy rápida propagación y de escala mundial, de una letalidad muchas veces superior a las anteriores, todavía desconocida en su real naturaleza y consecuencias. Es un fenómeno, por ello, improbable, pues la última vez que ocurrió algo parecido fue hace más de un siglo¹⁶. El COVID-19 es, en sí mismo imprevisible, pues es un desastre mundial, de alta letalidad y de muy rara ocurrencia. Por otro lado, hay que tener en cuenta que también son imprevisibles las decisiones de autoridad restrictivas de la libertad, como cuarentenas, cierres obligatorios de establecimientos no esenciales y toques de queda, que han sido motivados por la propagación de este coronavirus.

En cuanto a la “irresistibilidad”, es probablemente el aspecto más complejo y crítico. En realidad, este elemento envuelve dos preguntas distintas: ¿el suceso se pudo evitar? Y, luego, si no se pudo evitar, ¿podían al menos resistirse (controlarse) sus efectos? Si algo se puede evitar con medidas adecuadas, se es responsable si no se hizo lo necesario para impedirlo. Si algo inevitable se desencadenó, también se es responsable si se podían tomar medidas para controlarlo y estas no se tomaron.

Ahora bien, ambos elementos (inevitabilidad e irresistibilidad) tienen un rol diferente. El primero (evitabilidad) sirve para configurar la existencia misma del caso fortuito y el segundo (resistibilidad) para que surta sus efectos en el incumplimiento de ciertos compromisos obligatorios específicos. En efecto, podemos llegar a la conclusión de que el COVID-19 fue inevitable en general, pero puede que sus efectos se puedan controlar en determinados contratos. En síntesis, sobre el COVID-19, puede sostenerse que es un suceso absolutamente inevitable y, generalmente, irresistible.

Por último, en cuanto al carácter “exterior” del caso fortuito, significa simplemente que quien invoca un hecho como constitutivo de un caso fortuito en su favor, no

¹⁶ Nos referimos a la pandemia de la “gripe española”, de comienzos del siglo XX

debe ser la misma persona que lo causó. En el caso del COVID-19, es claro que se trata de un hecho exterior, así como las cuarentenas y restricciones impuestas por la autoridad. Un caso excepcional donde podría sostenerse que no es exterior, es aquella persona que se ha expuesto por su voluntad al virus, sabiendo de su alto contagio.

Por todo esto, puede afirmarse que el COVID-19 cumple, de manera general y abstracta, con los tres requisitos del caso fortuito. No obstante lo anterior, principalmente en relación al requisito de la irresistibilidad, de todas formas es necesario realizar un análisis en concreto y caso a caso.

ANEXO II – PROYECTO DE LEY PARA DARLE UNA CONSAGRACIÓN POSITIVA A LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN.

Boletín N° 13.474-07

Proyecto de ley.

Artículo único. - Incorpórese un nuevo artículo 1546 bis al Código Civil, en los siguientes términos:

Artículo 1546 bis: Si un cambio fundamental de circunstancias imprevisibles al tiempo de la suscripción del contrato convierte su cumplimiento en excesivamente oneroso para una de las partes, que no había aceptado ese riesgo, ésta puede solicitar a su contraparte la renegociación del contrato. Durante la renegociación, las partes continúan obligadas a cumplir sus obligaciones.

Si la renegociación no es aceptada o fracasa, las partes pueden poner término al contrato, en las condiciones y en el plazo que decidan, o solicitar de común acuerdo al juez que proceda a su adaptación. A falta de acuerdo dentro de un plazo razonable, el juez podrá, a petición de una de las partes, revisar el contrato o ponerle término, en las condiciones y en el plazo que él determine.

La Moción busca el reconocimiento positivo de la denominada “teoría de la imprevisión”, la cual ha sido admitida paulatinamente por la jurisprudencia de los tribunales ordinarios y con mayor frecuencia en tribunales arbitrales, y que ya se encuentra reconocida en diversos ordenamientos comparados, como lo son Italia, Alemania, Francia y Perú; y en algunos contratos internacionales en virtud de las denominadas “clausulas hardship”, las cuales se encuentran muy difundidas en el derecho internacional comercial y que regulan materias similares a la teoría de la imprevisión.

Ello, conforme la pandemia actual y la crisis económico social que ha conllevado, hacen necesarias todas las medidas económicas a fin de apoyar a las pymes,

personas de más bajos ingresos, trabajadores independientes que se han visto fuertemente golpeados por esta pandemia, las restricciones que se han debido tomar a fin de evitar un aumento de los altos número de contagio que estamos viviendo en todo el territorio nacional, y además realizar reformas que permitan entregar herramientas a las personas a fin de sostener sus fuentes de trabajo y emprendimientos que han sido duramente afectados, ya sea por la pandemia, las medidas que se han debido tomar para evitar los contagios y/o el desplome de la economía. La moción se enmarca en esta preocupación general por el bienestar de las personas en el contexto pandémico que vivimos.

Cabe en este sentido destacar que no es primera vez que se plantea la idea o moción de ingresar un proyecto que pretenda reformar el Código Civil y añadir expresamente la conocida "teoría de la imprevisión". En este sentido, se puede observar la moción incorporada en el Boletín 11532-07, que durante el año 2017 se ingresó al Senado, quedando el trámite estancado en el primer trámite constitucional. Por lo demás, si bien es bastante similar, la propuesta que se formula en dicha moción no es idéntica a la actual.

Ahora bien, el proyecto a propósito de la reforma señalada más arriba (año 2020) se encuentra en primer trámite constitucional¹⁷, en análisis por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado de la República.

En concreto, el proyecto de ley que propone introducir un artículo al Código Civil (Art. 1546 bis), consiste en regular la situación que se produce cuando "un cambio de circunstancias imprevisible al tiempo de la suscripción del contrato convierte su cumplimiento en excesivamente oneroso para una de las partes", para lo cual el proyecto considera necesario "el reconocimiento positivo de la denominada teoría de la imprevisión", con el objetivo de que "se permita al afectado solicitar la revisión judicial de los términos del contrato, o bien su resolución, a fin de perseverar un justo equilibrio en las prestaciones".

Si bien una moción de esta naturaleza parece loable, el profesor Víctor Vial Del Río estima que no es adecuado sustentar el proyecto en la "teoría de la imprevisión", que se fundamenta en principios generales de Derecho, como lo son la buena fe, la justicia y la equidad. En este sentido ha sostenido que la "teoría de la imprevisión" está superada por el razonamiento de los autores contemporáneos. Y aún más importante, el citado marco teórico ha encontrado escasa acogida en la jurisprudencia de nuestros tribunales, pues ha primado la opinión de quienes restan relevancia a la excesiva onerosidad sobreviniente que pudiera afectar a una de las partes contratantes, aplicándose en forma irrestricta el principio de la literalidad del contrato, en términos tales que este debe cumplirse en la forma convenida, aunque una de las partes quede en una situación desmedrada y perjudicial.

La doctrina moderna, en la que destaca el pensamiento del jurista italiano Emilio

¹⁷ El proyecto de ley fue ingresado el 5 de Mayo de 2020. Al 19 de Agosto, seguía en su primer trámite constitucional.

Betti, analiza el problema sobre la base de lo que constituye el aprovechamiento injustificado de un contrato por una de las partes, situación que ocurre cuando, por circunstancias sobrevinientes y que no pudieron preverse, la prestación de la otra parte se tornó excesivamente onerosa. En resumidas cuentas, la ejecución del contrato de buena fe impone a las partes obligaciones que, aunque no expresadas, derivan de la naturaleza de la relación jurídica entre aquellas, de modo que el contratante que se ve injustificadamente beneficiado debe someterse a la reducción de la prestación que se juzga excesiva, o si ello no fuera posible, a la terminación del contrato.

Según continúa exponiendo el autor citado, es crucial no olvidar que en nuestra legislación positiva existe una disposición que permite dar solución al problema mencionado: el artículo 1546 del Código Civil. Tal precepto establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe y que, por tanto, obligan no solo a los que en ellos se expresa, sino también a aquello que emana precisamente de la naturaleza de la relación de obligación. Sin embargo, por lo general, dicho precepto ha sido interpretado con un alcance reducido y parcial, como si la disposición se limitara a establecer la buena fe como un deber de conducta, sin reparar en que el legislador fue mucho más allá, pues determinó la necesidad de integrar o incorporar al contrato aún obligaciones que las partes no expresaron. Cabe señalar que el rol integrador de obligaciones que desempeña la ejecución de buena fe del contrato ha sido reconocido por la Corte Suprema, según lo comprueban sentencias recientes.

Vial del Río concluye sosteniendo que el proyecto de ley ganaría en claridad y precisión si se fundara justamente en el artículo 1546 del Código Civil, señalando que la facultad que se otorga al juez de reducir la prestación excesiva o de poner término al contrato obedece a una regulación que las circunstancias hacen aconsejable. Ello permitiría eliminar la aprensión que surge de aquella parte del proyecto que indica que este "solo sería aplicable a contratos suscritos con posterioridad a la pandemia". Para los contratos celebrados con anterioridad, los jueces debieran adoptar una solución similar, no con asidero en el artículo 1546 bis, sino que dando la aplicación que corresponde el artículo 1546 del mismo cuerpo legal, que es el marco dentro del cual se encuadra el nuevo artículo proyectado.

En relación al proyecto de ley en comento, el profesor Enrique Barros sostiene que la "teoría de la imprevisión" es un problema típico de contratación de ejecución diferida o permanente en tiempos de crisis. Sostiene que la propuesta legislativa tiene la virtud de ser una innovación que no nace de una idea que "anda dando vueltas", como es usual en el Derecho hispanoamericano, sino que toma como referencia la reciente reforma al Derecho francés de Obligaciones (2016). De hecho, sin decirlo, la norma del proyecto es traducción literal del nuevo Art. 1195 del Código Francés.

Por cierto, continúa el profesor citado, no es objetable tomar de prestado una regla probada por la mejor experiencia comparada. Pero sostiene que resulta absurdo,

concordando con Víctor Vial, que la regla solo rija para contratos futuros. Por cierto, hay razones de irretroactividad de las leyes sobre contratos, pero eso mismo muestra que la reforma propuesta no es remedio para lo que enfrentamos. En verdad, son los efectos de la tremenda crisis en que nos estamos sumergiendo, y no el escenario posterior, lo que debe ocupar a juristas y jueces.

Según sostiene Enrique Barros, lo que requiere el Derecho chileno de Contratos es incorporarse a la gran tradición del Derecho Civil a la que pertenece. El Derecho de contratos ha sido objeto de una profunda revisión en las últimas décadas, al menos desde dos puntos de vista: Por un lado, haciéndose cargo de las posiciones de desigualdad de las partes que negocian un contrato, neutralizando los abusos que se siguen de posiciones de asimetría de información y posición (especial y no exclusivamente en contratos de consumidores). Por otro lado, se ha procurado hacer más expedito y coherente el sistema de remedios para los incumplimientos contractuales. A estos cambios doctrinarios y jurisprudenciales responden las reformas al Derecho de Contratos en los dos principales Códigos de la tradición civil, el alemán y el francés.